



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006

فلسفه القانون

الأصلى

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ١٠

س١: اكتب في المذهب الاجتماعي؟

ص ١٢

س٢: اكتب في مفهوم العدالة كفاية للقانون؟

ص ١٩

س٣: اكتب في ماهية الأمن القومي مبيناً وسائل تحقيق الأمن القانوني؟

ص ٢٣

س٤: اكتب في ماهية الخير العام ودور الدولة في تحقيق الخير العام؟

2026

فلسفة القانون

تعريف فلسفة القانون

- محبة الحكمة. وقد شاع استخدام لفظ «فلسفة» منذ القرن السابع قبل الميلاد، وكان الفيلسوف يعرف بأنه المحب للحكمة.
- الفلسفة هي علم الكليات، حيث إنها تتناول بحث طبيعة الوجود والقوانين السائدة، والصلات القائمة بين أعيان الموجودات وبين أسس السلوك والمعرفة. وهذه الأسس أو الأصول الأولى، التي تعنى الفلسفة بالبحث عنها وكشفها، **تتناول ثلاثة موضوعات رئيسية هي: (الوجود، والمعرفة، والعمل).**
- دراسة الموضوعين الأولين تكون ما يسمى بالفلسفة النظرية، وهي تشمل على الأخص فلسفة الأديان، فلسفة التاريخ، نظرية المعرفة، المنطق، علم النفس، وعلم الجمال. ودراسة الموضوع الثالث تكون ما يسمى بالفلسفة العملية، وهي تشمل: فلسفة الأخلاق، وفلسفة القانون.
- يعد اصطلاح فلسفة القانون حديث نسبياً، إذ يرجع إلى القرن التاسع عشر ١٨٢١، حينما استعمله الفيلسوف الألماني هيغل (Hegel). وتحتل دراسة فلسفة القانون في الوقت الحالي مكاناً مرموقاً، في أوروبا وتحظى باهتمام كبير في الولايات الأمريكية واليابان.
- نحن من جانبنا نرى، إن دراسة فلسفة القانون تنصب على البحث عن العناصر الكامنة فيما وراء القانون، وصولاً إلى تحديد مبدأ سامي للعدالة، يأخذ منه القانون معناه، ويكمن فيه وحدته، ويتحدد محتواه.
- من هذا المنطلق **يمكننا تعريف فلسفة القانون بأنها:** «الدراسة التي تتناول الأسس الأولية الكامنة فيما وراء الظاهرة القانونية، وتهدف إلى الوصول إلى قانون تتحقق فيه الغايات النهائية للإنسان. وهي بذلك تعد وسيلة لدراسة البعد الميتافيزيقي للقانون، بتحديد فكرة العدالة وصلتها بالقانون، وبيان أن القانون وسيلة لتحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته، كل ذلك في إطار احترام البعدين الديني والاجتماعي للإنسان.

منهج البحث في فلسفة القانون

- يصطبغ أسلوب الدراسة الذي تسير عليه فلسفة القانون بما تصطبغ به الفلسفة بوجه عام، وهو النظر الكلى الشامل ومن هذا المنطلق اختلف موضوع فلسفة القانون عن علم القانون أو أصوله. إذ تتبع فلسفة القانون المنهج الكلى الشامل في البحث والاستقراء، أما علم القانون فإنه يدرس القانون في تطبيقاته الجزئية، فالفرق بين علم القانون أو أصوله وبين فلسفة القانون فرق في الطريق والأسلوب، أو هو فرق في الزاوية التي ينظر منها كل منهما إلى القانون، فعلم القانون ينظر إلى القانون كحالات جزئية خاصة، أما فلسفة القانون فإنها تنظر إليه ككل واحد شامل.
- فجميع شعوب العالم تعرف مجموعة من النظم والقواعد القانونية التي تنظم حياة الناس في جماعة أي نظام معين لقانون وضعي. وهناك أشكال ونظم متعددة مختلفة من هذه القوانين الوضعية. وموضوع علم القانون دراسة هذه النظم الوضعية كل على حدة، فيدرس قانون وضعي معين لشعب معين في زمن معين، أي يدرس القانون الروماني، أو القانون الفرنسي، أو القانون الألماني أو القانون المصري، أو الشريعة الإسلامية. كما إنه لا يعالج هذه النظم القانونية باعتبارها وحدة لا تتجزأ، بل يدرس أجزاء أو فروع منها، فيدرس القانون العام أو القانون الخاص مثلاً، وقد يقتصر على دراسة قسم معين من هذه الفروع فيدرس من القانون العام مثلاً القانون الدستوري أو القانون الإداري، ويدرس من القانون الخاص مثلاً القانون المدني أو القانون التجاري.
- يتضح من ذلك قصور علم القانون وعجزه عن الكشف عن ماهية القانون بمفهومه الكلى الشامل، لأنه لا يعنى إلا بدراسة قانون معين لشعب معين في وقت معين، فالنظرة الكلية الشاملة تخرج عن نطاق علم القانون ولكنها تعتبر الهدف الأول من دراسة فلسفة القانون.

نطاق علم فلسفة القانون

- إن فلسفة القانون تدرس القانون في جوانبه العالمية ونواحيه العامة. فهي لا تقتصر على بحث قانون وطني معين، بل تمتد إلى ما هو مشترك بين الأنظمة القانونية المختلفة، حيث إن القانون ليس مجرد ظاهرة وطنية، بل هو ظاهرة إنسانية، يمكن أن ينتقل من شعب إلى آخر، ويتم استيعابه عن طريق التأقلم.
- تراعى فلسفة القانون عند معالجتها للقانون في عمومها جانبين ما هو كائن وما يجب أن يكون فهي تدرس القانون كظاهرة، باعتباره نتاجاً ضرورياً للطبيعة الإنسانية، تحكمه أسباب عامة مشتركة، سواء في نشأته أم في تطوره، هذه الأسباب تكشف عنها الفلسفة لكي تصل من خلال ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون.
- يكاد يجمع علماء فلسفة القانون على أن فلسفة القانون

لنتناول ثلاثة موضوعات رئيسية هي (أساس القانون، وغايته، منهجه).

- المقصود بأساس القانون** ← ، ما هيته وجوهره وما يتكون منه، والبحث في أساس القانون يتناول الفكرة العامة الأساسية في تصور القانون، وما إذا كان القانون ينبثق من ضمير المجتمع بطريقة طبيعية لا شعورية أم أن لارادة الإنسان أثراً فعالاً في إنشائه، وما إذا كان نشوئه ينتج عن تفاعل عناصر مثالية أم يخضع لأثر القوة المادية، وما هي العناصر الهامة المشتركة بين جميع النظم القانونية.
- المقصود بغاية القانون** ← الأهداف التي يتوخاها - أو يجب أن يتوخاها - القانون، والتي تتمثل في مجموعة القيم التي يسعى إلى تحقيقها. وإذا كانت غالبية الفلاسفة متفقة على أن غاية القانون هي تحقيق العدل، إلا إن بعضهم يضيف إلى ذلك الأمن القانوني والتقدم الاجتماعي.
- المقصود بالمنهج القانوني** ← ، دراسة الترابط بين الأنظمة القانونية المختلفة، وبوجه عام تحديد الهيكل العام للبناء القانوني، وبوجه خاص دراسة نظريتي التفسير ودور القاضي.
- لما كانت النظرة إلى هذه الموضوعات قد اختلفت على مر العصور كان من الضروري للباحث في فلسفة القانون أن يلم بتاريخ الفكر القانوني وتطوره، وأن يدرس مختلف الصور التي اتخذها هذا الفكر، وأهم النظريات والمذاهب التي ظهرت فيه.
- هذه الموضوعات الثلاثة أساس القانون، وغايته ومنهجه، بالإضافة إلى تاريخ النظريات الفلسفية القانونية، تكون الهيكل العام لفلسفة القانون.

أهمية دراسة فلسفة القانون

- يعد القانون ضرورة اجتماعية ، لا غنى عنه في أي مجتمع، لضرورة تنظيم العلاقات بين أفراد، حيث يقوم بمهمة أساسية، تتمثل في ضبط الميول ومنع التصادم وتنسيق العلاقات والروابط التي لا يمكن في ظل النظام الاجتماعي أن تترك بين الأفراد. فالقانون يكفل النظام والأمن والاستقرار في المجتمع، ويؤمن الأفراد على أشخاصهم وأموالهم وحرياتهم. وإذا كان هذا هو شأن القانون في المجتمع فإنه يكون جديراً بإحاطته بالعناية الفائقة، لأنه كلما زاد إحكامه وإتقانه وقربه من الكمال، كلما زاد الاقتراب من تحقيق الغايات التي يسعى إلى تحقيقها.
- أولاً:** تؤدي دراسة فلسفة القانون إلى الارتقاء بمستوى التفكير القانوني، وزيادة الإدراك بالمشكلات الأساسية والأسس الأولية للقانون وتقديم الحلول للمسائل الكبرى التي يفترضها ويقترحها العقل الإنساني لأن فلسفة القانون تعتمد على التفكير العقلي التحليلي للأسس الأولية للقانون ومشكلاته المختلفة.
- كما إنها تخلق روح النقد المنظم تجاه النظم والقواعد. ولهذا، فإن دراسة التحليلات والنظريات التي قدمها كبار فلاسفة القانون،
- مثال ذلك:** أفلاطون أرسطو، توما الإكوييني، بنتام، كانط، هوبز، هيجل هوريو ديجي، وكلسن، وغيرهم، تعطي رؤية واضحة عن الفكرة الحقيقية للقانون، وتبين ما يجب أن تكون عليها، وتوسع المدارك في فهم حدود وقواعد الظاهرة القانونية، وتبين أنسب النظم القانونية للمجتمع، وتنمي ملكة النقد الصحيح لعلم القانون على أسس قائمة على المنطق السليم.

بوجه عام، فإن التأمل الفلسفي للقانون يعد مطلباً ضرورياً لتنظيم المعارف القانونية، ودراسة فلسفة القانون، ترفع من قدرة العقل على التفكير والتحليل الصحيح للمشكلات التي تثور في ميدان القانون.

ثانياً: تهتم دراسة فلسفة القانون بتحديد الأيديولوجية القانونية للمجتمع، إذ إنها بالبحث في الأسس الفلسفية للنظم القانونية، تحدد طبيعة النظام القانوني القائم وأبعاده وأصوله الفكرية. ففلسفة القانون تحدد الإطار الفكري والمبادئ التي يركز عليها النظام القانوني، والحقيقة إن تحديد المبادئ العامة للنظام القانوني، هي من صميم عمل فلاسفة القانون، نظراً لإلمامهم بأفكار كثيرة في مختلف العلوم الاجتماعية، بوجه خاص علوم المنطق والسياسة والاقتصاد والاجتماع والدين.

ثالثاً: تساعد دراسة فلسفة القانون على فهم القانون الوضعي،

من ناحية أولى :- تساعد على تحديد المضمون السليم لبعض الاصطلاحات اللغوية والكلمات ذات الدلالة في الحقل القانوني، **مثل:** العدالة الحق القانون. بالإضافة إلى إلقاء الضوء على معنى التعبيرات الأساسية في علم القانون، مثل: الملكية العقد الالتزام الحيازة إلخ. وذلك عند دراسة مصادر القانون وغاياته ومبادئ علم القانون،

من ناحية ثانية:- تساعد على بيان حدود الظاهرة القانونية ومدخلاتها الأساسية، حيث تتعرض بالتحليل والتأصيل لنشأة فكرة القانون، والعلاقة بين النظامين القانوني والاجتماعي، وتأصيل الأفكار الأساسية في عالم القانون، **مثل:** العقد، الالتزام، المسؤولية، وغيرها. وتحلي المفاهيم العامة والأساسية في النظم القانونية، مثل: العدالة، القانون النظام القانوني، وغيرها،

من ناحية ثالثة:- تساعد على حسن فهم المذاهب الكبرى في القانون والدولة، إذ لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً إلا باللجوء إلى فلسفة القانون،

من ناحية رابعة: فإن أي نظام قانوني يقوم على مجموعة من القيم والأسس، تمثل الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام، والأهداف التي يريد تحقيقها وتحليل هذه الأسس يؤدي إلى فهم هذا النظام وأبعاده، والدراسة التي تقوم بتحليل هذه الأسس وتقييمها ونقدها هي فلسفة القانون، ومن هنا تبدو أهمية فلسفة القانون كمدخل أساسي لفهم القانون.

رابعاً: تعد دراسة فلسفة القانون أداة لتطوير القانون والنظم القانونية، إذ عن طريقها يمكن مراجعة الأسس والمبادئ التي يركز عليها القانون في أي مجتمع. فإذا كان من المسلم به إن الفلسفة العامة قد أدت إلى تغيير الكثير من النظم السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات، فإن فلسفة القانون من باب أولى قادرة على القيام بالدور نفسه، حيث إن تغيير النمط الاقتصادي والسياسي للدولة أسهل بكثير من تغيير نمطها القانوني. ومن الجدير بالملاحظة، إن دور فلسفة القانون في تطوير القانون والنظم القانونية، ما هو إلا نموذج لأثر الفلسفة في القانون. فآراء وأفكار كبار فلاسفة القانون، كانت بمثابة الشرارة الأولى التي غيرت مجرى تاريخ الإنسانية وتطورها، وبالتالي تطوير القانون، فقد أدت نظريات جان چاك روسو و مونتسكيو، دوراً كبيراً في ظهور فكرة الدولة القانونية وتبلور مبدأ سيادة الأمة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وأدت أيضاً إلى بلورة أفكار عميقة مثل فكرة حقوق الإنسان، وغيرها من الأفكار، كما تطورت العديد من الأفكار القانونية في مجال نظم القانون الخاص، تحت تأثير فلسفة القانون، فقد حدثت ثورة كبيرة في علم المنهج القانوني تحت تأثير العلامة فرانسوا چيني،

حيث أدخل منهج التفسير الحر، وحرر الفقه القانوني من أغلال مدرسة الشرح على المتون التي جعلت القاضي والفقيه مقيدين أمام النصوص القانونية، لا يملكان إلا التفسير الحرفي لها، ولو كان بينها وبين الواقع بعداً شاسعاً، كما إن دراسة فلسفة القانون تعد أداة مهمة لفهم مدى انعكاس فلسفة معينة على القيم القانونية وعلى النظام القانوني، وتقييم هذا النظام وإظهار مدى صحة الأسس التي يقوم عليها من عدمه.

❖ **مثال ذلك :** عند تفسير حق الملكية، بوصفه أحد الركائز الأساسية في نظرية الحق في القانون، نجد إنه يتنازع **فلسفتان رئيسيتان هما: (الرأسمالية و الاشتراكية)** والنظر إلى أن حق الملكية حق مطلق، ترجع جذورها إلى فلسفة جون لوك، حيث فسر الملكية على إنها حق مطلق مقدس لا يجوز للدولة المساس به

علاقة علم فلسفة القانون بالعلوم الأخرى

❖ من المسلم به إن كل أنواع المعرفة تنبعث من ذهن الإنسان وعقله الأمر الذي أدى إلى وجود علاقة قوية ومتينة ومحكمة فيما بينها. ولقد جرى العقل البشري منذ عهد بعيد على تقسيم العلوم والمعارف إلى مجموعات معينة، هذا التقسيم يقوم على أساس وجود طابع خاص مشترك فيما بينها، فهناك علوم رياضية، وأخرى طبيعية، وثالثة اجتماعية، وهكذا. وفلسفة القانون فرع من فروع هذه العلوم الاجتماعية.

أولاً: علاقة فلسفة القانون بالفلسفة النظرية

❖ لقد نشأت فلسفة القانون في أحضان الفلسفة العامة، باعتبارها جزءاً من نظرة الفيلسوف العامة إلى الوجود كله، بما فيه المجتمع والقانون الذي ينظمه، فكان الفلاسفة يبحثون في فكرة أصول القانون استكمالاً لنظرتهم العامة إلى الوجود، ولذلك فإن العلاقة بين فلسفة القانون والفلسفة النظرية ذات أهمية بالغة، ففلسفة القانون تواجه القانون في أسسه العامة وفكرته المجردة.

ثانياً: علاقة فلسفة القانون بعلم النفس

❖ بعد علم النفس فرعاً من فروع الفلسفة النظرية، وهو العلم الذي يبحث في واقع النفس الإنسانية وحالاتها وقوانينها، ولذلك كان من الطبيعي أن تقوم بينه وبين فلسفة القانون صلة قوية، حيث يبحث كل منهما في النفس الإنسانية ووقائعها، فحتى نفهم أصل القانون ونشأته من الأهمية بمكان فهم طرائق علم النفس ومظاهر نشاط النفس البشرية. كما إنه إذا تم إصدار القانون الوضعي، فإن قواعده تتوجه بالخطاب إلى ضمائر الأفراد وما يقتضيه ذلك من الطاعة والامتثال، وبذلك يتجلى القانون في هذه الأحكام والوقائع النفسية. وبذلك يتضح ارتباط فلسفة القانون بعلم النفس.

ثالثاً: علاقة فلسفة القانون بالأخلاق

❖ تعد فلسفة القانون فرعاً من فروع الفلسفة العملية (أو فلسفة الأخلاق بالمعنى العام). والفلسفة العملية تعنى بدراسة الأسس والقواعد التي تنظم تصرفات الإنسان وسلوكه، وبذلك فإن صله الترابط بين فلسفة القانون والأخلاق جد متينة. فدارسي القانون يجدوا أنفسهم محتكين على الدوام بالأخلاق احتكاكاً شديداً، ففي دراسة التطور التاريخي للقواعد القانونية تظهر أن الأفكار الخلقية والنظم القانونية تسيران جنباً إلى جنب، فكل نظام وضعي له نظام مماثل من القواعد الخلقية.

رابعاً: علاقة فلسفة القانون بعلم الاجتماع

❖ يعد علمي فلسفة القانون والاجتماع علمين مستقلين عن بعضهما، حيث إن علم الاجتماع يبحث في الظواهر الاجتماعية، ويقف عند حد الوصف والتقرير. بينما تقوم فلسفة القانون بما هو أبعد من ذلك، حيث تدرس القانون كعلم من العلوم الهادفة الموجهة، أي إنها تهدف إلى رسم مثل أعلى للقانون. ❖ علم الاجتماع فإنه يبتعد عن تلك الدراسات الهادفة الموجهة، إذ يكتفى بدراسة الظواهر أو الوقائع الاجتماعية كما هي، لا كما يجب أن تكون. وعلى الرغم من استقلال هذين العلمين، إلا إن هناك وصلة قوية تربط بينهما، حيث إن من ضمن الموضوعات التي تعنى بها فلسفة القانون، موضوع دراسة الظواهر الاجتماعية، وهذا الموضوع يدخل في الوقت ذاته في نطاق علم الاجتماع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فمن مهام فلسفة القانون، دراسة العلاقات والروابط التي تربط الظواهر سواء كانت دينية أم خلقية أم سياسية أم اقتصادية. وهنا تظهر الصلة الوثيقة بين فلسفة القانون وبين علم الاجتماع

خامساً: علاقة فلسفة القانون بعلم القانون

❖ إن فلسفة القانون تعنى بدراسة القانون بصفته العامة الشاملة، فهي تبدأ حيث يقف علم القانون الوضعي، فتقدم له أدلته العقلية وأفكاره الرئيسية العامة. ففلسفة القانون تقوم بعملية العرض الشامل والتوحيد المنطقي لكل المسلمات الخاصة للفقه، وتتبع آثار البيئة والمحيط الذي اكتنف الحياة التاريخية للقانون، وتحاول تفسير العلل والأسباب العامة لنموه وتطوره وتقوم بوزن القانون الوضعي وتقييمه وفقاً لموازين ومعايير مجردة. ولذلك فإن فلسفة القانون لها نظامها الخاص الذي لا يشاركها فيه علم القانون

ويمكن إيجاز الفروق بينهما في الآتي:

١- **يختلف إطار فلسفة القانون عن علم القانون**، حيث إن إطار علم فلسفة القانون كلى عام مجرد، بينما إطار علم القانون جزئي خاص فعلم القانون يدرس القانون في خصوصه، أي القانون الوضعي لدولة معينة في زمان معين، ومن هنا تبرز الصفة الجزئية لعلم القانون. بينما فلسفة القانون تدرس القانون في عمومها، أي كحقيقة أو ظاهرة مجردة، وتعالج القانون من الوجهة العالمية، حيث لا تقتصر على دراسة خصائص، ومفهوم ومميزات قانون وطني معين، بل تمتد إلى ما هو مشترك بين النظم القانونية المختلفة، لأن القانون ليس ظاهرة وطنية، بل ظاهرة إنسانية. وعلى ذلك فإذا كان موضوع كل من فلسفة القانون وعلم القانون هو القانون، إلا إن كل من هذين العلمين ينظر إلى القانون من زاوية معينة. ولذا يقال إن علم القانون هو علم ما هو كائن، أما فلسفة القانون فهي علم ما يجب أن يكون.

٢- **تختلف غاية فلسفة القانون عن غاية علم القانون**، ويعد ذلك انعكاس لاختلاف موضوع كل منهما. فموضوع فلسفة القانون يتمثل في البحث عن الأسس البعيدة للقانون وتفسيراته المختلفة، ولذلك فإن هدفها هو البحث عن العلل الأولية للقانون والعوامل المؤثرة فيه وأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هدف فلسفة القانون يحدده منهجها التأملي في فكرة القانون. أما علم القانون فموضوعه جزئي محدد بالمكان والزمان يتمثل في القانون الوضعي السائد في دولة معينة، لذلك فهدف علم القانون يتمثل في إيضاح هذا القانون وبيان مراميه وقواعد تطبيقه. فهدف علم القانون يحكمه المنهج التفسيري التجريبي للنظام القانوني القائم.

٣- **يغلب على فلسفة القانون الطابع الشخصي الذاتي، أما علم القانون فيغلب عليه الطابع الموضوعي** فصيغة فيلسوف القانون لأفكاره ونظرياته حول القانون يحكمها ويحدد عناصرها شخصيته ومكوناتها وبالتالي تصطبغ أفكاره بطابع ذاتي، ولذلك فإن العنصر المميز للاختلاف بين الاتجاهات المختلفة في فلسفة القانون هو عنصر ذاتي بحت. فبعض فلاسفة القانون لتمسكهم الشديد بالأفكار المثالية وإيمانهم بالقيم العليا التي تجسدها القانون من حيث قيمته، إذ تدور أفكاره حول إيضاح الجوانب الأخلاقية والفلسفية للقانون وعدالة أو عدم عدالة القانون، والبحث عن أساس الإلزام به، كان حكمه قيمياً. ليس معنى ما تقدم إن الصلة بين فلسفة القانون وعلم القانون منبثة الصلة، فالحقيقة إن بينهما روابط وأواصر قوية وضرورية، إذ إن كل منهما يكمل الآخر، فمحل دراسة كل منهما هو القانون. فمن ناحية فإن علم القانون يحتاج إلى فلسفة القانون يستلهم مبادئها الهادفة الموجهة، التي تساعد على فهم جزئيات القانون وتطبيقاتها المختلفة، فعلم القانون لا يمكن أن يقتصر على مجرد الوصف المادي للقانون، وإلا انحسرت عنه فكرة العلم الحقيقي، حيث يجب عليه تبرير الظروف المادية المصاحبة لظهور القواعد القانونية فرجل القانون لا غنى له عن فلسفة القانون، إذ بدونها يظل عاجزاً عن الوصول إلى الأبعاد الحقيقية للقواعد التي يقوم بدراستها أو تفسيرها أو تطبيقها، بل يظل عاجزاً عن أن يخطو الخطوة الأولى في هذا الطريق.

ومن ناحية ثانية:- فإن فلسفة القانون بحاجة إلى علم القانون، إذ إن المبادئ الكلية والأولية للقانون، واستخلاص أسسه، تقتضي مسبقاً الإلمام به في جزئياته إلاماً تاماً، ثم إجراء عملية استخلاص أسسه من تلك الجزئيات استخلاصاً واقعياً مبنياً على المشاهدة والتجربة، وليس استخلاصاً نظرياً مبنياً على التصورات العقلية. ومن هنا يظهر إن كلا من فلسفة القانون وعلم القانون، متصل بالآخر، متعاون معه، ومكمل له.

سادساً: علاقة فلسفة القانون بعلم السياسة من المسلم به

إن علم السياسة وفلسفة القانون، يحتاج كل منهما إلى الآخر، فكل نظرية من نظريات فلسفة القانون تنعكس عليها نظرة صاحبها السياسية، وتصوره للمثل الأعلى فيما يتعلق بشكل النظام السياسي للمجتمع. كما إنه ما من قانون صدر إلا وكان تعبيراً عن الفلسفة التي يهدف المجتمع إلى اعتناقها، ويتضح ذلك من خلال الدراسة التحليلية لفكرة ورة القانون في المجتمعات القديمة والحديثة، فالقوانين النازية تعد تطبيقاً للفلسف

غاية القانون

الغايات الأيديولوجية للقانون

قد عرف الفكر القانوني عبر تاريخه الطويل تقلبات متتابة حول غاية القانون وهدفه، ويمكن رد الاتجاهات المختلفة في هذا الصدد إلى مذهبين أساسيين، هما: المذهب الفردي، وهو المذهب الذي يتخذ من الفرد نقطة البداية، ويجعل من المصلحة الفردية الغاية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها. وما دامت الغاية فردية، فإن الوسائل تكون بالضرورة فردية. والمذهب الجماعي، وهو المذهب الذي يتخذ من الجماعة نقطة البداية، ويجعل من مصلحة الجماعة الغاية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، وبطبيعة الحال فإن وسائل بلوغ هذه الغاية تكون بالضرورة جماعية.

المذهب الفردي

يُعد المذهب الفردي أهم المذاهب الفلسفية، سواء من حيث قوته أو من حيث ذبوعه وهيمنته على النظريات المتعلقة بالغاية الأيديولوجية من القانون، لفترات طويلة، حيث نجد له جذوراً قديمة، إذ ثمة فردية لدى السوفسطائيين، والأبيقوريين، غير أن تلك الفردية ظلت في المجال الفلسفي، دون أن تتبلور في مذهب قانوني. ولقد كان لوك أول من قدم فكرة نظامية عن هذا المذهب في نتائجه القانونية، وقد استأنفه روسو في عبارة مختلفة، ثم وجد لدى كانط نصه الدقيق. وقد اتخذ فيشته أيضاً نقطة انطلاق، ثم أضفى عليه إعلان حقوق الإنسان صده السياسي، ولذلك فهو يسود التفسير القانوني في القرن التاسع عشر.

أولاً: أسس المذهب الفردي:

تقوم فلسفة المذهب الفردي على تقديس الفرد في مواجهة الجماعة، بحيث يضيق نطاق تدخل القانون في حياة الفرد، ويمنح الفرد حرية كبيرة وحقوق مطلقة، وبالتالي لا يتدخل القانون في حياة الفرد إلا بالقدر الضروري وفي أضيق الحدود. وعلى ذلك، فالقانون وُضع لخدمة الفرد، حيث إن الأخير هو غاية القانون. ويعتبر المذهب الفردي هو محور الفلسفة الفردية، والتي تقوم على تقديس الفرد باعتباره أساس النظام الاجتماعي وغايته. فالإنسان الفرد هو محور الوجود، ومن ثم فهو غاية في ذاته، وليس مجرد وسيلة لتحقيق أهداف المجتمع. وبالتالي فإن كل القيم لا بد أن يكون محورها الفرد، كما أن وجد المجتمع يعتبر وسيلة لتحقيق غاياته، والسلطة السياسية وجدت من أجل حماية هذه الغايات.

قد ذهب أنصار المذهب الفردي إلى القول بأن الغاية المثالية للقانون هي حماية الفرد وحرية، فكل النظم القانونية يجب أن تضع نصب أعينها كغاية أسمى شخصية الفرد.

تنطلق الفلسفة الفردية من فرضية معينة، هي أن الإنسان في حالة الطبيعة عاش منعزلاً، وأن المجتمع المنظم قد تكون نتيجة الدخول الاختياري للأفراد في تكوين المجتمع. فالإنسان، طبقاً لهذا المذهب، سابق في وجوده على المجتمع، وهو الذي أوجد هذا المجتمع لمصلحته، وليس العكس. وبناء على ذلك، فإن الفرد يتمتع في الواقع بقيمة أسمى من المجتمع، ولذا يجب على المجتمع أن يعمل بكل تنظيماته بما فيها القانون على خدمة الفرد والمحافظة على كرامة حياة الإنسان ورحيته.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن المذهب الفردي يقوم على تقديس حرية الفرد واحترامه، والمجتمع المثالي هو الذي يعطي للفرد أكبر قسط ممكن من الحرية. فالمجتمع لا يعدو أن يكون بناء مكوناً من عدد من الأفراد، يستطيع كل منهم أن يمارس حقوقه بنفسه، ويستفيد من نشاطه، فإن سعد الفرد سعد المجتمع. فالإنسان يولد حراً، ومن حقه أن يُحسن من حالته الاقتصادية والفكرية، وأن يستفيد من نتائج عمله ونشاطه. ومن حقه على سائر الأفراد أن يحترموا حقوقه وحرية، ويتركوا له التمتع بما كسبت يداه. ولكن، بالضرورة، يجب عليه، لكي يضمن احترام الناس لحرية، ولكي يحافظ على حقوقه في الوقت ذاته، أن يتنازل عن جزء من حقوقه لصالح المجتمع، ومن هنا نشأت فكرة الحق والواجب.

قد اعتمد المذهب الفردي على مذهب القانون الطبيعي، الذي وُجد عند الإغريق والرومان، ثم أصبح أساساً لفلسفة العقد الاجتماعي التي ظهرت في القرن الثامن عشر.

ثانياً: نتائج المذهب الفردي:

كان لظهور المذهب الفردي وانتشاره، على يد فلاسفة وكتاب القرنين السابع عشر والثامن عشر، أثره الواضح في كافة المجالات، سواء في المجال السياسي، أو في المجال الاقتصادي، أو في المجال القانوني.

أ- أثر المذهب الفردي في المجال السياسي:

كان للمذهب الفردي أثراً كبيراً في المجال السياسي، تمثل في محاربة طغيان الدولة واستبدادها، وقد ظلت له السيادة في عالم السياسة طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، مما ترتب عليه ظهور الحريات السياسية، وإطلاق الحريات الفردية في المجال السياسي، وعدم تقييدها إلا في أضيق الحدود، وبالقدر الذي يجعل استعمالها لا يتعارض مع حريات الآخرين. ومن هنا ظهر مبدأ الأفراد متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات السياسية.

ب- أثر المذهب الفردي في المجال الاقتصادي:

كان للمذهب الفردي أثره البارز في المجال الاقتصادي، حيث ساعد على حرية المنافسة، وتشجيع المبادرة الفردية. ففي ظل المذهب الفردي يبحث كل فرد من أفضل وسيلة لاستثمار أمواله، بما يحقق له أكبر عائد ممكن. كما يؤدي المذهب الفردي إلى سيادة مذهب الاقتصاد الحر، وما يترتب عليه من نتائج، وإطلاق حرية التجارة، وتداول الثروات طبقاً لقانون العرض والطلب.

قد تحمس الفرديون في نطاق الاقتصاد لنظام المنافسة الحرة، واعتبروه المحرك الأول والأقوى للاقتصاد البشري كله، ورأوا إن صراع المصالح الخاصة للأفراد لن ينتج عنه إلا خير المجموع ونفعه. فالنظام الاجتماعي عندهم يركز على الفرد، فهو الغاية ولخدمته يتم تسخير المجموع، والفرد لا يستكمل شخصيته - بل آدميته - إلا بالحرية، وكما إن رجال الفلسفة يجعلون التفكير آية الشخصية من الناحية الفلسفية، فإن رجال القانون من أنصار المبدأ الفردي يجعلون الإرادة آية الشخصية من الناحية القانونية.

في ضوء هذا المذهب:- برز دور الحرية الفردية في نطاق الاقتصاد، والفرد لا يبدأ أي مشروع إلا عن حرية واختيار، فله حرية تنظيم أسس هذا المشروع وقواعده على النحو الذي يرضيه. فالتجارة تقوم على الحرية التي لا يحدها حد، وكل تدخل من المشرع بحجة التنظيم القانوني للأعمال التجارية والاقتصادية، لن يؤدي إلا إلى الكساد والركود ومحو الشعور بالمسؤولية وتثبيط العزائم وقتل روح الإبداع والابتكار والمجازفة، وهي أمور لا تنهض التجارة وتزدهر بدونها.

ج- أثر المذهب الفردي في المجال القانوني:

كان للمذهب الفردي تأثيراً هاماً في المجال القانوني، ويتضح ذلك من عدة جوانب:

جانب أول ← تبنى هذا المذهب فكرة حرية التعاقد، حيث إن الفرد، نظراً لما يتمتع به من حرية، يستطيع بإرادته الحرة المقدرة أن ينظم كل أموره، والقانون في نظرهم لا يستطيع أن يتدخل لرعاية مصلحة أحد الطرفين المتعاقدين، دون الطرف الآخر، فليس من وظيفة القانون أن يمد يده إلى الضعفاء اقتصادياً أو اجتماعياً، فعلى الفرد أن يسهر على مصالحه الخاصة بنفسه. كما ذهب أنصار هذا المذهب إلى القول بأن العقد أي توافق الإرادتين هو الأساس الذي تقوم عليه سائر العلاقات القانونية. ويرجع ذلك، إلى أن الفكرة الأساسية للفلسفة الفردية، تؤدي إلى وضع الإرادة الحرة في القمة من حيث الأهمية، فالإنسان سيد مصيره وتصرفاته، وهو الذي ينظم حقوقه بإرادته الحرة.

جانب ثاني ← انعكس تبني المذهب الفردي على تعريف القانون، باعتباره يعمل على تحقيق توافق الحريات الفردية، وإقامة التوازن بينها، حتى لا تصطدم ببعضها إذا تركت وشأنها. ومن هنا عرف كائناً القانون بأنه: مجموع الشروط، التي بفضلها يستطيع تحكم أن يتعايش مع تحكم الآخرين، وفقاً لقانون عالمي للحرية. وانطلاقاً من المذهب الفردي، عرف البعض الآخر القانون بأنه مجموعة القواعد التي تخضع لها، تحت طائلة الجزاء الذي توقعه السلطة الاجتماعية، حرية الفرد في تنازعها مع حرية الآخرين.

جانب ثالث ← كان لهذا المذهب أثره الواضح على حركة التقنيات في العصر الحديث، حيث وُضعت في ظله، وتحت تأثير تعاليمه، أغلب التقنيات التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر، خاصة التقنيات الفرنسي الذي وضع في عام ١٨٠٤، وكذلك التقنيات التي صدرت في بداية القرن العشرين والتي تأثرت تأثيراً كبيراً به، مثل التقنيين الألماني الذي وضع في عام ١٩٠٠، والتقنيين السويسري الصادر في عام ١٩١٢، وبعض التقنيات العربية المتأثرة بالتقنيين الفرنسي مثل التقنيين المصري واللبناني.

ثالثاً: نقد المذهب الفردي:

يمكن القول بأن المذهب الفردي له مميزات وعيوب، فيحسب للمذهب تقديسه للحرية الفردية، وتشجيعه للنشاط الفردي، وإقراره مبدأ المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات. إلا أنه ينسب إليه بعض العيوب، والتي تتمثل في:

- ١- قصر المذهب الفردي وظيفة الدولة على حفظ الأمن والنظام داخل الدولة وخارجها، وحرمانها من التدخل في النظام الاقتصادي والاجتماعي .
- ٢- فشل المذهب الفردي في تحقيق التوازن بين السلطات والحرية، حيث أثبتت التجربة عجز المذهب الفردي عن تحقيق الحرية الحقيقية للمواطنين، بل إن الفلسفة التي قام عليها تتضمن تناقضاً أساسياً مع أسس الديمقراطية، حيث ترتب على مبدأ المساواة القانونية بين الأفراد، دون المساواة الحقيقية، إلى قيام الرأسمالية الكبيرة وسيطرتها على مقاليد الحكم في الدولة .
- ٣- رأى هذا المذهب أن المنافسة الحرة بين الأفراد تؤدي إلى صالح الجماعة، إلا أن التجارب أثبتت عكس ذلك. فقد أدت تلك الحرية إلى ظهور الاحتكارات، فالحرية الاقتصادية أدت إلى نشوء كثير من المؤسسات ذات القوة الاقتصادية الكبيرة، التي استطاعت بتضامنها الحد من المنافسة الحرة، والجنوح إلى الاحتكار، الذي ترتب عليه زوال بعض المؤسسات الفردية من الوجود .
- ٤- اكتفى المذهب الفردي بإعطاء الحرية للأفراد، وحرمان تكوين الجمعيات التي تمثل مصالح بعض الهيئات، ك النقابات العمال .
- ٥- وقف المذهب الفردي عند حد تقرير الحقوق والحريات من الناحية القانونية للأفراد، كحرية التملك، وحرية العمل... إلخ. ولكنه لا يضمن للجميع من الناحية الواقعية، ممارسة هذه الحريات، فهو لا يضمن للشخص أن يكون مالكا ولا أن يجد عملاً، بل ترك الأمر لنشاط الأفراد وجهدهم، مما أدى إلى حرمان الضعفاء من ممارسة هذه الحريات. وبذلك تبين عجز المذهب الفردي عن ضمان الأعمال الفعلية لحقوق الأفراد.
- ٦- عجز المذهب الفردي عن حماية حقوق الأفراد، حيث أثبت التاريخ عجزه عن توفير الحماية الفعالة لحقوق الأفراد، بسبب اعتماده على فكرة المساواة القانونية، وتقريره لمبدأ الحرية الاقتصادية التي تؤدي عملاً إلى إهدار مبدأ المساواة.
- ٧- أدى إعمال المذهب الفردي إلى تهميش دور القانون في المجتمع. فمن ناحية، أدى إلى تضيق فكرة النظام العام والآداب، وهي فكرة جوهرية في أي نظام قانوني، وقد تمثل ذلك في زيادة القواعد المكملة على حساب القواعد الآمرة، وبوجه عام فكلما انتشر المذهب الفردي زادت دائرة القواعد المكملة وقلت القواعد الآمرة، الأمر الذي يعني تقليص دور الدولة الإيجابي في تنظيم شئون الجماعة. ومن ناحية ثانية، أدى المذهب الفردي تضيق نطاق المسؤولية المدنية، حيث إن مسؤولية الفرد لا تقوم ولا يكون مسؤولاً عن تعويض الغير عما لحقه من ضرر إلا إذا أمكن إثبات أن هذا الضرر راجع إلى خطأ ثابت أو مفترض في جانبه، وفي غير ذلك لا يكون مسؤولاً، وبالتالي لا يُسأل الشخص على أساس فكرة تحمل التبعة أو الضمان أو التضامن الاجتماعي أو الغنم بالغرم، لأن هذه الأفكار كلها من أسس المسؤولية طبقاً للمذهب الاجتماعي.
- ٨- وقع هذا المذهب في مغالطة تاريخية فالقانون الذي لا يوجد الحق بدونه لم ينشأ إلا داخل المجتمع، وهذا يعني أن فكرة القانون لم تنشأ إلا عندما اجتمع الإنسان بغيره من بني البشر داخل مجتمع واحد.

س ١ : اكتب في المذهب الاجتماعي؟

المذهب الاجتماعي

نشأ المذهب الاجتماعي لمعالجة الآثار السيئة التي ترتبت على الأخذ بالمذهب الفردي، إذ أدى المذهب الفردي إلى فصل النظام السياسي عن النظام الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى سيطرة الطبقة الرأسمالية على النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تملكها لرأس المال، وقد ترتب على ذلك مساوئ كثيرة ضارة بحقوق الإنسان. وعلى أثر تفاقم المشاكل التي نتجت عن النظام الرأسمالي، ظهر اتجاه يبغى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإصلاح الأضرار الناتجة عن المذهب الفردي، وركز هذا الاتجاه الاجتماعي على ضرورة تدخل الدولة في جميع الأنشطة، وبالأخص في المجال الاقتصادي.

المذهب الاجتماعي يهدف إلى محاولة تحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد في المجتمع، وذلك بقيام الدولة بالدور الأكبر في كافة الأنشطة، بما لها من امتيازات وهيمنة على جميع أفراد المجتمع. وتأسيساً على ذلك، قام المذهب على توسيع دور الدولة في المجتمع وتقليص دور الفرد، بحيث تضطلع الدولة وليس الأفراد بالكثير من المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، وبذلك انتقل الاهتمام من الفرد إلى الجماعة.

أولاً: أسس المذهب الاجتماعي:

قام المذهب الاجتماعي على أساس واقعي، وليس على أساس ميتافيزيقي مثل المذهب الفردي، فالقانون لا يهتم بالإنسان كفرد منعزل ومستقل عن غيره من الأفراد، بل يهتم به ككائن اجتماعي مرتبط بغيره من البشر ويعيش معهم في جماعة.

المذهب الاجتماعي يقوم على فكرة أن الفرد كائن اجتماعي، أي عنصر من عناصر المجتمع، وأن المجتمع ليس جمعاً من الأفراد المحتفظين بذواتهم، بل هو وحدة متجانسة ومتضامنة، بحيث تذوب شخصية الفرد داخل المجتمع. ويترتب على ذلك، أن تنبج عناية القانون إلى إسعاد المجتمع حتى يسعد الفرد. وسعادة المجتمع لا تتحقق إلا بترك قدر ضروري من الحرية للفرد، ليتمكن من إظهار مواهبه وكفائته، ولتحقيق تلك الغاية، يجب أن تعمل الدولة على تنمية فكرة التضامن الاجتماعي بين الأفراد، والتدخل في أوجه النشاط المختلفة. ويجب على كل فرد أن يتحمل قدرًا من الأعباء التي تفرضها الحياة الاجتماعية المشتركة.

ينبني على ذلك، إن الجماعة وليس الفرد، هي الهدف الأسمى للوجود. ولذلك فإن الغاية من القانون، في ظل المذهب الاجتماعي، هي تحقيق مصلحة الجماعة وسعادتها. لأن الجماعة هي الغاية العليا، وليست وسيلة أو أداة لتحقيق غايات أخرى. ومن ثم، يجب تسخير كل الوسائل، ومن بينها القانون، في خدمة الجماعة، أو بالأحرى الدولة، التي تمثل الجماعة في العصر الحديث.

لقد ظهر المذهب الاجتماعي نتيجة لفلسفة المدرسة التاريخية، وفلسفة المذاهب الواقعية (مثل مذهب ديجي) في القرن التاسع عشر، وازدادت أهميته في القرن العشرين.

قد ظهر المذهب الاجتماعي، منذ نهاية القرن التاسع عشر، في أشكال مختلفة، وفي أكثر من مدرسة من المدارس الفلسفية، وإن كان أبرز تلك المدارس هي: الاشتراكية، الشيوعية، القومية. وعلى الرغم مما يوجد بينها من فروق عديدة، إلا أن القاسم المشترك الأكبر بينها جميعاً هو أولوية المجتمع على الفرد، وأن غاية القانون هي تحقيق مصلحة الجماعة.

ثانياً: نتائج المذهب الاجتماعي:

كان لظهور المذهب الاجتماعي، أثره الواضح في كافة المجالات، سواء في المجال السياسي، أو في المجال الاقتصادي، أو في المجال القانوني.

أ- أثر المذهب الاجتماعي في المجال السياسي:

أدى اعتناق المذهب الاجتماعي إلى اعتبار الحريات العامة ليست مطلقة، فقد تدخلت الدولة للحد منها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، فالفرد لا يجب أن يتمتع إلا بالقدر من الحرية الذي تراه الجماعة. يوجد ارتباط وثيق بين الحرية والسلطة طبقاً للمذهب الاجتماعي، إلا إن الحرية ليس لها وجود مستقل عن كيان السلطة الاجتماعية التي تعيش في ظلها، وفي حالة التعارض تكون الأولوية للأخيرة. مفهوم الحرية في نظر هذا المذهب إنها ليست حقاً طبيعياً، وإنما هي منحة من الجماعة. فالجماعة هي المصدر الوحيد للخبرة الفردية، ولهذا لا يجوز للفرد من الحرية إلا القدر الذي تمنحه الجماعة، وهي لا تعطيه منها إلا القدر الذي يتفق وصالحها المشترك.

ب- أثر المذهب الاجتماعي في المجال الاقتصادي:

أدى اعتناق المذهب الاجتماعي إلى تدخل الدولة في كافة نواحي النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تملك الدولة لجميع وسائل الإنتاج، وتشجيع القطاع العام، والحد من المبادرة الفردية في المجال الاقتصادي إلى أقصى درجة ممكنة، وإحلال مبدأ الاقتصاد الموجه محل مبدأ الاقتصاد الحر. قد قام المذهب الاجتماعي على تحطيم حواجز الدولة الحارسة، التي فرضها عليها المذهب الفردي. فمدت الدولة نشاطها إلى ميادين النشاط الخاص، وتدخلت في تنظيم الإنتاج وتوجيهه، ووضعت أسس العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال، واعتنقت فكرة الاقتصاد الموجه. وتتفق المذاهب الاجتماعية على وجوب تدخل الدولة بالتنظيم القانوني للروابط الاجتماعية. فأساس المذهب إن إصلاح المجتمع يتطلب تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة المتزايدة والمتشابهة، لتهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي الملائم لممارسة الفعالية للحقوق والحريات.

ج- أثر المذهب الاجتماعي في المجال القانوني:

أدى تدخل الدولة في كافة المجالات، إلى تعظيم أثر القانون وتدخله في مختلف آفاق النشاط في الجماعة، فكثرت القواعد الآمرة، وتقلص مبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية، حيث تدخلت الدولة بقواعد آمرة لإقامة مساواة فعلية بين المتعاقدين، ولمنع تحكم فريق في آخر استناداً إلى قوة اقتصادية أو ظروف غير مواتية. فقد انعكس تصور المذهب الاجتماعي على وظيفة القانون في المجتمع، حيث ذهب إلى أن القانون له وظيفة اجتماعية تتمثل في توجيه نشاط الأفراد نحو غاية مشتركة هي الصالح العام للجماعة. ولذلك فإن تدخل الدولة يعتبر أمراً ضرورياً بغية تحقيق الوظيفة الاجتماعية للحقوق، حتى لا تخرج على المصلحة العامة. تحت دعوى حماية حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة الفعلية، اتخذت بعض الدول التي تبنت المذهب الاجتماعي، بعض الإجراءات ووضعت العديد من التشريعات التي تكفل سيطرتها على وسائل الإنتاج، مثل التأميم وتحديد حق ملكية الأراضي الزراعية. قد أدت فلسفة المذهب الاجتماعي إلى ظهور نوع جديد من المسؤولية المدنية، فنتيجة لزيادة المخاطر على الطبقة العاملة في المصانع، ظهر تحول على صعيد المسؤولية المدنية لمواجهة هذه المخاطر، فأقيمت المسؤولية على الخطأ المفترض، بدلاً من الخطأ الشخصي الذي قد يعجز المضرور عن إثباته. كما انعكس المذهب الاجتماعي على جوهر القانون وغايته، حيث تم التركيز على المعطيات الاجتماعية وإهمال ما عداها. في ظل المذهب الاجتماعي يسود نظام العدالة التوزيعية، وليس العدالة التبادلية التي تسود في ظل المذهب الفردي. والعدالة التوزيعية لا تقوم على فكرة المساواة المطلقة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، بل على أساس المساواة النسبية أو الواقعية، لأن المجتمع يتكون من أفراد مختلفي الظروف والقدرات، ولذلك فإن المبدأ الذي يحكم العلاقة بين الأفراد في ظل المذهب الاجتماعي هو مبدأ التدرج. ومن ثم تكون مهمة القانون تحديد واجبات الأفراد تجاه المجموع، وواجبات المجموع تجاههم. فالعدالة التوزيعية مصدرها السلطة، فهي تأتي من أعلى، أما العدالة التبادلية فتتحقق بطريقة تلقائية بين الأفراد عن طريق قانون السوق، ودور الدولة فيها دور سلمي يقتصر على الاعتراف بالقانون وتوقيع الجزاء. أما دورها في العدالة التوزيعية فهو دور إيجابي، لأنها هي التي تضع هذا النوع من العدالة موضع التنفيذ، باعتبارها طرف في الموضوع وصاحبة مصلحة.

ثالثاً: تقدير المذهب الاجتماعي:

- وجه أنصار المذهب الفردي إلى المذهب الاجتماعي عدة انتقادات، تتمثل في:
- أ- يثق المذهب الاجتماعي ثقة مطلقة في قدرة الدولة على الإشراف على كل مرافق الحياة، بيد أن التجارب أثبتت عجز الدولة عن القيام بتلك المهمة في كثير من الحالات. ومثال ذلك: عجز الدولة عن محاربة السوق السوداء، التي تظهر في أعقاب تدخل الدولة لتحديد الأسعار، دون مبالاة بقانون العرض والطلب.
 - ب- أدت النظريات الاجتماعية، وخاصة المتطرفة منها، إلى طغيان واستبداد السلطة الجماعية، سواء كانت الطبقة أو الدولة، مما أدى إلى قيام الشمولية والدكتاتورية، حيث يخضع الأفراد بشكل دائم للمجتمع الممثل في الدولة، التي تتمتع إزاءهم بجميع الحقوق. الأمر الذي أدى إلى زيادة قوة السلطة الحاكمة، على حساب المحكومين، فلا يوجد ضمان للمحكومين ضد تحكم الهيئة الحاكمة، التي تستطيع بمقتضى ما لديها من وسائل قانونية جبر الناس على قبول أوامرها.
 - ت- أدى المذهب الاجتماعي إلى اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين الناس، ولمحاولة الوصول إلى ذلك الهدف اتجهت نحو إلغاء الملكية الفردية، وانتقاص ما تحاط به من ضمانات في بعض المذاهب المتطرفة، أو تقييدها في بعض المذاهب المعتدلة.
 - ث- تطرف المذهب الاجتماعي في تقديس الجماعة، حيث إنه يضحى بمصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجماعة، ويسخره لخدمتها، إلى حد إهدار الحرية والملكية الفردية.
- عمدت كثير من الدول النامية إلى الأخذ ببعض أساليب المذهب الاجتماعي كوسيلة للتنمية الاقتصادية، دون الوقوع في مظالم اجتماعية.

القيم كفاية للقانون

- يُعد القانون أحد العلوم التقويمية، وليس من العلوم التفسيرية، ولذلك فإنه لا يعمل على إصدار أحكام للوجود مؤسسة على مبدأ السببية، ولكن أحكام للقيم مبنية على فكرة الغاية. ونتيجة لذلك، فالقيم تسيطر على القانون في مراحله المختلفة، حيث يؤسس القانون في نهاية المطاف على فلسفة القيم. إن الارتباط الذي يوجد بين القاعدة القانونية وقيمتها، هو الذي يجعل منها قاعدة منشئة للالتزامات.

س ٢: اكتب في مفهوم العدالة كفاية للقانون؟

العدالة كفاية للقانون

- إن العدالة هي روح القانون، والجزء المؤثر فيه، والذي يجب على الإنسان أن يعيه. كما إنها أحد الأسس التي تفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى.
- إذا كانت العدالة تمثل أساساً فضيلة أخلاقية، إلا أنها تعد أيضاً ضرورة قانونية لا غنى عنها لأي مجتمع. فالعدالة هي الضمان الأكيد لاستمرار العيش في جماعة، وعليها تقوم المعاملات والعلاقات بين الأفراد والجماعات، وهي التي ينشدها الجميع حاكمين أو محكومين، وبدونها ينقلب المجتمع إلى فوضى ويسود الاضطراب ويعم الظلم والجور. وتُعد العدالة بمثابة الحد الفاصل الذي يبين ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات، ومن هنا فإن العدالة تلتقي مع القانون باعتباره مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتضع المعايير الفاصلة. فبقدر ما تحقق القوانين العدالة وتقترب من المثل الأعلى يمكن الحكم على المجتمع بأنه متطور أو متقدم، وبقدر ما تبتعد القوانين عن العدالة بقدر ماتحكم على المجتمع بالتخلف والانحطاط. فالعدالة إذاً هي الهدف المنشود لكل مشرع، وهي الغاية التي يبغى الوصول إليها أو على الأقل الاقتراب منها - كل مجتمع. وبذلك تعتبر العدالة الغاية الأساسية التي يسعى القانون إلى تحقيقها.
- قد شغل موضوع العدالة منذ القديم ذهن الحكماء والفلاسفة.

قد كان فلاسفة الإغريق هم أول من تعرض لبحث فكرة العدالة، في محاولة للوصول إلى تحديد مضمونها والأساس الذي تقوم عليه، والعلاقة بينها وبين القوانين الوضعية المطبقة في الدولة.

فإذا رجعنا إلى المنابت الأولى، حيث طرحت فكرة العدالة على بساط البحث الفلسفي والتأمل العقلي، لوجدنا أن الإطار العام الذي يجمع بين آراء ومذاهب فلاسفة الإغريق هو أن للعدالة جانبين يرتبطان أحدهما بالآخر برابطة لا انفصام لها: الأول أخلاقي، ويأتي من النظر إلى العدالة على أنها فضيلة من فضائل النفس البشرية. والثاني قانوني، وينبع من كون الفرد عضواً في جماعة يرتبط بأفرادها بعلاقات وروابط مختلفة، وتوجد بينه وبينهم صلات ومعاملات متنوعة.

في نطاق فلسفة القانون، تعتبر العدالة الغاية الأساسية التي يسعى القانون إلى تحقيقها، فالارتباط جد وثيق بين العدالة والقانون. فالقاعدة القانونية غير العادلة لا تصلح أن تكون قاعدة قانونية، بل تعد من قبيل الأعمال المادية غير المشروعة. وبذلك تعتبر العدالة أحد الأهداف الأساسية للقانون، حيث لازمته منذ نشأته، بل إنها من وجهة نظر المدارس المثالية في الفكر القانوني هي الهدف الأساسي والأسمى للقانون. إذ أن أنصار هذا الاتجاه قد دأبوا على استخراج كل محتوى القانون من مبادئ العدالة، وأيضاً استنتاج صلاحيته نفسها.

إذا كان إجماع الفلاسفة والفقهاء قد انعقد على اعتبار قيمة العدالة غاية مثلى ينبغي على كل نظام قانوني أن يسعى إلى تحقيقها، إلا أن الاختلاف سرعان ما يظهر بينهم إذا تطرق الأمر إلى تحديد مفهوم العدالة. ويرجع ذلك إلى صعوبة تعريفها، لأنها من ناحية أولى تختلط بالأخلاق، باعتبار أنها في الأصل فكرة أخلاقية، ولأنها من ناحية ثانية فكرة غير ثابتة على مر العصور حيث تتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية السائدة في مجتمع معين في زمن معين.

أولاً: تعريف العدالة:

إن فكرة العدالة، على الرغم من بساطتها، لم يثبت مضمونها على حال واحدة، بل تقاذفتها الغايات المختلفة، وفلسفة الشرائع المتباينة، حيث بدأت فكرة تأمل فلسفية، ثم تحولت إلى فكرة قانونية كان لها تأثيرها في صياغة وتطبيق القواعد القانونية.

تُعد العدالة مطلباً إنسانياً لا يمكن التغاضي عنه، فالقانون غير العادل يُعد مجرد أمر واقع تنقصه المشروعية. فالعدالة هي القوة الدافعة، التي تدعو بإلحاح إلى أن يتسامى القانون، وتخضعه إلى القانون الطبيعي، أي للمثالية القانونية. فالعدالة هي ضمير القانون القلق، وكل ما لا ينسجم معها من قواعد ونصوص يجب استبعاده من نطاق القانون.

تعتبر المدرسة الفيثاغورية، والتي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد، هي أول مدرسة فكرية تتحدث عن العدالة كقيمة أساسية يجب على الدولة أن تلتزم بها. ورأى الفيثاغوريون أن العدالة هي المساواة أو المماثلة، فالعدل هو علاقة حسابية أو مساواة بين الأعداد، فالعدل هو أن ترد عدداً من الوحدات مساوياً لما أخذت، وتوقيع العقوبة على المجرم بقدر جرمه. ومن العدل أيضاً عندهم أن لا يملك أحد شيئاً خاصاً به، حيث أن كل شيء يجب أن يكون مشتركاً بين الأصدقاء، ليس الأموال المادية فحسب بل أيضاً الملكات النفسية وحسن البصر بالأمور، لأن الصداقة مساواة، ولأن جميع الناس إخوة وأصدقاء حيث أنهم جميعاً من سلالة الله.

قد استنبط سقراط من القواعد القانونية الجزئية التي تحكم علاقات الناس في المجتمع، أصلاً عاماً تصدر عنه تلك القواعد جميعها، ألا وهو فكرة العدل، الذي يقتضي نظام الكون أن يلتزمه الناس في علاقاتهم. فالعقل يملي على الناس التزام العدل في معاملاتهم، سواء وجدت قاعدة قانونية تقرر جزاء على مخالفة الحكم العادل أو لم توجد، كما ذهب سقراط إلى القول بوجود قواعد مثالية للعدل يدركها الإنسان بعقله وتكون أساساً عاماً لما عداها من قوانين، متبعاً بذلك المذهب العقلي المثالي في القانون.

قد ربط أفلاطون بين العدالة والدولة عند عرضه مفهوماً مثالياً للدولة، وذهب إلى أن العدل يبدو أوضح ما يكون في الدولة مشبهاً إياها بالإنسان الأكبر والوحدة الإنسانية الكاملة الصلبة. ورأى أفلاطون أن العدل في الفرد هو التعاون الفعال بين العناصر المختلفة التي تتكون منها طبيعة الإنسان، فكل إنسان عبارة عن عالم كامل من الرغبات والشهوات والأهواء والعواطف، فإذا توافقت هذه الظواهر النفسية وتعاونت أصبح صاحبها رجلاً حكيماً عادلاً، وإذا اختل التوازن بينها وسيطرت العاطفة على سائر القوى أو استبد العقل المجرد عليها، تصدعت أركان الشخصية ونال الفساد منها، فالعدل هو النظام والجمال في النفس. أما العدل لفى الدولة فهو قيام كل فرد بالعمل الذي يجيده وأن يأخذ منها بقدر ما يعطيها، فالرجل العادل هو الذي ينقل العدل إلى منصبه، فالدولة العادلة في نظر أفلاطون هي جماعة متوافقة ومتناسقة. ويمكن القول بأن العدالة في نظر أفلاطون سواء بالنسبة للدولة أو للفرد هي انسجام القوى المتعددة وتوافقها، فهي عبارة عن توافق بين الجزئيات في علاقتها بعضها ببعض وفي علاقتها بالوجود الكلي، وتستلزم من كل شخص أن يؤدي واجبه بغرض الخير المشترك.

رأى أرسطو أن مضمون القوانين يجب أن يكون العدل، وأن أساس العدل هو المساواة، وقد عمد أرسطو إلى تحليل فكرة العدالة تحليلاً دقيقاً، وانتهى من هذا التحليل إلى تقسيم العدالة إلى نوعين: العدالة بمعناها العام، وهي ذات صلة وثيقة بعلم الأخلاق، وعرفها بأنها: توافق وانسجام بين قوى النفس بواسطة العقل. والعدالة بمعناها الخاص، وهي جوهر القانون ومنبعه، وعرفها بأنها: إرادة دائبة لوضع كل إنسان في المركز المناسب وإعطاء كل ذي حق حقه. وقد قسم أرسطو العدالة بهذا المعنى إلى نوعين: النوع الأول عدالة القسمة أو التوزيع، وهي تخص علاقة الفرد بالمجتمع أو الدولة، أي تتصل بالحقوق العامة، وهي عبارة عن التناسب بين ما يقدمه الإنسان من عمل للمجتمع وما يحصل عليه من فوائد، فهي تحكم توزيع الثروات والمزايا على المواطنين وتقوم على أساس مساواة نسبية غير حسابية. والنوع الثاني العدالة التبادلية، وهي تتصل بالحقوق الخاصة، فهي عبارة عن التعادل بين التزامات وحقوق الأفراد في المعاملات المالية التي تحدث بينهم، فهي تحكم العلاقات والمعاملات بين أفراد المجتمع سواء كانت إرادية أو غير إرادية، وتقوم على أساس مساواة حسابية مطلقة.

رأت المدرسة الرواقية أن غاية الإنسان الحق والفضيلة، وأنه يجد سعادته في أداء الواجب، وعليه أن يتغلب على شهواته ويكبح جماحها ويحرر ذاته من المؤثرات الخارجية. ولأن الفرد لابد له من العيش مع الآخرين في مجتمع، فيجب عليه أن يقيم علاقاته معهم على أساس العدل والحب والتآخي. والعدل عندهم شامل، يمليه قانون طبيعي يحكم العالم بأسره، وينعكس في الضمير الإنساني. وقد فرق فلاسفة المذهب الرواقي بين نوعين من القوانين: القانون الوضعي، وهو القانون الذي تضعه كل جماعة ليطبق عليها. والقانون الطبيعي، الذي أوحى به الإرادة الإلهية إلى الإنسانية قاطبة، وهو يمتاز عن القانون الوضعي بأنه أقدم عهداً وأسمى منزلة وبأنه عام وشامل وخالد على مر الزمن. وقد نجم عن ذلك التفرقة بين نوعين من العدل: العدل الطبيعي، وهو العدل المطلق، وقد صنعتها الطبيعة للبشر جميعاً. والعدل التشريعي، وهو عدل القوانين التي تضعها كل جماعة على حدة. وقد اتجهت هذه المدرسة اتجاهاً فردياً إنسانياً، ونادت بخضوع الإنسان لقانون الطبيعة وحده، وهو القانون الذي ينعكس على الضمير الفردي ويتميز بطابع العالمية. ووفق منطق هذه المدرسة فإنه يجب أن تنهار الحواجز بين الدول لصالح الدولة العالمية، ويجب أن تظهر قواعد جديدة للأخلاق تتأسس على وحدة الطبيعة الإنسانية وفقاً لقانون العقل، ولذلك رأت هذه المدرسة أن الإنسان الحكيم هو الذي يكبح جماح شهواته ويتحرر من كافة المؤثرات ويهتدي إلى مبادئ العقل العليا أو مبادئ القانون الطبيعي. وقانون الطبيعة لا يخضع له الفرد وحده، وإنما تخضع له الدولة أيضاً، وإذا حدث وتمت المواجهة بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي، كانت الغلبة بلا منازع إلى سيادة القانون الطبيعي. وذلك مثلت تلك المدرسة ذروة الاتجاه المثالي في الحضارة اليونانية الذي ينادي بوجود قانون طبيعي يجب أن نستلهم منه أحكام القانون الوضعي، ونجد فيه اهتماماً بقواعد قانونية تنبع من العقل وتسمو على غيرها من القوانين الوضعية، ولذلك نادوا بعدم التدخل في شئون الفرد والمساواة بين سائر البشر وإلغاء الرق والفوارق الاجتماعية بين الناس في كل الدول.

ذهب الإبيقوريون إلى عدّ الفضيلة وسيلة للوصول وإلى سعادة الإنسان وليس الغاية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها. حيث رأى إبيقور أن اللذة خير والألم شر، وإن اللذة العقلية خير من اللذة الجسمية، لأن الجسم لا يحس إلا باللذة الحاضرة، أما العقل فيستطيع أن يتلذذ بذكرى ماضية ويأمل في لذة مستقبلية. أي أن اللذة عنده لم تكن الانغماس في الملذات الحسية، بل هي تثقيف العقل وممارسة الفضيلة. ورأى أيضاً أن على الإنسان أن يعتدل في كل شيء، وأن يعيش ببساطة، حيث أن الفضيلة تكمن في الاعتدال، لأن الإسراف في أي شيء يعود على صاحبه بالألم والشر. أما القناعة عنده فقد اعتبرها أكبر الفضائل قدرة على ضمان اللذة. ورأى الإبيقوريون أن العدل فضيلة يحصل الإنسان بممارستها على لذة كبرى، هي الطمأنينة وتأمين الإنسان نفسه وماله من اعتداء الغير. وتقوم هذه الفضيلة على عدم الإضرار بالغير، لأن الإضرار يعتبر مخالفة لفضيلة العدل. إذ أن العدل يكمن في اتفاق الناس على عدم الإضرار ببعضهم البعض، والإضرار هو نقض لذلك الاتفاق الصريح أو الضمني الذي بدونه لا يكون لفكرة العدل وجود. وطبقاً لأرائهم ليس في الطبيعة عدل أو ظلم، وإنما فيها لذة وألم فقط. وهكذا نرى أن مذهب الإبيقوريين ينادي باحترام القوانين الوضعية، لما في ذلك من فائدة تتحقق عن طريق مساواة الجميع أمام تلك القوانين وممارسة الجميع لفضيلة العدل.

هذه هي أهم الآراء والمذاهب الفلسفية الإغريقية التي تناولت فكرة العدالة بالبحث والتحليل.

يكاد ينعقد الإجماع بين الباحثين على أن الفضل الأكبر في ترجمة مفهوم العدالة في صوغها القانوني في روما يرجع إلى شيشيرون، الذي ساهم بجهد كبير في نشر الفلسفة اليونانية عند الرومان، إذ أنه قد هضم كافة الأفكار والمدارس الفلسفية اليونانية ثم قام بعرضها بصياغة سهلة واضحة مما يسر وصولها إلى أذهان المخاطبين. ولهذا السبب يقول بعض المعاصرين: إن شيشيرون كان القنطرة التي عبرت عليها الفلسفة اليونانية إلى روما.

قد عرف شيشيرون العدالة بأنها: إعطاء كل ذي حق حقه دون المساس بالصالح العام. فقد ذهب شيشيرون تأثراً بالفلسفة الرواقية إلى وجود قانون طبيعي، حيث يستفاد ذلك من قوله: إن هناك قانون عادل هو العقل القويم المطابق للعقل الحقيقي موجود فينا وذو أساس إلهي، ولا يمكن اقتراح هذا القانون أو إبطاله، وهو لا يختلف في روما أو أثينا أو اليوم أو غداً، لأنه قانون واحد ثابت لكل الشعوب وموافق لكل الأزمان، وأن الله هو صانع هذا القانون وهو الذي قدره وأعلنه. فالعدل عند شيشيرون يتجسد في القانون الطبيعي، بحيث ذهب إلى أنه ليس كل ما يوصف بأنه قانون يكون عادلاً بالضرورة، فالقانون لا يمكن أن يبني على مجرد الرأي أو الفكرة، وإنما هناك عدالة طبيعية وضرورية يؤكدها وجود وعي الإنسان ذاته. وأقام شيشيرون الدولة على أساس العدل التوزيعي، فهو ينادي بتوزيع المناصب والحقوق بين مواطني الدولة كل بحسب جدارته وكفاءته، فكل شخص يجب أن يكون في المكان اللائق له. أما العدل التبادلي فجعله مدار العلاقات والتصرفات بين الأفراد، وبذلك تتحقق المساواة بين الناس وإقامة التعادل بين ما يأخذون وما يعطون وذلك هو العدل.

قد عرف الإمبراطور الروماني جوستنيان العدالة ← إعطاء كل شخص ما يستحقه. والعدل عند جوستنيان يتجسد في القانون الطبيعي، وهذا ما عبر عنه صراحة بقوله: إن الأنظمة القانونية لا يمكن أن تهدر الحقوق المستمدة من الطبيعة، ولذلك فعندما يقع التنازع بين نصوص القانون الوضعي ومبادئ القانون الطبيعي، فإن الاختيار يكون دائماً في صالح الأخير.

القانون الطبيعي عند جوستنيان قانون مطلق وأساسي، وواحد في كل زمان ومكان، وسابق في الوجود على جميع التشريعات الوضعية ذات المصدر البشري، كما أنه يتصف بالكمال والسمو، فهو يُعدّ أسمى القوانين، وهو دائماً وباستمرار خيراً وعدلاً حيث يتضمن مبادئ العدل العليا.

قد عرف آباء الكنيسة العدالة تعريفاً يكاد يتطابق مع تعريف الفلاسفة الإغريق لها، بيد أنهم يختلفون عنهم في أن الإغريق يردون فكرة العدالة إلى الطبيعة، بينما يردوها آباء الكنيسة إلى الله، فهو الذي وهبها للناس منذ خلقهم، وتطبيق الناس لها مرده خشية الله.

قد عرف القديس توما الإكويني العدالة بأنها: عادة بمقتضاها يعطي المرء كل واحد ما هو مستحق له بإرادة دائبة ومستمرة.

✎ **عرف الفقيه الفرنسي فرانسوا جيني العدالة** ← التناسب الذي يجب أن يكون بين المصالح المتعارضة، بهدف تحقيق النظام اللازم لبقاء الجماعة الإنسانية والنهوض بها. وعند تحديد مفهوم فكرة العدل، رأى جيني أن أوضح ما قيل في تحديد ماهيتها هو نظرية أرسطو في التفرقة بين العدل التبادلي والعدل التوزيعي والعدل الاجتماعي. وبذلك يمكن إدراك معنى العدل، فهو الفكرة الكفيلة وحدها بإرساء دعائم النظام والأمن في الحياة الاجتماعية.

✎ من جماع التعريفات السابقة للعدالة، يمكن القول بأن العدالة هي: شعور كامن في النفس، يكشف عنه العقل السليم، ويوحي به الضمير المستنير، ويهدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون الجور على حقوق الآخرين. كما يتضح أن جوهر العدالة هو حصول كل إنسان على حقه، كما أنها وسيلة لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة من خلال إعطاء كل شخص حقه.

ثانياً: المفاهيم المختلفة للعدالة:

✎ تعددت مفاهيم العدالة حسب الوجهة التي يُنظر بها إليها، فمن ناحية لها مفهوم مطلق ومفهوم نسبي، ومن ناحية أخرى لها مفهوم عام ومفهوم خاص.

أ- المفهوم المطلق والمفهوم النسبي للعدالة:

✎ العدالة بالنسبة للبعض، لها مفهوم مطلق لا يتغير باختلاف الزمان أو المكان، فهي قيمة عليا تشمل جميع القيم. وبالنسبة للبعض الآخر، فإن للعدالة مفهوم نسبي يختلف من مجتمع إلى آخر، بل يختلف من طائفة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد.

✎ بالنسبة للفريق الأول، فإن الأمر يتعلق بالعدالة المبنية على بعض المسلمات القانونية غير القابلة للتبديل أو التغيير، بغض النظر عما تحدثه التقلبات الاجتماعية من تغيير المفاهيم في أذهان الناس. أما بالنسبة للفريق الثاني، فإن الأمر يتعلق بالعدالة التي تعمل الدولة على تحقيقها. أي العدالة منظوراً إليها في مجتمع معين وفي زمن محدد. وباختصار، فإن العدالة بالنسبة للبعض مثل القانون باعتبارها نتاج المجتمع بما فيه من ظروف مختلفة، وبالنسبة للبعض الآخر مثل أعلى محفور في النفس البشرية لا يمحو ولا يتبدل حيث أنها قيمة روحية.

✎ في الواقع، إن الرأي الذي ينظر إلى العدالة باعتبارها قيمة اجتماعية، وبالتالي ذات مفهوم نسبي، هو الاتجاه الغالب. حيث يؤيده الواقع التاريخي من ناحية، وتقلب آراء الفلاسفة من ناحية أخرى.

ب- المفهوم العام والمفهوم الخاص للعدالة:

✎ يعتبر الفيلسوف أرسطو أول من تناول فكرة العدالة بالدراسة الوافية، وقد لاقت نظريته عن العدالة العديد من التحليلات، وكانت وما زالت مناط الاهتمام في بحوث فلسفة القانون والسياسة. كما إن نظريته في العدالة قد نفذت إلى القانون الوضعي على أثر تبني الرومان لها، وتأسيس بعض المسائل في نظرية الالتزام عليها، ومن القانون الروماني انتقلت إلى القوانين الحديثة. وقد ميز أرسطو بين العدالة بالمفهوم العام والعدالة بالمفهوم الخاص. ومن الجدير بالذكر، إن هذه التفرقة كان لها أثرها الواضح، ولمدة طويلة، على الفكر القانوني في أوروبا، وذلك للارتباط الوثيق بين القانون والأخلاق.

✎ فالعدالة بالمفهوم العام فضيلة أخلاقية، ولذلك قبل إن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة، حيث يقترن كل منهما بالآخر، ومهمة القاضي هي تحقيق العدالة من خلال تطبيقه للقانون.

✎ **العدالة بالمفهوم الخاص** ← فضيلة محددة، تفيد إعطاء كل شخص حقه أو ما هو واجب له. والعدالة بهذا المعنى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة المساواة، فهي تقيد معنى المساواة والتناسب، فالقانون يكون عادلاً إذا كان يعطي لكل شخص حقه وفقاً لمبدأ المساواة والتناسب، وعلى العكس يكون القانون ظالماً إذا لم يراع المساواة والتناسب عند مخاطبة الأفراد أثناء تنظيمه لسلوكهم.

ثالثاً: أركان العدالة:

- تقوم العدالة على ركنين أساسيين، هما: (المساواة و العمومية).
- فقد أجمع كل من نادوا باعتبار العدالة الغاية المثالية للقانون، على اعتبار أن
- الركن الأول :-** المساواة هي العنصر الأساسي أو الركن الجوهري للعدالة، حتى شاع في هذا الصدد أن المساواة هي روح العدالة. فإذا لم تحترم المساواة فلن يكون للعدالة وجود على الإطلاق،
- المقصود بالمساواة** ← التعبير الواقعي عن الفكرة المجردة للعدالة .
- الركن الثاني :-** للعدالة هو العمومية
- المقصود بالعمومية** ← تعني أولاً أن المساواة التي تُعد جوهر العدالة لا تكون مساواة للبعض فقط، بل مساواة للجميع. فإذا كان كل الناس متساوون، فإن كل فرد يمكنه طلب الحصول على جزء من الخبرات التي يحتفظ البعض بها لأنفسهم. فالمساواة التي وجد بين أعضاء الجماعة، لا تكون عادلة إلا إذا راعت مساواة الأفراد الآخرين، حتى وإن كانوا يختلفون في الجنس أو في الديانة. فالقاعدة لا تكون قاعدة ما لم تطبق بشكل عام على جميع الأشخاص أو الحالات التي تنضوي تحت حكمها، وبناءً على ذلك فالمساواة واجبة بين جميع من هم في مراكز متماثلة دون تفرقة بينهم لسبب يتعلق بأشخاصهم أو ذواتهم، وهذه هي المساواة النسبية التي تكتفي بالعمومية النسبية لقواعده. فنصوص القوانين التي لا تتوافر شروطها إلا على طائفة محدودة أو على شخص واحد غير معين، لا تنافي مبدأ المساواة القانونية النسبية طالما أن الفرص متاحة للجميع.

رابعاً: تقسيمات العدالة:

- تنقسم العدالة إلى أربعة أنواع، هي: (العدالة الشكلية، العدالة التوزيعية، العدالة التبادلية، والعدالة التكميلية أو الاجتماعية).

أ-العدالة الشكلية:

- المقصود بالعدالة الشكلية** ← المساواة في المعاملة وفقاً للتصنيف الذي أعده القانون. فالقانون يجب أن يطبق بالتساوي في جميع الحالات، وعلى جميع الأشخاص دون تفرقة بينهم. وطبقاً لهذا المفهوم، يقتصر دور القاضي على تطبيق القواعد نفسها على المراكز القانونية ذاتها. فالعدالة هنا عدالة وضعية، تعني التزام القاضي بتطبيق القانون حرفياً، حتى يكون حكمه عادلاً، ومعاملة الحالات المتماثلة معاملة واحدة.
- يتحدد مضمون العدالة الشكلية في **ثلاث عناصر جوهرية**،
- يتمثل العنصر الأول في** ← وجود قواعد محددة سلفاً، توضح كيفية معاملة الأفراد في الحالات المطروحة، أي وجود قواعد تطبق على الحالات المتماثلة.
- العنصر الثاني يتمثل في** ← أن تكون القواعد عامة التطبيق، بمعنى أن تطبق إما على الأشخاص بشكل عام، أو على فئات معينة من الناس يتم تحديدها، أي لا يتم تطبيقها على الأفراد بشكل عشوائي.
- العنصر الثالث، فيتمثل في** ← التطبيق التزيه للقواعد القانونية بطريقة موضوعية دون محاباة أو تحيز.
- قد ذهب جانب من الفقهاء إلى أن المشكلة في هذا المعيار إنه يؤدي إلى نسبية العدالة، حيث يجعلها تختلف باختلاف النظم القانونية، فما يُعد عادلاً في وقت ما، ومكان ما، قد لا يكون كذلك في وقت آخر وفي مكان مختلف. كما يترتب على هذا المعيار الشكلي للعدالة، إن كل تغيير في القنن يؤدي إلى تغيير في مضمون فكرة العدالة. كما إن هذا المعيار يُعطي تصوراً جامداً لفكرة العدالة، فالعدالة طبقاً للقانون عدالة جامدة، لأنها تُبنى في المقام الأول على متطلبات النظام القانوني القائم، والذي يهدف بصفة أساسية إلى حفظ النظام في المجتمع .

ب-العدالة التوزيعية:

المقصود بالعدالة التوزيعية ← العدالة التي تسود في علاقة الدولة بمواطنيها، بشأن توزيع الأعباء والحقوق، والتي يجب بمقتضاها أن يتم توزيع الحقوق والأعباء على المواطنين على أساس المساواة التناسبية. حيث يجب أن تراعي الدولة، وهي بصدد توزيع الأعباء والحقوق على المواطنين، الاختلاف المحتوم بينهم في الحاجات والقدرات والعمل.

تقوم العدالة التوزيعية على أساس المساواة التناسبية، وليس على أساس المساواة الحسابية كما هو الشأن في العدالة الشكلية. فهي مساواة في القيم تضع كل فرد في المكان العادل حسب حاجته أو قدرته، مما يسوي بين الأفراد المتساوين في الحاجة أو القدرة أو الكفاءة.

العدالة التوزيعية تجد مجالاً واسعاً لها في نطاق توزيع الضرائب وشغل الوظائف. فلا توجد مساواة حسابية في فرض الضرائب، وإنما يوجد تناسب بين ما يحصل عليه الفرد من دخل وما يُفرض عليه من ضرائب، وهو ما يُطلق عليه الضرائب التصاعدية. كما أن الوظائف لا يشغلها إلا من تتوافر فيه شروط شغلها، من كفاءة وجدارة، وغيرها من الشروط.

ج-العدالة التبادلية:

المقصود بالعدالة التبادلية ← العدالة التي تسيطر على العلاقات التي يجري بشأنها تبادل فيما بين الأفراد فهي العدالة التي تسود علاقات الأفراد، سواء اكنت هذه العلاقات إرادية كالعقد، أو غير إرادية كالعمل غير المشروع.

تقوم العدالة التبادلية على مبدأ المساواة الحسابية المطلقة، بغض النظر عن صفات الأفراد واختلاف شخصياتهم، حيث يجب أن يحصل الشخص على المقابل الحسابي للشيء الذي تم تبادله. وإذا تسبب شخص بخطئه في الإضرار بغيره، فإن مقتضى العدالة التبادلية أن يلتزم المخطئ بإصلاح الضرر الذي أصاب المضرور، وأن يكون التعويض مساوياً للضرر.

مما لاشك فيه، إنه يوجد ارتباط وثيق بين العدالة التبادلية والعدالة التوزيعية. حيث إن العدالة التبادلية تكمل العدالة التوزيعية. فالعدالة التبادلية تنظم الأوضاع التي تترتب على العلاقات القائمة بين الأفراد في المجتمع، ولا تظهر فائدة العدالة التبادلية إلا بعد تحقق العدالة التوزيعية، حيث تقوم بالمحافظة على التوزيع الذي تم طبقاً لقواعد العدالة التوزيعية. ومن ثم فإن أي خلل في الذمم المالية، يكون موضوعه التوزيع الذي تم طبقاً لقواعد العدالة التوزيعية، يتم عن طريق العدالة التبادلية.

د-العدالة التكليفية أو الاجتماعية:

المقصود بالعدالة التكليفية أو الاجتماعية ← العدالة التي تسود علاقات الأفراد بالجماعة، ولكن من حيث وجوبه على الأفراد للجماعة. فالجماعة في الواقع هي جسم واحد أعضاؤه الأفراد ولا يمكن لجسم أن يعيش إلا بنشاط كل عضو من أعضائه النشاط الواجب، وهذا النشاط الواجب هو النشاط الذي يسهم به كل عضو في بعث الحركة والحياة في الجسم.

أساس العدالة الاجتماعية إذاً هو اعتبار الفرد جزءاً من كل الجماعة لا اعتباره كلاً قائماً بذاته، ومن هنا كان هدف العدالة تسخير الجزء لخدمة الكل، أي تسخير الفرد لخدمة الجماعة بقصد تحقيق الخير أو الصالح العام.

المقصود بالصالح العام ← صالح الجماعة ككل، بمعنى صالح مجموع الأفراد كمجموعة مستقلة منفصلة عن آحاد مكوניה. وصالح مجموع الأفراد كوحدة مستقلة إنما يتولد من الاشتراك بين أفراد هذا المجموع في غاية واحدة، فهو إذاً صالح مشترك بينهم أو صالحهم ككل، بغض النظر عما لكل منهم كأفراد من صالح خاص.

المقصود بالعدالة الاجتماعية ← الأساس المبرر للسلطة في الجماعة، تلك السلطة التي يقوم عليها نظام المجتمع. فباسم هذه العدالة وتحقيقاً للصالح العام، يخضع الأفراد لسلطة الحكام، ويملك الحاكم على الأفراد حق السيادة أو الأمر دون معقب. وباسم هذه العدالة كذلك، يلتزم الحكام بتسخير سلطاتهم لتحقيق الصالح العام وحده، فتقيد هذه السلطات بحدود هذا الصالح لا تعدوه إلى غيره من المصالح.

تعريف آخر للعدالة الاجتماعية ← التي تبرر مطالبة الفرد بأداء ضريبة الدم والتضحية بحياته في سبيل صالح المجموع، وهي التي تلزمه بالمساهمة في تدعيم كيان الجماعة بأداء ما يقتضيه الصالح العام من ضرائب مالية.

س ٣: اكتب في ماهية الأمن القومي مبيناً وسائل تحقيق الأمن القانوني؟

الأمن القانوني

إن الأمن القانوني، أو الاستقرار القانوني كما يطلق عليه البعض، هو الغاية الأولى للقانون، والقيمة الاجتماعية التي يسعى النظام القانوني، أو يجب أن يسعى، إلى تحقيقها، وذلك من وجهة نظر المدارس الشكلية للقانون. على عكس المذاهب المثالية، التي ركزت على قيمة العدالة، باعتبارها الغاية المثالية للقانون.

أولاً: ماهية الأمن القانوني:

المقصود بالأمن القانوني ← أن تكون القواعد القانونية مؤكدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية، وأن تضمن تأمين النتائج، بحيث يستطيع كل فرد أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها. وهكذا يستطيع كل فرد أن يتوقع مقدماً نتائج تصرفاته، من حيث ماله وما عليه. فالأمن القانوني يؤدي إلى إمكانية توقع الأفراد لنتائج أفعالهم سلفاً. ومن هنا تأتي الأهمية المعطاة للمصادر الرسمية للقانون، والتي تسمح دون أي لبس بمعرفة القواعد واجبة التطبيق، وأفضلية التشريع على غيره من مصادر القانون، بسبب سماته المحددة والأكيدة.

إن الأمن القانوني يُعد عنصراً من العناصر الأساسية في مفهوم القانون ذاته، ذلك أن القانون قاعدة اجتماعية تعمل على حماية قيم مجتمع منظم، والحاجة إلى الأمن والنظام والاستقرار هو خصيصة لصيقة بمفهوم القانون ذاته. فلا وجود للقانون إلا على أساس نظام اجتماعي موثوق به وغير مضطرب أو مثير للاضطراب، وبغير هذا لا يمكن للنظام القانوني أن يحقق الهدف الذي وُضع من أجله. ذلك أن الأمن القانوني يلبي الحاجة إلى أن يعرف كل فرد ماله وما عليه في الحياة الاجتماعية.

تعمل كافة النظم القانونية الوضعية، على بلوغ قيمة الأمن والاستقرار القانوني، لما تحققه من نتائج بالغة الأهمية في البناء القانوني بأكمله، والتي تتمثل في:

- ١- تحقيق التوازن في المراكز القانونية والاجتماعية داخل المجتمع، بما يحقق النظام واليقين وحسن التنظيم للروابط القانونية والعلاقات الاجتماعية.
- ٢- حماية المجتمع من الأحكام الجائرة وغير المتوقعة، والتي تؤدي إلى حدوث اضطرابات في مجريات الحياة.

- ٣- تحقيق صفة الكفاية للقاعدة القانونية، بما يجعلها قادرة على مسايرة التطورات السريعة في المجتمعات الحديثة، لما يتسم به المبدأ من مرونة، وبما يضمن حقوق الأفراد وحماية مصالحهم.

ثانياً: العلاقة بين قيمة الأمن القانوني وقيمة العدالة:

إن العلاقة بين الأمن القانوني والعدالة، تحكمها في القانون الوضعي أصل واستثناءات. أصل توجده العلاقة الوثيقة فيما بينهما، واستثناءات يوجدها الواقع العملي، الذي يحتاج في بعض الأحوال النادرة إلى الترويج بين الاستقرار والعدالة، فيُغلب الاستقرار على العدالة، تحقيقاً لمصلحة أولى بالرعاية كالمصلحة العامة.

فيما يتعلق بالأصل، أو القاعدة، فمن الثابت في الفكر القانوني عدم وجود تعارض بين مبدأ الأمن القانوني وقيمة العدالة، فبتضافرهما معاً تتحقق أهداف القانون، ويحتاج القانون إليهما لتحقيق كافة غاياته، لأن الأمن غير العادل لا قيمة له، ويصطدم مع دولة القانون، كما إن العدالة غير الآمنة وغير المستقرة تُعد عدالة ناقصة.

❁ فيما يتعلق بالاستثناءات، فإذا حدث تعارض بين قيمة العدالة وقيمة الأمن القانوني، فالسائد بين القوانين الوضعية والفقهاء هو تغليب المذهب الشكلي على المذهب المثالي، أي تغليب متطلبات الأمن القانوني على متطلبات العدالة. والمثال التشريعي على ذلك، التقادم المكسب، الذي يؤدي إلى حرمان المالك من ملكه، على غير علم منه، مما يظهر التقادم في صورة غصب، لأنه يؤدي إلى اكتساب ملكية شيء مملوك للغير بدون إرادته، وهذا بلاشك يتنافى مع مقتضيات العدالة، إلا أن المشرع قد غلب مقتضيات الأمن القانوني، باعتبار أن التقادم يؤدي إلى استقرار الحقوق، وخاصة حق الملكية، إذ لا يجب أن يظل عرضة للشك ومجهول المصير، وأن الاعتراف لواضع اليد، الذي استمر وازعاً يده المدة القانونية، يُعد حماية للأوضاع الظاهرة، حتى لا تظل المراكز القانونية مزعزعة لأجل غير مسمى.

❁ المثال الفقهي فيتمثل في: الغبن، حيث ثار الخلاف بين الفقهاء حول تأثير الغبن على صحة العقد. حيث ذهب جانب من الفقهاء إلى أن العدالة التي تقضي بضرورة تعادل التزامات الطرفين، تقضي بضرورة أن يكون الغبن من أسباب إبطال العقود. إلا أن أغلبية الفقهاء ذهبوا إلى تغليب مقتضيات الأمن والاستقرار القانوني على اعتبارات العدالة، حيث رأوا إن إبطال العقد بسبب الغبن سوف يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات. وقد أسفر هذا الجدل الفقهي، إلى عدم إبطال العقود بسبب الغبن إلا في أضيق الحدود. وهذا الاتجاه هو الذي تبناه القانون المدني المصري في المادة ١٢٩، إذ آثر المشرع المصري اعتبارات الأمن القانوني على اعتبارات العدالة.

ثالثاً: مقومات الأمن القانوني:

❁ يقتضي تحقيق الأمن القانوني توافر عدة مقومات، تتمثل في:-

١- **المقاومة الأولى** ← دقة ووضوح الصياغة التشريعية المنظمة لعلاقات الأفراد داخل المجتمع، حيث أن الصياغة الجيدة تُعد من أهم ضمانات حسن تطبيق النص القانوني، وبقدر ما تكون الصياغة منضبطة وسليمة، بقدر ماتكون القاعدة القانونية أقدر على تحقيق الأهداف التي تنشدها السياسة القانونية، ومن بينها تحقيق الأمن القانوني. ونجاح القاعدة القانونية يتوقف جانب كبير منه على الدقة في الصياغة وتخير أدواتها. ويتحقق ذلك من خلال عدة أمور، أهمها: استخدام مناهج وأساليب في الصياغة يكون باستطاعتها احتواء كافة الوقائع في مجال القواعد القانونية، واستخدام لغة قانونية واضحة وصحيحة قادرة على احتواء الوقائع العلمية التي يقوم البناء القانوني على أساسها. فالصياغة الجيدة تساعد على إنزال أحكام التشريع بعدالة وموضوعية.

❁ كان منطوق تطور الظروف الاجتماعية يفرز أموراً لم تعالجها النصوص القانونية القائمة، فإن وجود ثغرات في القواعد القانونية القائمة أمر محتمل، ويجب على المشرع التصدي لهذه الثغرات، تحقيقاً لمبدأ الأمن القانوني. وقد تصدت كافة التشريعات الحديثة لهذه المشكلة، وانقسمت إلى اتجاهين: الاتجاه الأول، يعطي للقاضي سلطة تكملة النقص في التشريع كما لو كان مشرعاً. والاتجاه الثاني، أدخل مصدراً مرناً للقانون هو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، واعتبره من المصادر الاحتياطية التي يلتزم القاضي الالتجاء إليها إذا لم يجد حلاً للنزاع في القواعد القانونية القائمة.

❁ أياً كان الاتجاه الذي حداه المشرعين، في حل مشكلة النقص في التشريع، فقد كان القصد منه تحقيق الأمن القانوني.

٢- المقاومة الثانية ← اقتران القاعدة القانونية بجزاء فعال، حيث إن الأمن القانوني لا يمكن تحقيقه دون استعمال الإجبار. فمما لا شك فيه، إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وإذا كان الاجتماع الإنساني ظاهرة حتمية، فإذا القانون أيضاً ظاهرة حتمية تلازمه وتواكبه، حيث يقوم بمهمة أساسية تتمثل في ضبط العلاقات والروابط وتحديد الحقوق والواجبات، ويضع جزاء على مخالفة قواعده. ويُقصد بالجزاء العقوبة الملائمة التي توقعها السلطة المختصة، على المخالف لأحكام القانون. ويجب توافر عنصر الجزاء في القاعدة القانونية، حتى يلتزم أفراد المجتمع بتلك القواعد طواعية أو جبراً، وبذلك يتحقق الأمن القانوني في المجتمع. وبناءً على ذلك، فإن أنصار المذهب الشكلي يعتبرون التشريع هو المصدر الوحيد للقانون لاقتترانه بالجزاء الذي توقعه السلطة العامة. فالجزاء الاجتماعي طبقاً لأنصار هذا الاتجاه، هو سبب الالتزام، لأنه لا يوجد أي التزام ناتج عن الضمير أو القانون الطبيعي، ولا يوجد أي قانون يمكن إدراكه سوى القانون الوضعي، الذي هو قانون الدولة. فالنظام القانوني هو قبل كل شيء نظام شرعي، لا قيمة له إلا إذا صدر من السلطة المختصة.

٣- المقاومة الثالثة ← غياب التعسف التشريعي والإداري والقضائي، حيث أن الأمن القانوني يجب أن يتحقق في إطار من المشروعية، فالحفاظ على الأمن القانوني يجب أن يتم في إطار الالتزام بالقانون. مقتضى هذا الالتزام، في النطاق التشريعي، هو عدم سريان القانون على الماضي، فالقانون لا يحكم الوقائع التي تمت قبل نفاذه، فهو لا يملك النظر فيما تم في ظل القانون القديم من تكون أو انقضاء مركز قانوني، أو من ترتيب آثار معينة على مركز قانوني. فالأثر المباشر للتشريع، يُسهم في تحقيق الأمن القانوني داخل المجتمع، لما يُشيعه من الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع، إذ يكفل لهم أن القوانين الجديدة لن تنال من مراكزهم القانونية المستقرة، وأن القانون سيظل منظماً لمراكزهم القانونية التي تشكلت خلال سريانه في نطاقه الزمني. أما تطبيق القانون بأثر رجعي، فإنه ينال من ثقة الأفراد في القانون، ويشير القلق في نفوسهم، إذ ستكون تصرفاتهم الصحيحة وأفعالهم المباحة عرضة لأن تصبح يوماً ما باطلة أو مُجرمة. مقتضى هذا الالتزام أيضاً، في النطاق الإداري، احترام الدولة وأجهزتها للقانون، وعدم التمييز في المعاملة بين الأفراد. فإذا تحللت الدولة وأجهزتها من التزاماتها القانونية، ولم تقم بفرض احترام القانون على الأفراد، انهارت سيادة القانون.

مقتضى هذا الالتزام أيضاً، في النطاق القضائي، عدم جواز الامتناع عن تطبيق القانون بدافع الشفقة أو الاعتبارات الشخصية، أو إبداء القاضي رأيه في التشريع. فإعلاء قيمة الأمن القانوني، يقضي بحصر السلطة التقديرية للقاضي في أضيق الحدود، وإحاطتها بالعديد من الضمانات القانونية. ويجب على القاضي الالتزام بالنصوص القانونية، طالما كانت واضحة، حيث لا يجوز له إهمالها بادعاء مراعاة اعتبارات العدالة، لأن ذلك يحدث خللاً في المراكز القانونية، ويتنافى مع قيمة الأمن القانوني. كما يجب على القاضي الالتزام بتطبيق النصوص القانونية، طالما صدرت عن السلطة المختصة، ولا يجوز له الامتناع عن تطبيقها بحجة إنها أصبحت لا تطابق الواقع، حيث إن النصوص تظل لها قوتها الملزمة حتى ولو أهدمت تطبيقها أو تغيرت الظروف التي كانت وراء صدورها، ولا يتم إلغاؤها إلا بتشريع آخر.

رابعاً: وسائل تحقيق الأمن القانوني:

لجأت الأنظمة القانونية الوضعية إلى العديد من الوسائل لتحقيق الأمن القانوني، وهذه الوسائل بعضها يتعلق بتكوين القاعدة القانونية ذاتها، وبعضها الآخر يتعلق بالنظم القانونية ذاتها.

أ- الوسائل المتعلقة بتكوين القاعدة القانونية:

يستخدم المشرع، في سبيل تحقيق الأمن القانوني، عدد من الوسائل التي ترتبط بجوهر تكوين القاعدة القانونية ذاتها، ومن أهم هذه الوسائل:

١- اعتبار التشريع المصدر الأول للقانون:

يعتبر التشريع الوسيلة الأولى لتحقيق الأمن القانوني، حيث إنه الوسيلة التي تمكن الدولة من التعبير عن إرادتها تعبيراً دقيقاً من خلال الصياغة المنضبطة الواضحة، مما يؤدي إلى تجنب الغموض والتناقض الذي قد يثور عند تطبيقه. كما يتمتع التشريع بصفة اليقين، حيث يصدر في شكل وثيقة رسمية مكتوبة، فيجعل من السهولة بمكان إثبات القاعدة القانونية، وتاريخ بدأ سريانها، مما يكفل للقانون التجديد والثبات اللازمين لتحقيق الأمن القانوني.

٢- استخدام منهج الصياغة الجامدة:

المقصود بالصياغة الجامدة ← صياغة المبدأ القانوني في إطار معيار جامد يواجه حالة معينة، ويحدد لها حلاً واحداً، لا يتغير ولا يتأثر بالظروف الخاصة بكل حالة فردية. والصياغة الجامدة هي صياغة كمية وليست كيفية، حيث يُقصد بها التعبير عن القيمة التي تحملها القاعدة في العمل، ويحول دون الخلاف على ما يخضع لها من فروض. ويلجأ المشرع إلى استعمال الصياغة الجامدة لتحقيق الأمن والاستقرار القانوني، باعتبارها وسيلة تحقق الثبات واليقين القانوني بشكل جامد. وهذه الصياغة تقيد سلطة القاضي في تفسير الوقائع، حيث يتوقف دوره على مجرد الاستدلال الشكلي بين المبدأ القانوني الثابت في القاعدة، وبين الوقائع التي يريد إنزاله عليها، فإذا وجد أن الوقائع تندرج تحت المبدأ، فإنه يطبق المبدأ القانوني تطبيقاً آلياً.

٣- توسيع نطاق القواعد الآمرة:

يلجأ المشرع الوضعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار القانوني من خلال صياغة بعض الأحكام بقواعد أمرة، بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها. ويلجأ المشرع إلى هذه الوسيلة حماية للقيم التي يريد الحفاظ عليها وترسيخها وإلزام الأفراد بها، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار واليقين داخل المجتمع. وتقوم فلسفة القواعد الآمرة في النظم القانونية، على وجود نوع معين من الأنشطة القانونية لا يجوز أن تتدخل في شأنها الإرادة الفردية، بل يجب تنظيمها من قبل إرادة الدولة، التي تحددها في إطار فلسفتها العامة في تأكيد اليقين والثبات في المراكز القانونية. فالقواعد الآمرة وثيقة الصلة بحياة المجتمع، على نحو يقتضي استقلال الدولة بتنظيمها، بما يكفل استقرار هذه الحياة، كالقواعد الضابطة لنظام الحكم، والقواعد المنظمة لكيان المجتمع السياسي والمالي، والقواعد المتعلقة بأمن المجتمع.

ب- الوسائل المتعلقة بالنظم القانونية:

يستخدم المشرع، في سبيل تحقيق الأمن القانوني، عدد من النظم التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني، ومن أهم هذه النظم:

١- **التقادم** ← يُعد التقادم من الأحكام المستقرة في الأنظمة القانونية، باعتباره وسيلة هامة من وسائل تحقيق الاستقرار واليقين في المراكز القانونية. فالتقادم المُسقط. لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر من قيامه على وجوب احترام الأوضاع المستقرة، التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها، وإحاطتها بسياج من الثقة والمشروعية، إذ وجوب احترام الأوضاع المستقرة هو الذي يُحتم تحديد وقت معين بانقضائه لا يستطيع الدائن المطالبة بحقه. كما أن التقادم المُكسب، الذي يؤدي إلى اكتساب ملكية شيء أو حق عيني آخر عليه بحيارته مدة معينة من الزمن يقوم على اعتبارات تحقيق الأمن القانوني.

٢- **الشكلية** ← تُعد الشكلية من الوسائل الأساسية التي يلجأ إليها المشرع لتحقيق اليقين والاستقرار في بعض المراكز القانونية. ويُقصد بالشكلية، المظاهر الخارجية التي يفرض القانون على الأفراد اتباعها في تصرفاتهم، لإمكان ترتيب آثار قانونية معينة، وذلك بإضافة عنصر خارجي إلى العنصر الداخلي، يؤكد وجوده ويضمن مفعوله في نطاق القانون، بغرض التنبيه إلى خطورة بعض التصرفات، أو تيسير إثباتها، أو إمكان الاحتجاج بها على الغير. ومن أهم صور الشكلية، الرسمية التي يتطلبها المشرع في بعض المعاملات، ويشترطها كركن في بعض العقود، لاعتبارها صحيحة ومنتجة لآثارها، الأمر الذي يوجب إبرام هذه العقود من خلال موظف رسمي مختص بذلك. كما أن من صور الشكلية أيضاً، الشكلية الإجرائية، وهي التي تنصرف إلى مجال ونطاق ووظيفة قواعد المرافعات. فالقانون الإجرائي ينظم وسائل وأشكال الحماية القضائية للحقوق الناشئة عن المعاملات الخاصة، والنظام القضائي يخضع لقاعدة الشكلية الإجرائية، وهذا التنظيم الشكلي للنشاط القضائي يكفل له النظام، ويشبع الطمأنينة والثقة في القضاء، كما يفرض ضمانات لصحة القضاء وعدالته، ويحول دون تحكم القاضي وتسرع، ودون هوى الخصوم وتحاييلهم، ويمثل بذلك حصانة لحقوق الأفراد في المجتمع.

بذلك يتضح أن الشكلية الإجرائية تُعد من أهم وسائل تحقيق اليقين والثبات والاستقرار في المراكز القانونية، لأنها تحول دون تعسف الجهاز الإداري القضائي، وتؤكد المراكز القانونية الموضوعية.

٣- **نظرية الوضع الظاهر**← القاعدة إن القانون لا يحمي إلا الأوضاع التي تتفق مع أحكامه، وأن أية أوضاع غير قانونية لا تستحق حماية القانون. إلا إن الضرورة اقتضت الخروج على هذه القاعدة، حيث اعترف القانون بأوضاع مبنية على الظاهر وإن لم تتفق مع أحكامه، ومن هذه الأوضاع فكرة الوضع الظاهر. ويقوم الوضع الظاهر على حقيقة لا يحميها القانون، إلا إنه يوهم في تعبيره عن نفسه أمام الناس بأنه مركز يتفق مع حكم القانون. ويوجد العديد من التطبيقات لهذه النظرية في القانون الوضعي، مثل: صحة تصرفات الوكيل الظاهر، والوارث الظاهر، والموظف الفعلي.

س ٤ : اكتب في ماهية الخير العام ودور الدولة في تحقيق الخير العام؟

الخير العام

أولاً: ماهية الخير العام:

يهدف القانون بتنظيمه لسلوك الأفراد في المجتمع، إلى تحقيق غايات متعددة، منها الخير العام للمجتمع. والقانون من خلال تنظيمه لسلوك الأفراد في المجتمع، يجب أن يراعي ظروف المجتمع الذي يحكمه، إذ إن ما يصلح لمجتمع قد لا يصلح لمجتمع آخر، أو للمجتمع نفسه في زمن آخر. وتنظيم القانون لسلوك الأفراد، يشمل في الوقت ذاته تحقيق مصالح الأفراد وحاجاتهم. ولقد أدى الارتباط بين القانون والمجتمع، إلى بحث مسألة الارتباط بين القانون والصالح العام.

يُقصد بالخير العام، تحقيق الخير والصالح للجماعة ككل في المجتمع. أي تحقيق الخير العام للمجتمع ككل وليس لطائفة معينة من الأفراد أو فرد بعينه. فالقاعدة القانونية توصف بأنها قاعدة عامة ومجردة، انطلاقاً من كونها تبغي تحقيق الصالح العام لكافة الأفراد في المجتمع، بغض النظر عن ذواتهم.

يحدد الخير العام إطاران، أولهما: الإطار الشكلي: ويتمثل في أن الخير العام هو مجموعة الوسائل التي تؤكد فعاليات المجتمع السياسي، حتى يتحقق الخير العام الإنساني. وهو من هذه الناحية يفترض وجود مجموعة وسائل كافية من الناحية الشكلية لحفظ النظام والسلام والأمن في المجتمع. وتُعد الدولة هي المنوط بها وضع وتحديد الإطار الشكلي لتحقيق الخير العام، وذلك عن طريق أجهزتها الإدارية والتشريعية. ثانيهما: الإطار الموضوعي: ويتمثل في العناصر الموضوعية المكونة للخير العام. فالخير العام من الناحية الموضوعية هو الأشياء الحسنة والمفيدة للمجتمع ككل.

لما كانت غاية الخير العام وثيقة الصلة بالقاعدة القانونية، فإن غاية تحقيقا لخير العام تحكم كل فروع القانون، فالتنظيم الداخلي للدولة يجب أن تحكمه غاية تحقيق الخير العام، بحيث يهدف التنظيم السياسي والإداري والقانوني في الدولة إلى تحقق الخير العام. فالتنظيم السياسي والإداري والقانوني والقضائي، مجرد وسائل محددة لتحقيق الخير العام. وقاعدة الخير العام هي التي تحكم العلاقة بين الدولة والأفراد، فالالتزامات المقررة على الدولة لصالح الأفراد وتنظيم الخدمات العامة، وكذلك الواجبات التي يلتزم بها الأفراد تجاه الدولة، مثل: دفع الضرائب والمساهمة في الخدمات العامة والخدمات العسكرية، وبوجه عام، كافة أوجه العلاقات القائمة بين الدولة والأفراد، يحكمها معيار تحقيق الخير العام. فالصالح العام-من الناحية المنطقية- يفرض ضرورة تحقيق المساواة بين الأفراد، ومراعاة قواعد الخير العام عند توزيع الخيرات والالتزامات على أفراد الجماعة.

ثانياً: التوفيق بين الخير الفردي والخير الجماعي:

يشور التساؤل عن كيفية التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، عند السعي نحو تحقيق الخير العام؟.

الحقيقة إن الرأي مستقر على أن التوفيق بين هاتين المصلحتين يتم في إطار سياسة تشريعية متوازنة، تقوم فلسفتها على اعتبار أن دور الخير العام في إنشاء وتكوين القاعدة القانونية، لا يقتصر على تحديد وتقييد مصلحة الفرد لذاتها، ولكن لهدف تحديد دور مصلحة الفرد في إطار مصلحة المجموع، وليس في إطار مصلحة الفرد ذاته. فالفرد لا يُعد غاية في حد ذاته، ولكن يُنظر إليه بوصفه عضواً في الجماعة. فالخير العام هو الذي يلتقي عنده الكل وهو المجتمع، والجزء وهو الفرد، على أساس أن هذا الجزء هو بدوره كل في حد ذاته.

المعيار الواجب اتباعه في مشكلة التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، يتمثل في إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن ما يستوجب اهتمام القانون بالخير العام أو المصلحة العامة، هو كون هذه المصلحة ذات قيمة اجتماعية. فالقاعدة أن كل مصلحة فردية ليست محل حماية لذاتها، بل تكون محلاً للحماية وغاية للقانون إذا كان لها في الوقت ذاته قيمة اجتماعية بالنظر إلى الخير العام. أي أن تكون متصلة بالغاية العامة للنشاط الإنساني في المجتمع، سواء كان نشاطاً فردياً أو جماعياً. وبناءً على ذلك، فالمصلحة الفردية (الخير الفردي) لا تستوجب الحماية، إلا إذا ارتفعت إلى مرتبة المصلحة الاجتماعية في الوقت ذاته.

كما أن مراعاة متطلبات الخير العام تفرض دائماً على المشرع أن يزيل التعارض بين المصلحتين الفردية والجماعية في إطار متطلبات العدالة، كما يجب عليه أيضاً أن يراعى العدالة التصحيحية، أخذاً في الاعتبار متطلبات الخير العام.

الخير العام يُعد من الغايات الأساسية التي يرمي إليها القانون، ومن ثم يجب أن يستوحي النظام القانوني متطلبات الخير الجماعي وليس الفردي، وإن كان يهدف إلى تحقيق الأخيرة، فإن ذلك يكون بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الخير الجماعي. أي يجب إيجاد حل لمشكلة تحقيق الخير العام، مع عدم التضحية بمصالح الفرد. فيجب على المشرع أن يبحث عن نقطة اتفاق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، بحيث يكون فرض تضحية باسم الخير العام مقبولة. فالخير العام يرتكز على التوازن في التوفيق بين المصالح المتعارضة، وليس التضحية التامة بمصلحة الفرد لحساب مصلحة المجموع.

ثالثاً: دور الدولة في تحقيق الخير العام:

يتمثل دور الدولة في تحقيق الخير العام، في كونها تقوم بإجراء التنسيق بين أنشطة الأفراد في المجتمع بهدف مراعاة الصالح العام للجماعة. وتقوم الدولة بتحقيق الصالح العام عن طريق مجموعة وسائل فنية تحكم بمقتضاها في توجيه وإدارة النظام في المجتمع، والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع، وفي إطار تفضيل الخير العام على الخير الفردي في حالة حدوث تعارض بينهما. فالدولة هي التي يقع على عاتقها عبء توفير الظروف المناسبة لتحقيق الخير العام في المجتمع، على النحو الذي يكفل النظام في المجتمع، والخير العام للجميع. ودور الدولة على هذا النحو في تحقيق الخير العام، يتطلب من الدولة اتخاذ قدراً من الإكراه القانوني على الأفراد، لفرض بعض الأمور اللازمة لتحقيق الخير العام. ويتأثر دور الدولة في فرض الوسائل اللازمة لتحقيق الخير العام، بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي وفلسفتها الاجتماعية. وتحديد مضمون وإطار الخير العام ووسائل تحقيقه، توضحه السياسة التشريعية، في ضوء المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في المجتمع.

من الجدير بالملاحظة، إن الأنظمة السياسية مهما اختلفت اتجاهاتها السياسية والاقتصادية، تظل الغاية الأساسية من القانون في كافة الأنظمة الوضعية هي تحقيق الخير العام، إلا إن وسائل تحقيقه هي التي تختلف من نظام إلى آخر، حسب ظروف كل مجتمع. ومن المؤكد إن اختلاف الوسيلة، لا يؤثر على مضمون وإطار الغاية المراد تحقيقها وهي الخير العام. فالخير العام يُعد من الغايات الأساسية التي يحافظ على تحقيقها كافة النظم القانونية، إذ القاعدة العامة إنه لا يوجد مجال في التنظيم القانوني الوضعي لا يهدف إلى تحقيق الخير العام. والدولة تساهم عن طريق أجهزتها المختلفة في تحقيق الخير العام. وفي ضوء تحديد الخير العام، يتحدد مضمون وإطار العلاقة بين الدولة والفرد، ودور الدولة في المجتمع. فالخير العام هو الذي يحدد ويبرر محتوى وشكل ونطاق القاعدة القانونية. كما يستلزم تحقيق الخير العام، وجود تنظيم قانوني رشيد، محدد ومنسق للأعباء والأنشطة الفردية والعامة في الدولة.



القسم الثاني : المنطق القانوني



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٣

س١: تكلم عن منهج وضوابط المنطق القانوني؟

ص ١٠

س٢: وضع علاقة المنطق بالتكييف القانوني؟

ص ١٣

س٣: وضع ما هو الاساس المنطقي في عملية القياس القانوني؟

ص ١٨

س٤: وضع كيفية نقل المنطق القانوني القرائن والادلة المحتملة؟

ص ٢٣

س٥: وضع متي وكيف يتفاعل المنطق مع الكذب في مجال القانون ؟

ص ٢٨

س٦: وضع كيف تستخدم المنطق للخروج من دائرة القياس الناقص؟

ص ٣٢

س٧: وضع كيف تستخدم المنطق في الاستنباط من النص الشرعي؟

ميزان الحقوق

المنطق القانوني (مفهومه ومبادئه وأدواته)

س ١/ تكلم عن منهج وضوابط المنطق القانوني؟

منهج وضوابط المنطق القانوني

هل يمكن للقانوني أن يستغنى عن المنطق

ما هي المهارات الأهم في سلم المهارات القانونية؟

لماذا نحتاج للمشتغلين بالقانون في حياتنا؟ هل لأنهم يساعدوننا في الحصول على حقوقنا؛ أم لأننا نستعين بهم في الدفاع عن أنفسنا؛ في كل مرة نكون فيه محلاً للاتهام؟ عزيزي القارئ: يقوم القانوني بهذه المهمة أو تلك؛ ويقوم أيضاً بعمل آخر لا يقل أهمية؛ وهو دوره في صناعة وعي الناس بحقوقهم.

من أرشيف المنطق القانوني

يتقيد القانوني في عمله بمجموعة من الإجراءات، التي ينبغي القيام بها في مواعيد محددة. يجد القانوني نفسه أمام قضية أو مشكلة تتعدد فيها الآراء بين مؤيد ومعارض. ويكون عليه أن يخضع تلك الآراء للتقييم؛ ثم يختار الرأي الأصح من بينها.

هل يجوز للطبيب أو القانوني أن يبتعد عن أصل المشكلة؛ وأن يضيع وقته في تفاصيل لا فائدة منها؟ من اليسير أن نتوقع الكارثة؛ لأن مشرط الجراح سيتحول - عندئذ إلى سيخ حديد؛ وتتحول مواد القانون في يد القانوني إلى أداة لأكل الحقوق وتزييف الوعي بالقانون.

ما رأيك بعد هذا الحديث عزيزي القارئ- هل تمنع في وصف القانوني بأنه طبيب جراح؟ وهل تعترض على وضع هذه المهارة في أعلى سلم المهارات القانونية؟ وهو السلم الذي ينبغي على المشتغل بالقانون أن يرتقبه؛ وذلك إذا رغب في أن يكون الأكثر وعياً والأشد تأثيراً بين زملائه؟.

خارج الصندوق.. ماذا نربط العدالة والقانون بصورة الميزان؟

سأذكرك- عزيزي القارئ- بأن المشتغل بالقانون يتعامل مع مجموعة من الآراء المختلفة؛ في أغلب القضايا. وأنه يقوم في نهاية الأمر باختيار رأي واحد من بينها؟. إننا نطلق على عملية الاختيار بين الآراء المختلفة مصطلحاً محدداً هو: الترجيح. ألا تذكر هذه الكلمة بالميزان؛ ألا تلاحظ أن القانوني - عندما يرجح بين الآراء فإنه يقوم في الحقيقة بوزن كل رأي منها؛ وأنه يقوم باختيار الرأي الذي ثقلت موازينه أو الكفة الراجحة. والآن عزيزي القارئ- هل يستحق المشتغل بالقانون وهو يقوم بعملية الترجيح وصفاً جديداً هو الوزن؛ جنباً إلى جنب مع الوصف الذي يجدر أن يتحرى به؛ وهو وصف "الطبيب الجراح"؟.

يتوقف النجاح في عملية وزن الآراء أو الترجيح فيما بينها، ثم اختيار الرأي الراجح منها، على القيام بمجموعة من الخطوات. الشرط الأول والأهم في تلك الخطوات هو: أن تكون - جميعها- خطوات منطقية. وإن أول شيء يتطلبه المنطق: أن تكون كل خطوة مبنية على الخطوة التي سبقتها. إنك في هذه العملية أشبه بمن يتدرج بين مجموعة من الخطوات؛ خطوة تعلوها خطوة.. ألا تذكر هذه العملية بكلمة السلم التي سبق وأن أشرنا إليها، ونحن نتكلم عزيزي القارئ عن سلم المهارات القانونية؟

المنطق القانوني - والوعي الشعبي:

يمكنك في هذا الموضوع أن تقتبس منطق المصريين في أمثالهم الشعبية؛ وهم يقولون: محدش بيطلع درجات السلم مرة واحدة. ما هي دلالة السلم في الوعي الشعبي المصري؟. السلم صورة لبناء متعدد الدرجات، كل درجة تؤدي إلى درجة أعلى، وهكذا.. وذلك فإن وصولك للدرجة الأعلى في السلم؛ هي نتيجة حتمية ومنطقية لمرورك بالدرجة السابقة عليها. يستعمل المصريون هذا المنطق للتعبير عن النظام الذي يتدرج فيه الفرد اعتماداً على كفاءته، فيترقى إلى وظيفة أعلى، أو ينتقل إلى وضع اجتماعي أفضل.. وهكذا فإنه بدون عنصر الكفاءة؛ يصبح عامل الزمن وعنصر الجهد هباءً منثوراً. وتشير هذه الحكمة الشعبية إلى أثر التفكير المادي والمنطقي في حضارة المصريين. وهناك شواهد عديدة على وجود هذا الاتجاه ورسوخه في العقلية المصرية منذ القدم. ما رأيك عزيزي القارئ أن تتعمق في هذا النوع من البحث؟

لعلك - عزيزي القارئ - ترغب في بعض التفاصيل عن المهارة الجديدة، التي ينبغي أن يتحلى بها القانوني. في سلم المنطق القانوني. يبدأ القانوني عمله بخطوة نسميها "تحرير محل الخلاف أو النزاع" ويفرض المنطق قانونه في هذا الموضوع؛ لأنه ليس من المنطقي أن يشغل الباحث بمسألة لا يوجد خلاف حولها.

تدريب - ١ - الخطوات المنطقية في عملية الترخيص بين الآراء:

الخطوة الأولى: يستبعد القانوني النقاط موضع الاتفاق؛ أي تلك التي لا يوجد خلاف حول حكمها القانوني أو الشرعي. معنى هذا: أن القانوني يركز على النقاط محل الاختلاف، التي تتعدد فيها وجهات النظر.

الخطوة الثانية: يقوم القانوني بحصر الآراء في النقاط التي وقع فيها الاختلاف؛ وتحديد أدلة كل رأي منها. والأدلة جمع دليل؛ والدليل هو الأساس القانوني أو الشرعي التي يستند إليه الرأي.

الخطوة الثالثة: يستبعد القانوني الآراء غير الصحيحة وغير المقبولة. وسيكون عليه بعد ذلك أن يستعمل الميزان؛ بهدف الترجيح بين الآراء المتبقية. سيختار القانوني الرأي الذي يستند إلى الدليل الأقوى؛ وسيكون الرأي الذي يختاره بمثابة الكفة الراجحة في القضية محل النزاع.

القانوني: هل هو مجمل بيانات أم هو محال معلومات؟

الخطوة الأصولية: يعتقد البعض أن عمل القانوني في الخطوة الثانية هو مجرد عمل إحصائي. دعني أؤكد لك - عزيزي القارئ - أن المشتغل بالقانون - في تلك الخطوة يقوم بنشاط أوسع نطاقاً وأكبر أثراً. ما رأيك - عزيزي القارئ - أن نطلق على هذه الخطوة اسم "الخطوة الأصولية"؟

١- **يقوم القانوني:** بحصر الآراء في المشكلة موضوع النزاع. وسأعترف لك عزيزي القارئ - بأن جميع الآراء وحصرها - على هذا النحو - هو عمل إحصائي دقيق. وأؤكد لك أنه عمل هام، ولكنه لن يسعفك وحده في حل القضية المعروضة عليك.

٢- **لذلك لا ينبغي أن يتوقف القانوني عند إحصاء الآراء:** لأنها لن تسعفه وحدها؛ وهو يبحث عن حل للقضية التي بين يديه. يجب على القانوني أن يبحث عن الدليل القانوني أو الشرعي؛ الذي تستند إليها تلك الآراء. يعتمد القاضي في حكمه على أدلة؛ أهمها: التشريع والعرف. ويستخلص الفقهاء المسلمون أحكامهم من دليل القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وغيرهما..

المنطق القانوني.. والوعي الشعبي:

الوضع الاجتماعي للفرد أو طبقته الاجتماعية هو الذي يتحكم في تكوين وعيه وثقافته. ويمكن التعبير عن هذه الفكرة في مجال العمل القانوني والشرعي. وذلك لأن المنطق يقول: إن أي رأي قانوني أو حكم فقهي لم يأت من الفراغ؛ وإنما جاء من أصل محدد؛ وهو ما نسميه المصدر أو الدليل. إن لبحث في الآراء والأحكام إنما هو بحث في الأدلة - في نفس الوقت. وبدون الوعي بهذا الترابط: لن يجني القانوني أو الفقيه شيئاً له قيمه في عمله وبحثه. إن الوعي الشعبي بأن الآراء تتولد من أصول أو جذور محددة وترتبط بها: هو دليل آخر على أثر التفكير المادي والمنطقي في حضارة المصريين.

خطوة التمحيص:

سننتقل للخطوة الثالثة؛ ويقوم المشتغل بالقانون فيها باستبعاد الآراء التي تفتقد مقومات الصحة؛ أو تفتقر إلى مبررات القبول:

- ١- **يفتقد الرأي مقومات الصحة:** بسبب عدم صحة الدليل أو المصدر أو الأصل؛ الذي يستند إليه الرأي.
من ذلك:- الشك في أصل الرأي؛ أو عدم التأكد من صدور هذا الرأي من صاحبه. ومن أمثلته: أن يحتج صاحب الرأي بحكم قضائي أو حديث نبوي. ويثبت للقانوني-بعد البحث والتحري- أن الحكم القضائي لم يصدر أصلاً؛ أو أن الحديث منسوب كذباً للنبي عليه السلام.
- ٢- **يفتقر الرأي إلى مبررات قبوله:** إذا تعارض مع حقائق العلم والتاريخ. وأرجو أن تدقق النظر في كلمة حقائق؛ لأننا نتكلم عن الأمور التي ثبتت على وجه اليقين. السؤال: هل من المنطقي أن يرجح القانوني أحد الآراء؛ في الوقت الذي يتعارض فيه هذا الرأي مع الثوابت العلمية أو التاريخية؟. أليس من المنطقي أن يكون الرأي مقبولاً من الوجهتين العلمية والتاريخية؛ قبل أن نبحث فيما إذا كان هذا الرأي مفيداً أو غير مفيد؟

تدريب - ٢- ارتباط المنطق القانوني بحقائق العلم والتاريخ:

- أرجو-عزيزي القارئ- أن تستخلص الحكم الراجح؛ في المسألة الخطيرة التالية:
- **عُرِضَتْ عَلَيْكَ قَضِيَّةٌ تَتَعَلَقُ بِسَيِّدَةٍ مُطْلَقَةٍ:** تطالب بإثبات نسب ابنها من مطلقها. وتبين لك من المستندات التي قدمتها الموكلة أن واقعة ميلاد الابن حصلت بعد سنة وشهرين من واقعة الطلاق.
 - **تمسكت المطلقّة:** بمذهب الفقهاء الأحناف؛ وقولهم أن أقصى مدة الحمل هي سنتين. وتمسكت كذلك بالمذهبين الشافعي والحنبلي وبالمشهور في المذهب المالكي؛ وهو أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات.
 - **أنكر المطلق نسب الابن إليه:** تمسك دفاعه بالقانون المصري رقم ١٩٢٩/٢٥؛ والذي تضمن النص على عدم سماع دعوى النسب؛ إذا جاء الولد بعد مدة سنة من الطلاق.
 - **ردت المطلقّة:** بأنه لا حجة في التمسك بالقانون؛ في مسألة مدة الحمل؛ لأنها مسألة شرعية. وأن ما ذهب إليه القانون - بخصوص أقصى مدة الحمل - يخالف الحكم الفقهي الذي تبناه أكثر الفقهاء المسلمين.
 - **قدم المطلق:** إفادة طبية موثقة؛ تضمنت التأكيد على أن أقصى مدة الحمل هي **تسعة أشهر أو (٢٨٠ يوماً)**؛ لأن قدرة المشيمة على تغذية الجنين تضعف بشدة بعد الشهر التاسع للحمل؛ الأمر الذي يجعل وفاة الجنين مؤكدة بعد الأسبوع الـ (٤٥) من الحمل.

ما هو المنطق القانوني وما هي أصوله

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

وردت كلمة الميزان في مواضع متعددة بالقرآن الكريم. ولعل أهمها ما جاء في سورة الرحمن، وتكرار كلمتها في ثلاث آيات متعاقبات (٧-٩): "والسمااء رفعها ووضع الميزان ألا تظفوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان" وتلتقي جميعها عند معنى محدد، وهو الآلة التي ينبغي أن نتخذها مقياساً، في معاملات الناس. ويشير طغيان أو اختلال الميزان إلى اضطراب العدالة، عندما تضيع الحقوق بين الأفراد. والربط بين فكرة الخلق وفكرة الميزان هو دليل على وجوب العدالة، وأثر فكرة المنطق في التشريع الإسلامي.

كيف يؤثر المنطق القانوني في عمل القضاة؟

يتم استخدام ميزان المنطق القانوني؛ للترجيح بين الآراء والقضايا؛ سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي:

- ١- **على المستوى النظري:** في مجال صناعة التشريع وتفسيره؛ وهو ما يُطلق عليه المنطق القانوني النظري.
- ٢- **على المستوى العملي:** في مجال تطبيق القاعدة القانونية؛ وهو عمل يضطلع به السادة القضاة وحضرات المحامين.

يُقوم **القضاء الجالس:** بالبحث عن الأساس المنطقي أو المقدمات المنطقية؛ التي سيبنى عليها قراره أو حكمه القضائي. في الوقت الذي سيكون على القضاء الواقف حضرات المحامين التأكد من توافر المنطق في دفاعهم القانوني؛ الذي يجهزونه لصالح موكلهم.

هل ترغب عزيزي القارئ في التوقف أمام تفاصيل عمل القاضي؟

حسناً، إليك مجموعة الخطوات المنطقية التي يمر بها العمل القضائي بإحدى المحاكم:

- ١- **يبدأ القاضي عمله:** بفحص صحيفة الدعوى وشروط قبولها وطريقة إعلانها للمدعى عليه. لدينا في ذلك العمل سلم منطقي من درجتين؛ لأنه لا يجوز البدء في أي إجراء أمام المحكمة؛ إلا بعد التحقق من صحة الدعوى طبقاً للقانون. وبمعنى آخر: يترتب على صحة الدعوى أولاً انعقاد الخصومة أمام المحكمة ثانياً.

٢- **ينتقل القاضي للخطوة التالية:** لقد نشأت الخصومة نتيجة لصحة الدعوى؛ ولذلك يبدأ القاضي في تلقي طلبات الخصوم. من الناحية الزمنية: يتوزع عمل القاضي على مجموعة من الجلسات المُعلنة؛ وتشهد تلك الجلسات مجموعة من الأعمال والإجراءات. السؤال: هل القاضي مُطلق اليدين في تحديد نطاق عمله؟ لماذا لا نحتكم للمنطق عزيزي القارئ؟ تشمل الخصومة طرفين أساسيين؛ هما المدعي والمدعى عليه. ويتمتع كلاهما بحق لا يجوز إنكاره. يستعمل المدعي حقه في الدعوى؛ ويباشر المدعى عليه حقه في الدفاع. ولذلك فإن الطلبات والدفع التي يقدمها الخصوم في الدعوى هي التي تحدد نطاق عمل القاضي وتطبيقاً لذلك: لا يجوز للقاضي بوجه عام الحكم في شيء لم يطلبه الخصوم.

- ٣- **يصدر القاضي أخيراً حكمه في النزاع المعروض عليه:** يلجأ القاضي إلى تطبيق صحيح القانون مباشرة؛ عندما يستعين بالتشريع أو العرف أو المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية. وإذا لم تسعفه تلك المصادر بالحكم: فإنه على القاضي أن يهتدي بالقانون الطبيعي وقواعد العدالة.

قبول الدعوى ← إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه ← مباشرة الخصومة

١- السلم المنطقي والخطوات المتدرجة في العمل القضائي:

- هناك خطوة منطقية وأساسية تسبق الحكم في الدعوى؛ ونطلق على تلك العملية اسماً محدداً هو: عملية التكييف القانوني. تمر عملية التكييف القانوني بدرجات ثلاث منطقية، بعضها فوق بعض:
- ١- **تحديد الواقعة محل النزاع وموضوع الدعوى:** بالنظر إلى أنها الواقعة الأساس التي نشأت بسببها الخصومة؛ والتي تعلقت بها طلبات الخصوم ودفعوهم.
 - ٢- **استخلاص القاضي:** الوصف القانوني الدقيق للواقعة محل النزاع.
 - ٣- **يترتب على تحديد الوصف القانوني للواقعة نتيجة منطقية:** تحديد القاعدة القانونية الصالحة للتطبيق عليها.

تتطوي عملية التكييف القانوني كما لاحظنا على نشاط قانوني محدد؛ يستعمل فيه القاضي التفكير المنظم. ولذلك فإن تلك العملية تتعارض مع التفكير العشوائي؛ ولا تتفق مع أسلوب الظن والتخمين؛ ولا تنقاد للميول العاطفية. ولك يمكن

🌟 **وصف عملية التكييف القانوني** ← عملية قانونية وعقلية في ذات الوقت. وتخضع تلك العملية لمنهج علمي محدد؛ ولا يمكن أن يكتمل هذا المنهج إلا باتباع قواعد المنطق والخضوع لمقتضياته.

ما هو المنطق القانوني .. وكيف نستعمله ونوظفه؟

🌟 إن غاية المنطق القانوني هو الانتقال من السبب إلى النتيجة. وبمعنى أكثر دقة: الانتقال من مقدمة لا خلاف على صحتها؛ إلى نتيجة تترتب عليها حتماً أي بحكم اللزوم. ولماذا تكون النتيجة لازمة: لأنها النتيجة التي يقبلها العقل. ولماذا يقبلها العقل: لأنه ثبت بحكم التأمل الذهني أو الملاحظة والمشاهدة؛ أن ذلك السبب لابد أن يُفضي إل تلك النتيجة. يُطلق عليها: **"المقدمة الصغرى"**.

🌟 يشترط في العلاقة أو الرابطة بين المقدمة والنتيجة: أن يكون أساسها ومبناها المنطق. ولهذا تصدى بعض العلماء لتعريف المنطق بالقول: إنه الآلة أو الميزان أو المعيار؛ الذي لا يستغنى عنه الباحثون في كافة العلوم. إننا نستعمل هذه الآلة في علم القانون ذاته؛ لأننا نسخرها في تمحيص الآراء والأدلة المختلفة؛ ولأننا نختار على أساسها الرأي الراجح الذي يستند إلى الدليل الأقوى. إننا نحصل في نهاية تلك العملية على شهادة صلاحية صادرة من العقل.

مقدمة كبرى = سبب معقول ← مقدمة صغرى = نتيجة لازمة

٢- سلم المنطق القانوني:

🌟 هكذا يخضع المنطق للقواعد التي تتفق مع التفكير السليم؛ فتخرج أجزاء التفكير ومراحلها متناسقة لا تعارض بينها. إنك في كل مرة تقوم فيه بعمل ذهني؛ تربط فيه بين المقدمات والنتائج المترتبة عليها؛ بين الأشياء والعلل، بين الأسباب والنتائج تكون قد قمت بعمل منطقي.

🌟 **الميزان** ← الآلة التي يعتمد عليها القضاة والفقهاء والمحامون؛ وهم يتناولون الوقائع موضوع النزاع أو البحث. يعكف هؤلاء على اختيار القاعدة القانونية التي تنطبق على الواقعة التي بين أيديهم. ويبدأون عملهم بتحديد الوصف القانوني الدقيق للواقعة؛ ويتوصلون بذلك للمقدمة الكبرى. وينتهي عملهم باختيار القاعدة القانونية المناسبة للواقعة؛ فيصبح لديهم المقدمة الصغرى. أما المشتغلون بالفقه الإسلامي: فإنهم لا يستغنون عن آلة المنطق. وذلك لأنه لا يمكن للفقيه أن يرجح أحد الآراء الفقهية؛ إن لم يثبت من قوة الدليل الشرعي؛ الذي يستند إليه ذلك الرأي.

🌟 يترتب على كلامنا هذا أن القاضي يجمع في عمله بين نوعين من المنطق القانوني؛ فلا يستغني بأحدهما عن الآخر:

١- **المنطق القانوني الشكلي**: بالنظر إلى التزام القاضي بقواعد القانون؛ عندما يدقق في صحة الدعوى، وشروط قبولها وصحة الإعلان بها.

٢- **المنطق القانوني الموضوعي**: عندما يقوم بتحديد الواقعة الرئيسية محل النزاع؛ ثم إسباغ الوصف القانوني الدقيق عليها.

ندريب - ٣- الاستدلال والاستنباط في مجال المنطق القانوني:

🌟 العمليات العقلية داخل المنطق القانوني ليست حكرًا على القضاة. يبذل المحامون بالطبع جهدهم في هذا المجال. ويتوقف نجاح القاضي والمحامي في تلك العمليات على إثبات العلاقة المنطقية بين السبب ونتيجته، بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى. يُطلق أساتذتنا على الوسائل والأدوات التي نتوصل به الإقامة تلك العلاقة اسم الاستدلال.

لذلك يحمل المنطق أكثر من تعريف؛ إنه الآلة أو الميزان أو المعيار؛ الذي لا يستغنى عنه الباحثون في كافة العلوم. بينما عرفه البعض الآخر من أساتذتنا: بأنه علم الاستدلال. ومعنى الاستدلال ببساطة: هو أن تقدم الدليل وتقيم البرهان على وجود الشيء. ولهذا السبب عرفوا المنطق بأنه علم الاستدلال؛ لأن **موضوعه هو**: البرهنة أو إقامة الدليل على أن النتيجة التي تم التوصل إليها؛ مرتبطة بالسبب الذي أفضى لها؛ ارتباط حتمي بحكم العقل أو الواقع أو الإثنين معاً.

لماذا عرفوا المنطق القانوني بأنه علم الاستدلال؛ ولم يقولوا إنه علم الاستنباط؟ الجواب: لأن الاستدلال أوسع نطاقاً من الاستنباط في مجال المنطق القانوني؛ وإليك عزيزي القارئ الأسباب:

- **الاستنباط له معنى محدد**: عندما يكون هدفك هو استخلاص الحكم في القضية المعروضة عليك؛ سواء استخلصته من قاعدة قانونية أو من دليل شرعي. يمكنك أن تتفحص في هذه العملية دور القاضي، يرتبط نجاح القاضي في عمله بتقديم الوصف القانوني الدقيق للواقعة موضوع النزاع؛ الأمر الذي يعقبه تحديد القاعدة القانونية التي تنطبق عليها. وهكذا يسعى القاضي إلى استخراج القاعدة القانونية المناسبة من مصدرها؛ الذي قد يكون التشريع أو العرف إنها كما ترى عملية تحليلية؛ لماذا: لأن القاضي يعتمد على جهده الذهني وتفكيره النظري؛ عندما يتوقف عند المصدر أو الأصل القانوني؛ ليستخرج منه القاعدة القانونية التي تنطبق على الواقعة موضوع النزاع. ومثل القاضي في ذلك مثل أساتذتنا في الفقه الإسلامي. عندما يتوقف الفقيه أمام المصدر أو الأصل الشرعي؛ فيستخرج منه الحكم الفقهي للواقعة.
- **من هذه الزاوية**: يلتقي الاستدلال مع الاستنباط؛ إذا تركز عمل القانوني أو الفقيه على التفكير النظري والتأمل الذهني؛ وكان موضوع عمله هو البحث في القواعد القانونية أو الأحكام الفقهية. نقول: يلتقيان في المنهج وموضوع العمل؛ غير أنهما يختلفان في الغاية من العمل ذاته.

٣- مقارنة عمليات الاستدلال التي تقوم على التفكير النظري:

عملية الاستدلال أوسع نطاقاً من الاستنباط: لأن القانوني قد يتجاوز مجرد التفكير النظري والتأمل الذهني. وينتقل إلى الملاحظة الحسية والمشاهدة المادية في عالم الواقع. يقوم القانوني في هذه الحالة بالتفكير والنظر في حياة الناس. ويهتدي في عالم المحسوس إلى ظاهرة محددة؛ فيقوم بتقصي أسبابها وتمحيص العوامل المؤثرة فيها. ويختتم القانوني عمله بعد ذلك باستخلاص المبادئ التي تحكم تلك الظاهرة. إن عملية الاستدلال بهذا الشكل هي عملية تأصيلية؛ وتحمل بكل دقة اسماً مخصوصاً هو: الاستقراء. وذلك لأن العمل القانوني فيها يبدأ من الوقائع؛ أي إنه ينطلق من الحوادث والجزئيات؛ وينتهي باستخلاص بعض المبادئ العامة والأحكام الكلية.

تعتبر تلك المبادئ والأحكام العامة ثروة؛ لأنه يمكن توظيفها بما يحقق مصالح الناس؛ سواء في مجال القانون أو الفقه الإسلامي. بمعنى أنه يمكن للمشرع أن يعتمد عليها في إعداد القواعد القانونية المنظمة للظاهرة ويمكن للمشتغل بالفقه الإسلامي أن يستفيد منها أشد الفائدة؛ وهو يبحث عن الأحكام الفقهية الاجتهادية للظاهرة.

الموقف القانوني في الشريعة الإسلامية:

اعتمد الفقهاء المسلمون كما لاحظنا من قبل على المنهج الاستقرائي؛ بملاحظة واقع الناس. وتوصلوا إلى وجود مجموعة من المصالح الضرورية؛ التي تستحق القدر الأكبر من الحماية القانونية. وهي المصلحة في حماية النفس والدين والعقل والمال والنسل؛ وأطلقوا عليها اسم: **"المفاسد"**. ويستعمل الفقهاء المسلمون المنهج الاستقرائي أيضاً في التعرف على المصالح المستجدة في المجتمع. وقد انتهوا إلى الإقرار بمبدأ تغير الأحكام الاجتهادية، تبعاً لتغير مصالح الناس وأعرافهم. ولذلك على الباحث في الفقه الإسلامي أن يكون واعياً بأثر المجتمع ومصالحه في تطور الفقه الاجتهادي للمسلمين. إن التعامل مع الفقه الإسلامي باعتباره كتلة جامدة لم ينالها التطور هو تعامل خارج نطاق العلم ومنهجه.

تعدد أشكال الاستدلال كالاتي :

- ١- **الاستدلال بالقياس**: يطلق عليه الاستدلال غير المباشر. في القياس يكون لدينا واقعة لها حكم قانوني أو شرعي؛ ثم تحدث واقعة أخرى مشابهة. ويثور التساؤل عندئذ: هل يجوز أن نأخذ حكم الواقعة الأولى أي الأصلية؛ ونطبقه على الواقعة الحادثة أو المستجدة.
- ٢- **الاستدلال بالتقابل**: يقوم هذا الشكل على فكرة التقابل بين طرفي المسألة الواحدة. ذلك أن المسألة الواحدة قد تشتمل على قضيتين؛ إن قيام الدليل على بطلان قضية منهما: يستتبع بالضرورة بطلان القضية المقابلة. وذلك لأنه يستحيل اجتماع البطلان والصحة في مسألة واحدة.
- ٣- **الاستدلال الاستقرائي أو التجريبي**: يتم التعرف على مصالح الناس واحتياجاتهم؛ من خلال ملاحظة حياتهم وعاداتهم وسلوكهم. تعتبر عملية التعرف على مصالح الناس بتلك الطريقة المادية عملية استقرائية. يقوم الاستدلال الاستقرائي أو التجريبي على فكرة محددة؛ هي استخلاص بعض المبادئ العامة؛ من وقائع وجزئيات موجودة فالواقع. وتكمن فائدة هذه العملية في خطوة أخرى لاحقة؛ وهي الخطوة التي نستعملها في مجال التشريع والبحث القانوني. وذلك عندما نأخذ تلك المبادئ؛ ونقوم بتعميمها أو تطبيقها على وقائع وجزئيات أخرى مشابهة.
- ٤- **الاستدلال بالمثل**: نعتمد في هذا الاستدلال على العلاقة المنطقية بين الشيء؛ وبين مثله أو شبيهه الذي هو من جنسه.

تدريب -٤- أنواع أشكال الاستدلال:

تطبيقات على الاستدلال :

- **قرأت في أحد كتب الفقه الإسلامي**: أنه يكفي بشهادة امرأتين؛ في إثبات الوقائع الخاصة بالنساء؛ أي تلك الوقائع التي من المعتاد ألا يطلع عليها ويلاحظها سوى النساء. يقول أحد الفقهاء إن شهادة امرأتين على أن فلاناً وفلاناً كانا قد رزعا من امرأة واحدة؛ عدد خمس رضعات مشبعات؛ هي شهادة كافية لتحريم الزواج بينهما؛ باعتبارهما أخوين بالرضاعة.
- **قرأت في أحد كتب الفقه الإسلامي**: أن أحد الرواة؛ واسمه... المولود سنة... قام بنقل حكم فقهي عن أحد الصحابة الكرام - في مسألة محددة. واكتشفت بالبحث والتدقيق أن ولادة الراوي كانت عقب وفاة الصحابي المنطق يقول: إن واقعة ميلاد الراوي-بعد وفاة الصحابي: تؤكد استحالة حصول اللقاء بينهما؛ وأن سماع الراوي من ذلك الصحابي هو محض وهم-بل وخيال!
- **قرأت حديثاً عن النبي عليه السلام -خلاصته**: أن سكوت البنت عند طلبها للزواج؛ يعتبر موافقة منها على العريس الذي تقدم لها أو كما قال عليه السلام. وقرأت أكثر من بحث في علم الاجتماع؛ درس فيه الباحثون عادات المصريين في الزواج في أكثر من محافظة. وانتهى الباحثون إلى أن سكوت البنت عند طلبها للزواج لم يعد عرفاً في تلك المحافظات؛ خلافاً للعرف الذي كان سائداً في عصر النبي عليه السلام. وقرأت دراسة لأحد أساتذتنا الفقهاء: أن حديث النبي عليه السلام المذكور لم يعد ملزماً في عصرنا؛ لأن الحكم التشريعي الخاص الوارد فيه كان مبنياً على العرف؛ وهو العرف الذي تغير في عصرنا.
- **تصفحت القانون المدني المصري**: ولاحظت فيه أن القانون يعترف بصحة التصرف في المنقولات، عن طريق البيع. وقال لك أستاذك الجليل في المحاضرة: إن ذلك الإقرار أو الإقرار هو دليل قاطع؛ على أن القانون المدني المصري يعترف بالحق في تملك المنقولات.

س ٢/ وضع علاقة المنطق بالتكييف القانوني؟

ما هي علاقة المنطق بالتكييف القانوني

تدريب - ٥ - المنطق القانوني ومهارة البحث عن المعيار:

- سيكون على المحامي أن يفتش عن شيء مادي أو فكرة مادية؛ قبل الكشف عن الوصف القانوني للواقعة. سيكون هذا الشيء أو الفكرة المادية بمثابة المعيار أو المقياس الذي يحتكم المحامي إليه؛ فيحصل منه على الوصف القانوني للواقعة. ما هو المعيار في القضية التالية:
- كان الأب يحتفظ بسلاحه الناري في دولابه ويحتفظ بمفتاح الدولاب: قامت مُشاجرة بين أبنائه وأحد الجيران بالشارع، وسقط ذلك الجار بطلق ناري من سلاح الأب.
- سيبحث حضرة المحامي عن إجابة السؤال التالي:
- **هل الأب فاعل أم شريك، أم لا توجد مسؤولية عليه؟.**
- يجب على المحامي أولاً أن يستبعد مسؤولية الأب بصفته الفاعل الأصلي في جريمة القتل المذكورة. وذلك لأن الأب ببساطة: كان مستلقياً على سريره في تلك اللحظات؛ وربما كان يستمع أو يستمتع بصياح أطراف الخناقة وأهل الشارع!.
- إن المعيار الوحيد الذي ينبغي أن يسند إليه المحامي في هذه القضية: كمن في الإجابة على سؤال وحيد. أما السؤال فهو: متى يكون الفرد شريكاً في جريمة؟. من الناحية القانونية: يتخذ الإشتراك الجنائي أحد صور ثلاثة، وهي: الاتفاق والمساعدة والتحريض. إذا ارتكب الأب إحدى تلك الصور: فإنه يكون شريكاً في جريمة القتل. وإذا لم يثبت عليه شيء من ذلك: فإنه سيتمكن من استكمال نومه هادئاً قرير العين!.
- في التطبيق السابق: كان لدينا معيار أو مقياس محدد نحتكم إليه؛ بهدف تحديد مسؤولية الأب؛ وتقديم الوصف القانوني الدقيق للواقعة. إن التحقق من اشتراك الأب - في جريمة القتل - كان يتطلب بالضرورة تعقب أي دليل مادي؛ على أنه ارتكب صورة أو أكثر من الصور الثلاثة للإشتراك الجنائي. وهكذا يتطلب المنطق القانوني أن يكون المعيار أو المقياس قابلاً للملاحظة المادية. بمعنى أنه يمكننا التثبت من وجوده أو عدم وجوده؛ في الواقع.. في الحقيقة.
- يجوز أن نطلق على المعيار أو المقياس اسماً ثالثاً هو الضابط. وسواء استعملت أي اسم منها: فإنك تكون بصدد البحث عن عنصر محدد؛ يتحقق في الواقع وبشكل مادي. وستنتهي العملية بنتيجة منطقية؛ يقطع العقل بصحتها. إن عدم وجود أي صورة من صور الاشتراك في الجريمة؛ تترتب عليه نتيجة وحيدة؛ وهي عدم وجود أي مسؤولية جنائية للأب - في القضية المذكورة.
- **بلاحظ أن** المحامي يحتاج إلى الإلمام بمجموعة من المعايير أو المقاييس أو الضوابط القانونية. إن كل معيار منها هو بمثابة مفتاح الإجابة المطلوبة في إحدى القضايا.
- الآن يصح أن نعقد مقارنة في مجال المنطق القانوني؛ ومن المهم أن أذكرك بفكرة الميزان التي يقوم عليها المنطق؛ وهل يقوم الميزان بدور واحد:
- ١. **يعتمد القانوني على الميزان في عملية الترجيح:** عندما يقوم القانوني بوزن الآراء؛ فيختار منها الآراء الصحيحة والمقبولة؛ ثم يقوم بعد ذلك بترجيح الرأي الأقوى حجة. في مثل هذه الحالة: كان الميزان أداة للترجيح بين الآراء واختيار واحد منها.
- ٢. **قد يتحول الميزان إلى معيار أو مقياس أو ضابط:** ويقوم القانوني في تلك الحالات بعرض الواقعة موضوع النزاع على المعيار أو الضابط؛ ثم يستخلص النتيجة. في هذه الحالة: كان للميزان دور مختلف؛ مقارنة بالحالة السابقة. دورٌ مختلف نعم؛ لكنه ما زال أداة عقلية ومنظمة.
- ٣. **إن الاعتماد على المعيار في مثل الحالة التي تدربت عليها حالاً:** كان هو السبيل الوحيد والمباشر؛ للبحث في أصل المشكلة وموضوع النزاع. ولذلك يصح أن نشبه المعيار أو المقياس أو الضابط في العمل القانوني.

نريب-٦ - معيار النية أو القصد في عملية التكييف القانوني:

البحث عن المعيار أو المقياس في القضايا الثلاثة التالية :

- **القضية الأولى :-** قام موكلك بتوثيق أحد الأفراد بالحبال للحصول منه على بعض الأموال؛ وصارك موكلك بالسبب؛ وهو أن المجني عليه كان مديناً له بمبلغ كبير من المال، وأنه رفض سداد الدين في موعده المتفق عليه.
 - **القضية الثانية :-** تم ضبط أحد الطلاب وبجواره هاتفه المحمول مفتوحاً؛ وقد تبين بفحص كراسة الإجابة الخاصة بالطالب؛ أنه لم يستفد من المادة الموجودة على هاتفه؛ في إجابة أسئلة الامتحان.
 - **القضية الثالثة :-** اتهم الزوج زوجته بإجهاض نفسها؛ وتبين أنها كانت تتردد على أحد الأطباء لمتابعة حملها؛ وأن الزوجة كانت على صلة قرابة به. ولذلك كان الطبيب على علم بظروفها الاجتماعية القاسية؛ وأنها سبق لها وأن أنجبت خمسة أولاد؛ بعد عملية قيصرية.
- في القضايا الثلاث السابقة كان عمل المحامي يتركز على كشف حقيقة النية -أو القصد لدى الفاعل. تحديد حقيقة النية كانت هي المعيار أو المقياس أو الضابط في عملية التكييف القانوني. وأنه كان يقوم بعمل خطير؛ يتوقف عليه تحديد ما إذا كان عمله يدخل في نطاق العمد؛ أم كان يلحق بدائرة الخطأ أو الإهمال. وتختلف العقوبة بسبب ما إذا كانت الجريمة عمدية؛ أو كانت قد وقعت على سبيل الخطأ.

هل هناك علاقة بين عملية التكييف القانوني وعملية القياس؟

غير أنه سيكون لدينا سؤال هام: هل يبحث المحامي في كل مرة عن المعيار أو المقياس أو الضابط؛ بهدف تمحيص نية الفاعل؛ وتقديم التكييف القانوني الدقيق للواقعة؟. وسيكون علينا للإجابة على هذا السؤال أن نبحث في العديد من التطبيقات. وأن نتحقق من علم المحامي فيها؛ وهل يتركز على عناصر أخرى؛ غير عنصر النية أو القصد؟. وكيف يستخدم أدوات المنطق القانوني؛ وهو يقوم بعملية التكييف القانوني للواقعة موضوع النزاع.

مفهوم الشرعية الجنائية:- المفهوم الذي نلخصه بالعبارة المحكمة التالية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني تشريعي. هذا المبدأ هو ثمرة نضال مثير؛ خاضته المجتمعات البشرية سنوات طويلة!.

يشتمل هذا المبدأ المقدس على مجموعة متفرعة من المبادئ؛ منها بعض المبادئ التي يتعذر فصل أحدها عن الآخر. ومن ذلك: مبدأ المساواة في العقاب ومبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة. ومن المنطقي أن يقال: إن العدالة تأبى أن تكون الجريمة واحدة؛ بينما تختلف عقوبتها من فرد إلى آخر. غير أن العدالة قد تقبل التمييز في العقاب عن نفس الجريمة؛ بهدف مراعاة التناسب بين كل من العقوبة والجريمة.

نريب-٧ - أثر المنطق العقابي على التكييف القانوني:

- كل جريمة لديها **ركن مادي و آخر معنوي**.
- **الركن المادي:** عنصر الاستيلاء على المنقول المملوك للغير.
- **الركن المعنوي:** نية التملك عند الفاعل. معنى ذلك: أنه يوجد لدينا سبب معقول ومنطقي؛ يبرر البحث عن القاعدة القانونية التي تنطبق على كل جريمة.

نريب-٧ - التحقق من توافر القياس في عملية التكييف القانوني:

- **للتحقق من وجود القياس ضمن عملية التكييف القانوني تعتبر الوقائع الثلاثة الآتية التي وصلت بالقطار :**
- لدينا طرفي المعادلة في عملية القياس؛ لدينا أولاً: نموذج الجريمة المنصوص عليه في القاعدة القانونية وهي جريمة السرقة. ولدينا ثانياً واقعة جديدة؛ وهي واقعة السرقة التي حصلت بالقطار.
- لدينا العلة التي تقوم عليها عملية القياس؛ وهي الاستيلاء على منقول مملوك للغير. لقد توافرت تلك العلة في كل واقعة حصلت بالقطار. وهي نفس العلة الموجودة في النموذج القانوني لجريمة السرقة.
- إن وجد نفس العلة فالواقعة الفعلية؛ وكذلك في الواقعة النموذج: كفيل بالقيام بعملية القياس؛ أليس كذلك؟ هيا بنا إذن نقيس وقائع السرقة بالقطار؛ على نموذج جريمة السرقة في القانون.

🔍 لقد تحققنا من توافر العلة في وقائع القطار؛ فهل معنى ذلك أنه لدينا تكييف قانوني واحد لكل واقعة؟ من الواضح أن كل واقعة ليست مشابهة تماماً للواقعة الأخرى؛ بمعنى أنه يصعب إخضاع الوقائع الثلاثة تحت نموذج قانوني واحد؛ هو نموذج السرقة البسيطة. لماذا: لأن كل واقعة - من الوقائع الثلاثة - تشير إلى نموذج إجرامي مختلف. ولذلك لا يجوز تطبيق القاعدة القانونية الخاصة بالسرقة البسيطة على الواقعتين الأخريين.

🔍 تعالى عزيزي القارئ نتعمق في الفكرة التي أحدثك عنها. نحن نتصدى لعملية التكييف القانوني في هذا الموضوع؛ وهي العملية التي نستعين فيها بعملية استدلالية أخرى وهي عملية القياس:

- ١- **لدينا في كل قاعدة قانونية جنائية:** نموذج محدد للواقعة المعاقب عليها.
- ٢- **يُشترط للقياس على النموذج القانوني:** حصول واقعة مشابهة؛ الأمر الذي يتطلب بالضرورة التأكد من أن العلة في القاعدة النموذج؛ هي نفس العلة في الواقعة الفعلية. يشير توافر العلة إلى أن السلوك المعاقب عليه في القاعدة القانونية، كان قد وقع بالفعل من أحد الأفراد.
- ٣- **هل اكتمل التكييف القانوني للواقعة بذلك:** أم ينقصنا المعيار أو الضابط؛ الذي سنتمكن به من تقديم الوصف

القانوني الكامل لكل واقعة؟

🔍 تشتمل بعض النماذج الإجرامية- في القانون الجنائي- على بعض الظروف المشددة للعقاب. تنقلب الجريمة بالظرف المشدد من جريمة بسيطة إلى جريمة مركبة. الهدف من الظرف المشدد هو النزول على مقتضيات العدالة. أي عندما تكون الجريمة واحدة؛ وتختلف عقوبتها من فرد إلى آخر. لدينا ثلاث جرائم وقعت بالقطار؛ كلها جرائم سرقة؛ ومع ذلك تتفاوت فيها العقوبة؟

🔍 عزيزي القارئ: أرجوك لا تتعجب؛ لأن الجواب يكمن في العدالة! تقف العدالة موقف الرفض من فكرة المساواة في العقاب؛ في الأحوال التي يكون المطلوب فيها تشديد العقوبة؛ استناداً إلى عامل موضوعي. أرجو أولاً أن تتأكد من أن العامل الموضوعي الذي استدعى تشديد العقاب منصوص عليه في النموذج القانوني للجريمة. وسوف أكشف لحضرتك عن العوامل الموضوعية في واقعتين من **الوقائع الثلاثة** التي حصلت بالقطار. لماذا نركز على واقعتين اثنتين؟ لسبب بسيط؛

🔍 **هو أن الواقعة الأولى :-** هي واقعة سرقة بسيطة؛ ولا خلاف بأنها جحة سرقة.

🔍 **يختلف الحكم في الواقعتين الأخريين:-** لأنه يوجد فيهما عامل موضوعي؛ استدعى تشديد العقاب على الجريمة. ولك فإن كل جريمة منهما تخضع لقاعدة قانونية أو نموذج قانوني مختلف؛ عن نموذج السرقة البسيطة.

🔍 **أرجو-عزيزي القارئ- أن تختبر سبب تشديد العقوبة؛** وهل يعتبر وجوده شكلاً من أشكال الخطورة الإجرامية؟. بمعنى هل حضرتك مقتنع تماماً بتشديد العقوبة بسبب العامل الموضوعي المذكور؟. وهل حضرتك مقتنع بأن تشديد العقاب مرتبط باعتبارات العدالة؟.

🔍 إذا انتهيت حضرتك إلى الموافقة على منطق المشرع القانوني؛ فإنك بذلك تكون قد انتقلت إلى فكرة أخرى. خلاصة تلك الفكرة: **أنه ليس المقصود بالتناسب بين العقوبة والجريمة؛** تحقيق المساواة الحسابية بين العقوبات التي يتم النص عليها؛ بخصوص نفس الجريمة. إن تشديد العقوبة ليس هدفاً في ذاته؛ إنما هو الأداة المنطقية التي يستعملها المشرع؛ **لتحقيق التناسب بين العقوبة والجريمة.** ولذلك من المنطقي أن نتشدد في العقاب؛ كلما تسببت الجريمة في ضرر أكبر، أو كانت تنطوي على خطورة إجرامية أشد.

من أرشيف المنطق القانوني:

تتطوي فكرة المساواة الحسابية في مقدار العقوبة على خدعة كبيرة - في بعض الأحيان. ومن ذلك الخدعة التي استخدمها النبلاء في العصور الوسطى؛ في ولاية سكسونيا الألمانية. كان قانون الولاية عنواناً للمساواة بين الأغنياء والفقراء والمعدمين. غير أن العقوبة في الواقع كانت تنطوي على تمييز شديد كانت العقوبات تنفذ على ظل المحكوم عليه؛ إذا كان من طبقة النبلاء. ولذلك كان يتم قطع رأس ظله في عقوبة الإعدام؛ وجلد ظهر ظله في عقوبة الجلد. وكان النبيل يدخل من بوابة السجن لقضاء عقوبته؛ ثم يستمر في طريقه؛ حيث ينتظره الخدم أمام بوابة الخروج!.

- ١- **لقد تبين أن عملة التكيف القانوني:** هي عملية مركبة؛ يستعين فيها القانوني بالقياس؛ لأنه يتحقق من أن العلة في نموذج الواقعة المنصوص عليه في القانون؛ هي نفس العلة في الواقعة الحاصلة.
- ٢- **مع ذلك فإن عملية التكيف القانوني:** قد لا تكتمل في بعض الحالات؛ على الرغم من وجود نفس العلة؛ في القاعدة القانونية وفي الواقعة الحادثة. وبمعنى آخر: قد يقوم المحامي بعملية قياس كاملة وصحيحة؛ ومع ذلك يظل التكيف القانوني للواقعة قاصراً.
- ٣- **أن شرط احتمال عملية التكيف:** هو ملاحظة ما إذا كان المشرع قد أضاف للنموذج القانوني للواقعة عاملاً موضوعياً أو أكثر؛ وأنه قام بالنص على تشديد العقاب لذلك السبب.
- ٤- منطق التشديد العقابي ومهارة التكيف القانوني للواقعة.

أدوات المنطق القانوني وطرق عملها

س ٣/ وضع ما هو الأساس المنطقي في عملية القياس القانوني؟

ما هو الأساس المنطقي في عملية القياس القانوني

القياس عملية ممنوعة.. ولكن هل نستند إلى مبرر منطقي؟

يلجأ كل منا في حياته إلى عملية القياس؛ ربما عدة مرات يومياً. يقوم القياس على منطق بسيط وصادق في الوقت ذاته. إننا نصادف الكثير من الوقائع المتشابهة في حياتنا. بعض تلك الوقائع لها حكم قانوني أو شرعي محدد؛ والبعض الآخر يخلو من هذا أو ذاك. وهو أمر ثابت بالملاحظة والاستقراء؛ وتشهد به معاملتنا.

١- **هل وجود التشابه بين الواقعتين:** كاف وحده لاستعارة حكم الواقعة الأصلية؛ وتطبيقه على الواقعة المشابهة؟. المنطق يقول: إن التشابه بين الواقعتين ليس كافياً في ذاته؛ وأنه يجب أن ندعم هذا التشابه بعنصر آخر أو أكثر؛ يبرر العملية الخطيرة التي سنقوم بها.

٢- **هل معنى ذلك أنه يجب أن تبحث عن واقعتين متطابقتين:** أرجو أن تتمهل في الإجابة؛ لأنه سيترتب على موافقتك سؤال آخر. أما السؤال الآخر فهو: هل من المتصور حصول ذلك التطابق في الواقع؟. وهل ما نلاحظه من تشابه بين بعض الوقائع؛ هو في حقيقته شكل من أشكال التطابق؟. لقد ثبت بالاستقراء: أن كل واقعة تستقل ببعض التفاصيل؛ التي تميزها عن غيرها من الوقائع؛ على الرغم من وجود بعض أوجه الشبه بين بعضها البعض.

٣- **إذا لم يكن التطابق بين الواقعتين متصوراً في الواقع:** فما هو الشيء الذي يمكن الاعتماد عليه؛ ونحن نتصدى لواقعتين متشابهتين؟ ما هو العامل الذي ندعم به الواقعتين؛ ونستند إليه للقيام بعملية القياس؟.

المنطق القانوني.. والوعي الشعبي:

لدينا لمزيد من الأدلة؛ عن مظاهر التفكير المادي والمنطقي في حضارة المصريين. تقول الحكمة المصرية: "يخلق من الشبه أربعين". ترفض هذه الحكمة فكرة التتابع التام بين شيئين أو ظاهرتين في الواقع. إنها تسلم بوجود التشابه في حياتنا؛ وتعترف بأن الشيء أو الأصل الواحد أكثر من شكل؛ بمعنى أنه قد ينشأ عنه أكثر من صورة. تبدو الصور المتشابهة وكأنها مجموعة من الأقنعة؛ التي تخفي الوجه الأصلي خلفها. إننا نعجز عن الفصل بين تلك الأقنعة؛ تماماً كما نعجز عن فصل الشيء أو الأصل، عن الصور التي نشأت عنه.

التشابه بين الواقعتين ليس كافياً للقيام بعملية القياس = التطابق بين الواقعتين ليس متصوراً في العقل والواقع = إذن لابد من وجود عنصر يبرر عملية القياس بين الواقعتين المتشابهتين
البحث عن الأساس المنطقي لعملية القياس:

أن عملية القياس تتم بين واقعتين في الحقيقة؛ بمعنى أننا لانفترض حصول الواقعتين أو إحداها. يصح القول: إن عملية القياس تبدأ من الواقع؛ وتنتهي في الواقع. ما الذي يربط بين بداية القياس ونهايته. الرابط هو تلك العملية المنظمة؛ التي تقوم على التفكير المنطقي والعمل العقلي.

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

تدرب المسلمون على القياس في عهد النبي عليه السلام. وتوسعوا فيه بعد ذلك؛ ولاسيما بعد ظهور المذهب الحنفي بالعراق وانتشاره. ويدخل القياس ضمن الأدلة العقلية؛ لاعتماده على الرأي والاجتهاد؛ للوصول إلى الحكم الفقهي. كما عرفوا القياس الافتراضي؛ في العصر الذي ازدهر فيه الفقه الإسلامي. وهو القياس الذي يقوم على افتراض واقعتين. وقد برع فيه الفقهاء الأحناف؛ واصطلح عندهم على تسميته بـ الفقه الافتراضي. وكانت المسألة الافتراضية تبدأ عندهم بقولهم رأيت إن حصل كذا.. ويشير الفقه الافتراضي- في اعتقادي- إلى عمق النظر والتفكير؛ والسعة التي كان يضيفها الاجتهاد على الفقه الإسلامي وحركته ونموه.

تدريب - ٨ - الخطوات المنطقية في عملية القياس:

• **الخطوة الأولى:** بتحديد الواقعتين المتشابهتين؛ الواقعة الأصلية وحكمها القانوني أو الشرعي؛ وهي الواقعة التي نطلق عليها الأصل المقيس عليه. أما الواقعة الأخرى: فهي الواقعة الجديدة والتي تخلو من الحكم القانوني أو الشرعي؛ وهي الواقعة التي نطلق عليها الفرع.

• **الخطوة الثانية:** البحث عن المبرر المنطقي في عملية القياس. وبمعنى آخر: البحث عن العلاقة المنطقية بين الواقعتين المتشابهتين؛ بين الأصل المقيس عليه؛ وبين الفرع.

• **في الخطوة الثالثة:** نأخذ حكم الأصل المقيس عليه؛ ونطبقه على الفرع وذلك بعد التحقق من وجود العلاقة المنطقية بين الواقعتين المتشابهتين.

• **سنوقف عند الخطوة الثانية:** التي نبحث فيها عن المبرر المنطقي للقياس؛ لأنها الخطوة الأهم في تلك العملية. هل لاحظت أننا في القياس لا نتحدث عن التطبيق المباشر والآلي للحكم؛ على كل واقعة مشابهة. صحيح أن وجود التشابه بين الواقعتين؛ هو أمر لا تستغني عنه عملية القياس. ومع ذلك تتم عملية القياس في بعض الحالات بين واقعتين متشابهتين؛ ثم نكتشف أنه قياس ضعيف يتعذر قبوله. لا يقبل المنطق تعدية القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي من واقعة إلى واقعة أخرى مشابهة؛ ما لم يكن هناك رابط محدد بين الواقعتين. يُعتبر هذا الرابط أو العلاقة بمثابة الكوبري أو الجسر؛ الذي تنتقل عليه القاعدة أو الحكم من الواقعة الأصلية؛ إلى الواقعة الفرعية المشابهة.

• سنقوم الآن بعملية منطقية؛ بهدف البحث عن الجسر أو الرابطة بين الواقعتين المتشابهتين. أليس من المنطقي أن نبحث في المبررات العقلية؛ التي تستند إليها القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي؟ لماذا: لأننا في القياس سنأخذ القاعدة أو الحكم الخاص بالواقعة الأصلية؛ ونطبقه على الواقعة الجديدة.

تشتمل القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي على العلة أي السبب من وضعها؛ وعلى الحكمة من موضوعها. وسيكون عليك في عملية القياس أن تختار بينهما؛ بهدف إقامة الجسر الذي يعينك على إتمام عملية القياس. **هل سنعتمد في عملية القياس على علة الحكم أم على الحكمة من الحكم؟.**

ما هو الفرق بين حكمة القاعدة؛ وبين العلة من القاعدة؟

١- **المقصود بالحكمة:** المصلحة من القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي؛ وتنحصر المصلحة في أحد أمرين؛ إما جلب منفعة للأفراد؛ أو دفع مفسدة ورفع مضرة عنهم.

٢- **المقصود بالعلة:** السبب أو الباعث على وضع القاعدة القانونية أو فرض الحكم الشرعي.

قد تميل إلى الحكمة -عزيزي القارئ- قائلاً؛ ولماذا لا أعتد عليها في عملية القياس بين الواقعتين المتشابهتين. غير أنني أنصحك بالتمهل؛ لأن الحكمة أو المصلحة مسألة نسبية ومتغيرة؛ وقد يتعذر تحديدها أو قياسها. ولقد ثبت بالمشاهدة والاستقراء أن الناس ليسوا سواء؛ عند تطبيق الحكمة من النص القانوني أو الحكم الشرعي عليهم. وذلك بالنظر إلى اختلاف أحوالهم وظروفهم وأعمارهم وإليك السؤال المنطقي التالي: هل يجوز أن نستعمل شيئاً متغيراً ونسبياً في أي عملية للقياس؛ ألا يشترط القياس ثبات الشيء المقيس عليه؟

مثال ذلك: ماهي الحكمة من إباحة الفطر للمسافر في نهار رمضان؛ أليست دفع المشقة وتجنب التعب والإرهاق؟. هل لديك شك في أن المشقة تختلف من فرد لآخر؛ حسب عمره وحالته الصحية؛ وأنها ليست بنفس القدر في كافة وسائل السفر؟. ولذلك يتعذر إخضاع كافة الأفراد من حيث مشقتهم أو تعبهم إلى مقياس محدد أو معيار منضبط. ومعنى ذلك: أن الحكمة من إباحة الفطر قد لا تتحقق في بعض الأفراد؛ ممن يتمتعون بالصحة أو يسافرون بالطائرة.

تعالى-عزيزي القارئ- نجرب الاحتكام إلى علة الحكم أو السبب الذي من أجله تم وضع الحكم. إليك السؤال التالي: ألا تخاطب القاعدة مجموعة من الأفراد؛ ألا يعني ذلك بالضرورة أن يكون هناك دافع وراء وضع القاعدة أو الحكم؛ وأن يكون من الدوافع التي يقبلها العقل. من حقه أن تحتج قائلاً: إن الحكمة من وضع القاعدة هي أيضاً دافع وسبب مقبول عقلاً. وسأرد عليك بالقول: إن العلة تتفوق على الحكمة من زاويتين؛ فهي من ناحية: سبب مقبول عقلاً؛ وهي من ناحية أخرى: سبب يمكن تقديره أو تحديده أو قياسه بطريقة مادية. هل مارلت-عزيزي القارئ- مضمماً على الاعتماد على الحكمة في عملية القياس- بعد كل ما ذكرته لك؟.

عندي لك نصيحة-عزيزي القارئ- إذا كنت تبحث عن الجسر الذي يربط بين الواقعتين الأصلية والفرعية؟. ما رأيك في أن تبحث وسيلة مواصلات؛ يمكنك أن تنتقل بها إلى الواقعة الأصلية؛ فتستعير منها حكمها؛ ثم تقوم بنقل ذلك الحكم إلى الواقعة الجديدة؟. لن تجد أفضل من علة الحكم؛ تتخذها وسيلة للانتقال بين الواقعتين المتشابهتين ببساطة: لأنك في جميع الظروف سيكون لديك معيار منضبط؛ سيكون عندك شيء يمكن قياسه أو تحديده بطريقة مادية؛ لا يمكن أن يختلف الناس بشأنها.

مثال ذلك: إن علة السكر- أو ذهاب العقل- هي المبرر المنطقي في تحريم البيرة الكحولية عند المسلمين. لديك هنا شيء يمكن التحقق منه؛ وهو الشيء أيضاً الذي يقبله العقل؛ ويمنحك التصريح للقيام بعملية قياس ناجحة. وللك لا يستعمل الكثير من أساتذتنا لتعبير التشابه بين الواقعتين عند القيام بعملية القياس. وإنما يفضلون العبارة التالية: التماثل بين الواقعتين. تشير عبارة التماثل بين الواقعتين إلى وجود الجسر أو الرابط أو العلاقة المنطقية؛ بين الواقعتين المتشابهتين.

يلاحظ انه ← تتفوق علة القاعدة؛ عن الحكمة من القاعدة. ولذلك من المنطقي أن نعتد على العلة وحدها في القيام بعملية القياس. ويصح القول: إنك بالاعتماد على العلة: تحصد ثمار عملية القياس في مجال تطبيق القانون؛ وتجنّي أثرها الإيجابي في ميدان العدالة:

- ١- لأن العلة ستكون بمثابة المعيار المنضبط: على الرغم من اختلاف الأفراد في ظروفهم وأحوالهم وقدراتهم الشخصية من هذه الزاوية: فإن المعيار المنضبط يسهل عملية القياس من الناحية الفنية. أما من الناحية الموضوعية: فإن المعيار المنضبط يساهم في قبول الناس للقاعدة أو النص التشريعي؟
- ٢- ولأن وجود العلة: معناه في أغلب الأحوال أن الحكمة من القاعدة أو الحكم قد تحققت. ويعبر أساتذتنا عن هذه الفكرة بقولهم: إن وجود العلة مظنة تحقق الحكمة.
- ٣- تقوم العلة بوظيفتين اثنتين: الوظيفة الأولى: الدور الرئيس الذي تؤديه في عملية القياس؛ عندما تقوم بدور الجسر؛ الذي يربط بين الواقعتين المتشابهتين. تقدم العلة التبرير المنطقي لعملية القياس؛ وتساهم بالنصيب الأكبر في إتمامها على النحو الصحيح من الناحية الفنية. أما الوظيفة الثانية: فهي المساهمة في توفير عنصر الرضا بالقانون بين المخاطبين به. وهي بين هذا وذاك: تكون قد استوعبت الحكمة أو المصلحة المقصودة من القانون في أغلب الأحوال.

هل نجد عملية القياس أحياناً.. للحفاظ على اعتباران العدالة؟

- ❁ **يلاحظ ان** ← الحكم يدور مع علته. وذلك لأن اتخاذ العلة أساساً للقياس: فيه أكثر على ضمانة؛
- ❁ **أولها:** تطبيق الواجبات القانونية أو التكاليف الشرعية
- ❁ **الضمانة الثانية:** استقرار المعاملات المدنية والأحكام القضائية.
- ❁ **يلاحظ أن العبرة في القاعدة أو الحكم:** حتى لو تخلفت الحكم منه. وتلك هي العبرة من التطبيقات التي مرت بنا؛ ومنها على سبيل المثال:
- ❁ **-الواقعة الأصلية:** السفر على جمل في نهار رمضان.
- ❁ **-حكم الواقعة:** إباحة الفطر.
- ❁ **-علة الحكم:** السفر مسافة ٨٤١ كم
- ❁ **-الحكمة من الحكم:** حفظ النفس بدفع المشقة.
- ❁ **-الواقعة الجديدة:** السفر على طائرة في نهار رمضان.
- ❁ **المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:**

❁ كان الخليفة عمر بن الخطاب شديد الوعي بوظيفة القياس؛ وعلاقته بالعدالة. وهو ما يتضح في رسالته إلى قاضيه بالعراق-الصحابي الجليل - أبو موسى الأشعري. تضمنت الرسالة مجموعة من المبادئ في إجراءات القضاء. وقد كشف فيها عن وعيه بالعلاقة بين الاستقرار الاجتماعي؛ وبين استقرار أحكام القضاء والحد من تضاربها. يقول-رضي الله تعالى عنه. "الفهم .. الفهم فيما تلجج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها.."

❁ كنا أمام بعض التطبيقات؛ التي تمت فيها عملة القياس؛ سواء تحققت الحكمة من القاعدة أو كانت قد تخلفت. تقول القاعدة في تلك التطبيقات: إن العبرة في عملية القياس؛ هو وجود عل القاعدة أو علة الحكم.

❁ مع ذلك لدينا تطبيقات أخرى؛ كان تطبيق القياس فيها مرتبطاً بوجود العنصرين معاً- علة القاعدة والحكمة منها. بمعنى أن تخلف الحكمة: سيترتب عليه استبعاد عملية القياس. ويمكن التعبير عن ذلك بالقول: إن الاعتبارات المتعلقة بالعدالة قد ترفض النتيجة التي تترتب على عملية القياس!. بمعنى أننا قد نكون أمام واقعتين متشابهتين؛ وقد تتوافر فيهما علة الحكم؛ ومع ذلك تأبى العدالة قبول نتيجة القياس؛ بسبب عدم وجود الحكمة أو المصلحة من القاعدة.

❁ هكذا نجد وسيلة المواصلات أو الجسر أو العلاقة المنطقية بين الواقعتين المتشابهتين؛ ثم يكون عليك أن تتراجع عن نقل الحكم من الواقعة الأصلية إلى الواقعة الجديدة. خسارة كبيرة؛ ولكن هل تستحق العدالة مثل تلك الخسارة؟

أرجو التوقف أمام المثاليين التاليين. وستجد العلة ماثلة ومتحققة؛ ولكن شيء ما كان قد حال بينها وبين التفاعل في الواقع ترى ماهو ذلك الشيء؟ لقد تخلفت المصلحة أو الحكمة من القاعدة بكل بساطة **يلاحظ ان :**

١- **بطلان عقد البيع الذي يتم بالإكراه:** يحتاج الناس إلى التعاقد لتحقيق مصالحهم؛ وتلك هي الحكمة من إباحة العقود. إن إبرام العقد: يعتبر مظنة لتحقيق تلك الحكمة. ولذلك كان إبرام العقد أو العلة أو السبب؛ الذي يترتب عليه ترتيب أحكام العقد. علة منضبطة ونموذجية لا يمكن أن يختلف فيها اثنان أليس كذلك؟ ومع ذلك قد ينعقد البيع عن طريق الإكراه المادي أو الأدبي. فهل يختلف الحكم عندئذ: إن وجود الإكراه هو دليل على غياب الرضا بالعقد لدى أحد طرفيه. في تلك الحالة: يصعب القول بوجود الحكمة، أو القول بأن المصلحة من التعاقد متوفرة. ولكل يجوز المطالبة بإبطال العقد؛ وهو الحق الذي أقر به القانون للمتعاقد الذي خضع للإكراه؛ ويستوي في ذلك الإكراه المادي أو الأدبي. ولولا ذلك الإكراه: لكان المتعاقد مُلزماً بالعقد وشروطه؛ لماذا لأن العلة كانت موجودة ومتحققة بالفعل؛ والتي كانت تتمثل في إبرام العقد.

٢- **عدم رفع الولاية عن البالغ الرشيد بسبب السفه:** يتصرف الفرد بمقتضى مصلحته؛ في الأحوال التي يكون فيها سليم العقل. ومن هنا اكنت الحكمة من رفع الولاية عنه؛ وذلك عند بلوغه سن الرشد. تقتضي اعتبارات المنطق والعدالة أن يباشر الفرد مصالحه عندئذ؛ لأنه الأقدر على تقديرها والسعي إليها. إن بلوغ الفرد إحدى وعشرين سنة ميلادية: يعتبر مظنة تحقيق تلك الحكمة. ومن هنا كنا السن المذكور هو العلة أو السبب في هذه القاعدة. علة منضبطة ونموذجية؛ لا تثير خلافاً في تحيدها . غير أن الفرد قد يبلغ السن المذكور؛ وهو مصاب بعارض -مثل السفه؛ فما العمل حينئذ؟
 إن وجود عارض مثل السفه يشير إلى عدم تحقق المصلحة أو الحكمة من القاعدة. ونقصد بذلك: القاعدة التي ترفع الولاية عن الفرد عند بلوغه سن الرشد. ويترتب على السفه: استمرارا خضوع السفيه للولاية؛ على الرغم من بلوغه سن الرشد. ولولا ذلك العارض: لكان الفرد أحرص في التصرف في أمواله؛ لأن العلة كانت موجودة ومتحققة بالفعل؛ وهي بلوغه سن الرشد المذكور.

٣- **في جميع ما سبق:** كان لدينا عامل مشترك؛ وهو علة القاعدة أو الحكم. لقد قمنا في بعض التطبيقات بعملية القياس؛ على الرغم من تخلف الحكمة. وتراجعنا عن القياس؛ في البعض الآخر من التطبيقات؛ بسبب عدم وجود الحكمة. لقد احتكنا في هذا وذاك للمنطق والعدالة؛ وإليك ملخص المثاليين السابقين؛ في تعذر القياس بسبب تخلف الحكمة.

٤- **الواقعة الأصلية:** عقد بيع سيارة- بلوغ الفرد ٢١ سنة ميلادية.

٥- **حكم الواقعة:** مباحة - رفع الولاية عنه

٦- **علة الحكم :** إبرام العقد - بلوغ سن الرشد

٧- **الحكمة من الحكم:** حفظ النفس والمال والنسل

٨- **الواقعة الجديدة:** عقد بيع بالإكراه- حصول عارض السفه لدى الفرد

س ٤ / وضع كيفية تقل المنطق القانوني القرائن والادلة المحتملة؟

المنطق القانوني القرائن والادلة المحتملة

ما هي المرحلة التي يتدخل فيها القانون.. ويفرض منطقه..؟

أشرنا في أكثر من موضع إلى الهدف من عملية التكييف القانوني؛ وهو التوصل إلى القاعدة القانونية التي تحكم موضوع النزاع. سيكون عليك أحياناً -حضرة المحامي- أن تقوم بعملية شديدة الدقة؛ وأنت تقوم بعملية التكييف القانوني. وهي أن تعتمد على واقعة معلومة في القضية؛ بهدف إثبات واقعة مجهولة. ولماذا: لأن نجاحك في إثبات الواقعة المجهولة؛ معناه نجاحك في اختيار القاعدة القانونية المناسبة لها؛ والتي يرضيها موكلك.

السؤال: هل يمكنك أن تقوم بتلك العملية؛ إذا لم تكن هناك علاقة منطقية بين الواقعتين المعلومة والمجهولة؟.

وشمة سؤال آخر: ما هو الشرط الذي يشترطه العقل؛ حتى يتقبل تلك العلاقة بين الواقعتين؟.

يتقبل العقل وجود العلاقة بين الواقعتين؛ في حالة ما إذا كانت الواقعة المجهولة هي نتيجة محتملة؛ لوجود الواقعة المعلومة.

-الواقعة المعلومة: استلام ابنتك الكتب الدراسية.

- الواقعة المجهولة: سدادك مصروفات مدرستها.

ندريب-٩- المنطق القانوني يدعم الطرف الضعيف في النعاق:

- تشتري الأسرة وهي تجهز ابنتها للزواج- بعض الأجهزة المنزلية بالتقسيط. ويلاحظ في القضية التالية:
- اشترت أم العروسة فلاجة بالتقسيط من متجر للأجهزة: وكان موعد سداد كل قسط منها هو مطلع كل شهر، بدءاً من مارس ٢٠٢٤م.
- طالب البائع فسخ البيع واسترداد الثلاجة والتعويض: بسبب تخلف أم العروس؛ عن سداد أي قسط من الأقساط المحددة والمتفق عليها.
- قدمت الأم القسيمة التي تقيد سداد القسط الثالث: ولذلك لدينا احتمالان اثنان؛ أولهما: أن تكون الأم قد انتظمت في سداد الأقساط شهرياً. وثانياً: أن تكون الأم قد تخلفت عن سداد القسطين-الأول والثاني.
- الاحتمال الأقوى: هو أن تكون الأم قد سددت القسطين المذكورين. صحيح لا يوجد لدينا دليل قاطع يؤكد دفاع الأم. ومع ذلك فإن وجود قسيمة سداد القسط الثالث معها؛ يدعم احتمال قيامها بسداد الأقساط السابقة.

- هناك-إذن-قرينة قانونية في صف الأم: لأنه توجد واقعة معلومة وحدثت بالفعل؛ ستعتمد عليها الأم في إثبات واقعة أخرى مجهولة. لقد ترتب على سداد القسط الثالث وهي الواقعة المعلومة؛ نشأة علاقة محتملة مع واقعة مجهولة؛ وهي واقعة سداد القسطين الأول والثاني:
- دعوى التاجر فسخ عقد بيع ثلاثة بسبب تأخر المشتري عن دفع الأقساط.
- * قدم المشتري قسيمة السداد الإلكتروني للقسط الثالث في مايو ٢٠٢٤م
- * عجز البائع - صاحب المتجر- عن تقديم الدليل على تخلف المشتري عن سداد الأقساط فحضر دعواه.
- * استند الحكم إلى أن القسيمة المذكورة هي دليل على سداد الأقساط السابقة.

القسيمة قرينة = علاقة محتملة: بين واقعة معلومة حصلت فعلاً

هي سداد القسط الثالث والواقعة المجهولة وهي سداد الأقساط السابقة

🌟 **سنستوقف أمام العلاقة المحتملة بين الواقعتين؛ لماذا:** لأنها المبرر المنطقي والعاقل؛ للنتيجة القانونية التي نريد التوصل إليه. ما هو مصدر الاحتمال في تلك العلاقة؟ لدينا إطار عام؛ يعبر عنه أساتذتنا بقولهم: القانون مبني على الوضع الغالب والأعم. بمعنى أن المشرع لا يتفاعل مع المسائل التي تقع نادراً في حياة الناس؛ لأن ندرتها دليل على ضعف علاقتها بمصالح الأغلبية منهم.

🌟 ينشأ الوضع الغالب بسبب تكرار نوع محدد من الوقائع؛ ينطوي على سلوك بشري محدد. وبمعنى آخر: هناك ظواهر اجتماعية؛ تنشأ كل ظاهرة منها نتيجة الإشباع المتكرر لحاجة اجتماعية محددة. ومثال ذلك: أن الإشباع المتكرر لحاجة الإنسان للطعام؛ كان قد نشأ عنه ظاهرة المقايضة؛ ثم ظاهرة البيع... الأمر الذي مهد لظهور القوانين؛ التي نظمت عقد البيع وأحكامه المختلفة.

تدريب - ١- خطوات الإثبات عن طريق القرائن:

🌟 سنبدأ فيما يأتي بإحدى الأدوات القانونية؛ التي يتم توظيفها لإثبات الواقعة محل النزاع. وسنلاحظ أننا أمام شكل محدد من أشكال الاستدلال المنطقي؛ لأنه يربط بين المقدمة؛ وبين النتيجة التي تترتب عليها:

- **يتعامل القانون مع كل فرد بلغ سن (٢١) سنة ميلادية:** باعتباره كامل الأهلية. طبقاً للوضع الغالب: فإن كل من بلغ هذا السن؛ يكون قد اكتمل عقله ورشده. وتصبح لديه أهلية أداء؛ أي أنه أصبح مؤهلاً للقيام بأي تصرف قانوني. ولكننا نشاهد في الواقع: أفراداً يبلغون هذا السن؛ ولم تكتمل قواهم العقلية. وقد نسمع عن غيرهم؛ ممن اكتمل نضجهم العقلي قبل هذه السن. المنطق يقتضي استبعاد مثل تلك الحالات؛ لأنها في منزلة الاستثناء. والأصل: أن التنظيم القانوني يقوم على الوضع الغالب.

- **إن بلوغ أحد الأفراد تلك السن:** يعتبر قرينة على اكتمال عقله ورشده. نستعمل مصطلح القرينة هنا بمعنى الدليل؛ لأننا نستدل من القرينة على وجود واقعة أخرى مجهولة. ومن ذلك: أن وجود أحد الأفراد بجوار جثة القتيل؛ وعليه آثار دماء أو بيده سكين؛ يعتبر قرينة أو دليل إثبات على ارتكابه جريمة القتل - حتى يقوم دليل على براءته. وإن انقطاع أخبار أحد الأفراد؛ بعد سفره إلى دولة تدور فيها رُحى الحرب؛ يعتبر قرينة أو دليل على مقتله هناك.

- **مثال ذلك:** ثمة علاقة بين واقعتين؛ أحدهما معلومة؛ والأخرى مجهولة. مضمون هذه العلاقة. أن وجود الواقعة المجهولة هو نتيجة محتملة؛ بسبب وجود الواقعة الأولى. وتنشأ القرينة القانونية؛ عندما يتقبل المنطق علاقة الاحتمال بين الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة. ويترتب على ثبوت الواقعة المجهولة - اعتماداً على فكرة القرينة - تطبيق القاعدة القانونية الخاصة بها.

هل هو منطق قانوني.. أن تكون وسيلة الإثبات.. أداة للعقاب؟

🌟 اعتمد الإنسان في المجتمعات القديمة على منطق مختلف؛ وهو يتعامل مع القرينة. **لذلك السبب:** عرفت بعض المجتمعات نظام المحنة أو الاختبار الإلهي. وبمقتضى ذلك النظام كان يتم تعريض المتهم لاختبار أو محنة؛ وذلك بهدف إثبات براءته أو التوصل إلى إدانته بالجريمة. كانت المحنة أو الاختبار تدور حول فكرة محددة؛ وهي تحكيم الآلهة في الحالات التي يعجز فيها أفراد المجتمع عن إثبات بعض الجرائم.

🌟 **من أشهر تلك الجرائم التي كانت تخضع لنظام المحنة:** جريمة زنا الزوجة في العراق القديم. ذلك أنه قد يفشل الزوج في إثبات تلك التهمة على زوجته؛ وعندئذ فإنه كان يتم إلقاء الزوجة في النهر. في تلك العصور كان غرق الزوجة قرينة قاطعة على ارتكابها الجريمة؛ طبقاً للمادة (١٣٢) من قانون حمورابي.

🌟 **كان فشل المتهم في الاختبار أو المحنة:** يعتبر قرينة قاطعة على ارتكابه الجريمة. نقول قرينة قاطعة؛ بالنظر إلى أن نتيجة الاختبار اكنت تكشف عن حكم الآلهة العادل؛ التي لا يُتصور أن تخطئ في حكمها. وهنا يمكن السر في المنطق العقابي القديم؛ عندما كان يخلط بين وسائل الإثبات؛ وبين طرق العقاب.

🌟 لم تكن المحنة مجرد نظام للإثبات؛ لأن المتهم قد يدفع حياته ثمناً لذلك النظام. وقد يكون أوفر حظاً؛ عندما يخرج من المحنة بعاهة مستديمة!. لذلك فإن المحنة كانت وسيلة للوصول إلى الحكم .. وليست وسيلة إثبات بمعنى الكلمة. قد يتقبل المنطق البشري في تلك العصور فكرة المحنة.

هل المنطق في القرينة هو قطع النزاع.. أم طلب الحقوق..؟

تعتبر المحنة أو الاختبار الإلهي صورة للفكر القانوني للبشرية؛ في مرحلة من مراحل تطورها. ذلك أن البشرية كانت على موعد مع نوع آخر من القرائن؛ أكثر قبولاً من جهة المنطق واعتبارات العدالة. واجهت البشرية في بعض المجتمعات المشكلة التالية: وجود جثة قتيل في منطقة أو بلدة؛ وعدم وجود أدلة كافية ضد قاتل بعينه. **ما هي اعتبارات المنطق والعدالة هنا:**

- ١- **تقتضي اعتبارات العدالة:** عدم إهدار دم المجني عليه؛ وهو الأمر الذي يتطلب تدخل القانون؛ حتى لا يتمكن القاتل من الإفلات من العقاب عن جريمته.
 - ٢- **من جهة اعتبارات المنطق:** فإن وجود جثة القتيل - في تلك المنطقة أو البلدة - ينطوي على علاقة الاحتمال التي تحدثنا عنها. بمعنى أن وجود جثته في ذلك الموضع فيه مظنة-شبهة حصول الجريمة بواسطة أحد الأفراد؛ الذين يسكنون في تلك المنطقة.
- يلاحظ** بسبب هذه العلاقة المحتملة بين واقعتين محددين؛ نشأت واحدة من أشهر القرائن القديمة. ونقصد بذلك: العلاقة بين واقعة القتل؛ وواقعة العثور على جثة القتيل في مكان تختص به جماعة من الأفراد. تحمل تلك القرينة في مجتمعاتنا العربية **اسم القسامة:** هو الاسم المشتق من كلمة القسم أو اليمين؛ لأن الحلول التي تعاملت بها المجتمعات مع تلك القرينة؛ كانت تعتمد على شكل أو إجراء محدد؛ وهو توجيه اليمين إلى عدد محدد من الأفراد.
- نشأت تلك القرينة في المجتمعات القبلية؛ التي كانت تعيش على الارتحال بغرض التماس الرعي أو التجارة. ولذلك عرفت الجماعة اليهودية؛ وقبائل العرب قبل الإسلام. ومن المنطقي والمعقول في حياة الارتحال؛ أن تقع بعض جرائم القتل في هذه القبيلة أو غير ذلك؛ في الوقت الذي يكون فيه القاتل مجهولاً.

المنطق القانوني .. والوعي الشعبي:

- خلافًا للكثير من المجتمعات القديمة؛ كانت القيمة الأولى في النظام القانوني المصري القديم هي حماية الحق في الحياة. وكانت الدائرة الأولى للحماية القانونية: هي العقاب بالإعدام على جريمة القتل العمد، بغض النظر عن المركز الاجتماعي للقتيل. أما الدائرة الثانية للحماية القانونية. فهي إلزام كل فرد بواجب قانوني محدد، هو الدفاع عن أي فرد يتعرض للقتل. ولذلك إذا عجز عن إنقاذه من يد القاتل؛ فإنه كان يلتزم بواجب الإبلاغ لدى أقرب مركز للشرطة. كانت عقوبة الإعدام هي جزاء كل من نكص عن الدفاع عن القتيل؛ رغم قدرته على ذلك. وقد تحول ذلك الالتزام القانوني بمرور الوقت إلى واجب أخلاقي، توارثه المصريون حتى وقت قريب. كان الدفاع عن ابن الحتة وبنات الحتة واجباً اجتماعياً؛ وكان المصري يخضع لجزاء معنوي صارم إذا أخل بهذا الواجب.
- وأغلب الظن أن تعامل المجتمعات القديمة مع القرينة المذكورة؛ كان مبعثه في البداية هو الدفاع عن كيانه المادي. بمعنى أن كان من مصلحة أهل المنطقة التي وُجدت فيها جثة القتيل أن تسعى إلى قطع النزاع. ذلك أن حسم النزاع كان يحميها من مغبة الثأر وعاقبة الانتقام؛ الذي قد يقدم عليه أهل المجني عليه وجماعته.
- لدينا سؤال منطقي: إن وجود جثة القتيل في منطقة أو بلدة بعينها؛ هو قرينة على أن الجريمة تم ارتكابها بواسطة أحد سكان المنطقة أو البلدة. غير أن الفاعل لم يزل مجهولاً؛ ولذلك تنتمي تلك القرينة إلى دائرة الاحتمال. ومن هنا تأبى اعتبارات المنطق والعدالة النظر إليها باعتبارها قرينة قطعية.
- من هذه الزاوية يمكننا تفهم موقف الكثير من المجتمعات قديماً؛ في طريقة تعاملها مع تلك القرينة. كانت يتم التعامل مع تلك القرينة باعتبارها دليل نفي؛ وليس دليل إثبات لجريمة القتل. وكانت تلك المجتمعات تلجأ إلى تحليف أهل المنطقة أو البلدة؛ أو تحليف عدد محدد منهم؛ فيحلفون على براءتهم من دم القتيل. كان اليمين أو القسم كفيلاً بقطع النزاع مع أهل المجني عليه؛ وقبولهم الدية من أهل المنطقة أو البلدة.

📌 **يلاحظ** أننا نتناول موقف أربعة مذاهب فقهية؛ وهي المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي.

📌 **فيما يتعلق بالمذهب الحنفي**: فقد تبنى الفقهاء الأحناف الموقف التقليدي والقديم؛ الذي كان يتعامل مع قرينة القسامة باعتبارها دليل نفي. وهنا نسأل: لماذا عارضت المذاهب الثلاثة الأخرى هذه الاتجاه؛ واتخذت من القسامة دليل إثبات لجريمة القتل - وليس دليل نفي. إن استعمال القسامة باعتبارها دليل إثبات؛ كان يترتب عليه التعامل مع الجريمة باعتبارها جريمة قتل عمد؛ والتوصل إلى القصاص من القاتل؛ عن طريق نظام القسامة.

📌 كانت هناك مشكلة تواجه المذاهب الثلاثة الأخرى وهي أن قرينة القسامة - وحدها لم تكن كافية لإسناد جريمة القتل إلى فرد محدد. والسؤال: كيف تمكنت تلك المذاهب من حل المشكلة؛ وهل كان الحل مناسباً؛ من جهة اعتبارات المنطق والعدالة؟ قد يُقال إن تلك المذاهب - بما فيها المذهب الحنفي - نظرت إلى العدالة؛ ولكن من زاويتين مختلفتين.

تفسير اتجاه الفريقين :

١- **تبدو اعتبارات المنطق واضحة - لدى فقهاء المذهب الحنفي**: لأنهم يتعاملون مع قرينة تفيد الاحتمال وليس اليقين. لا يجوز طبقاً لاعتبارات العدالة إنزال القصاص أو عقوبة الإعدام على أحد سكان المكان؛ دون التثبت على وجه القطع؛ أي دون التأكد تماماً من ارتكابه لجريمة القتل.

٢- **تبدو اعتبارات العدالة أكثر وضوحاً - لدى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى**: لماذا؟ لأنهم يسعون للقصاص من القاتل؛ بينما يكتفي الأحناف بالدية. ومما لاشك فيه أن الوصول للقاتل الحقيقي وإخضاعه للعقاب؛ هو الاتجاه الأقرب للعدالة.

٣- **لهذا السبب اشترط الفقهاء في المذاهب الثلاثة الأخرى**: وجود قرينة إضافية؛ تدعم القرينة الأصلية. ونقصد بالقرينة الأصلية: وجود جثة القتيل؛ في موضع تختص به مجموعة من الأفراد. وتتحقق القرينة الإضافية: في كل حالة يكون لدى أهل القتيل؛ دليل ضد أحد سكان المكان وقد أطلق الفقهاء على تلك القرينة الإضافية اسم اللوث. ومن أمثلة اللوث: أن يتمكن أهل القتيل من إثبات وجود عداوة بين القتيل؛ والفرد الذي يتهمونه بالقتل الذي هو من سكان المكان.

كيف يدخل المنطق .. لدعم دور القرينة في الإثبات؟

📌 **ماذا لاحظت**: هناك ميزة تشتمل عليها طريقة الاستدلال بالقرينة. تسمح تلك الطريقة بدعم القرينة الأساسية؛ بقرينة أخرى إضافية أو أكثر. وهناك فائدة عظيمة نحصل عليها من تلك الطريقة؛ في مجال إثبات الحقوق وحسم النزاع. ما رأيك أن نطلق على عملية الدعم بالفرائئ اسم تعضيد القرينة؟. تفيد هذه العملية في مجال ترجيح الأدلة على بعضها البعض. هل تريد مثال مبسطاً لفكرة تعضيد الأدلة:

١- **وجود أحد الأفراد في مسكن المجني عليه**: يعتبر قرينة على قيامه بالاعتداء على المجني عليه وأفراد أسرته.

٢- **تتدعم هذه القرينة بقرينة أخرى**: ومن ذلك مثلاً وجود رائحة الخمر التي تفوح من فم الفرد المذكور.

٣- **قد تتدعم القرينة بقرينة ثالثة**: ومن ذلك مثلاً وجود سابقة اعتداء كان هذا الفرد متهماً فيها؛ أو صدر بشأنها حكم قضائي ضده.

من أرشيف المنطق القانوني:

📌 أصدرت محكمة الإسكندرية الأهلية حكمها الشهير في قضية "ريا وسكينة" بتاريخ ١٥ من مايو ١٩٢١م. قضت المحكمة بإعدام ستة من المتهمين، من بينهم حسب الله زوج ريا. كان حسب الله قد اعترف بقتله ثمانية نسوة؛ من جملة سبع عشرة امرأة. غير أنه أنكر اعترافه أمام النيابة العامة، مبرراً ذلك بأنه اعترف تحت تأثير الخوف والإهانة. لم تعول المحكمة بشأن عدول حسب الله عن اعترافه. واعتمدت على قرائن متعددة، يقوي بعضها بعضاً. أهمها: أن الإقرارات الصادرة منه كانت مفصلة مما يرجح أنها كانت بإرادته، وأن خاتمه كان موجوداً بالتراب أثناء النباش عن جثث النساء؛ وأنه كان ملازماً لزوجته ريا؛ الأمر الذي يرجح أنها كانت تستغله في خنق الضحايا؛ ونقلهن للدفن أسفل المنزل.

أرجو أن تهتم بدعم القرينة التي بين يديك؛ بقرينة أخرى أو أكثر. إن تعضيد القرينة واحدة من الأدوات التي تعينك في إثبات الحقوق. وربما ستفاجئ حضرة المحامي بأن دعم القرينة قد يكون أداة فعالة؛ لإنقاذ موكلك من حكم بالإدانة. وهناك أكثر من مفاجأة أخرى؛ تبدأ بامرأة عربية كانت أسبق من غيرها في الاستدلال بالقرائن.

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

كان الظهار بمثابة طلاق في جاهلية العرب وفجر الإسلام؛ وصورته أن يقول الزوج لزوجته "أنت علي كظهر أمي". استعملت الزوجة - وهي خولة بنت مالك بن ثعلبة - مجموعة من القرائن التي يدعم بعضها. ويفضل تلك الصحابية الجليّة؛ أخذ الظهار حكم اليمين في شريعة الإسلام؛ وتجب فيه الكفارة المغلظة. وقد وثقت السنة النبوية تلك القرائن؛ ومن بعدها سورة المجادلة في الآيات (٢-١).

القرينة الأولى: أن الزوج لم يتلفظ بكلمة الطلاق.

القرينة الثانية: أن الزوج كاذب في عبارته-المذكورة؛ لأن الزوجة ليست أمه.

القرينة الثالثة: أنه ليس من المنطقي أن تنقضي الرابطة الزوجية بسبب عبارة كاذبة لم تتضمن لفظ الطلاق!. كان منطق خولة بنت ثعلبة دقيقاً؛ جمعت فيه بين التفكير العقلي؛ واعتبارات العدالة. ولذلك فإنني أنظر إليها باعتبارها إحدى العرييات المتأصلات في المجال الحقوقي. وهي من هذه الزاوية تستحق أن تكون المحامية الأولى في تاريخ المسلمين.

ندريب - ١١ - القرينة المدعومة قد تكون أقوى أثراً من بعض الإقرارات:

حضر إليك - حضرة المحامي - بعض الأفراد؛ لتوكيلك في قضيتهم. والتي تتلخص في أن قريبهم كان قبل وفاته قد أصيب بمرض لا شفاء منه وانتهى بوفاته. وأن قريبهم - رحمة الله عليه - في فترة مرضه اعترف بوجود دين عليه بمبلغ كبير؛ لمصلحة أحد ورثته. الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من جزء من ميراثهم بعد وفاة قريبهم المذكور.

يوجد إقرار من المريض مرض الموت: بوجود دين عليه لصالح أحد الورثة؛ كيف يمكنك أن تتغلب على ذلك الاعتراف أو الإقرار؟

لديك أكثر من قرينة يدعم بعضها البعض: القرينة الأولى: أن الاعتراف بالدين صدر في فترة مرض الموت. والقرينة الثانية: أن الإقرار بالدين كان لصالح أحد الورثة-دون غيره.

تشير كل قرينة منهما إلى سبب من أسباب الضعف أو التهمة: لأن من شأن مرض الموت؛ أن يؤثر على إرادة المريض ولياقته الذهنية. ومن شأن الإقرار بالدين لأحد الورثة؛ أن يثير شبهة المحاباة له؛ على حساب باقي الورثة. ولذلك فإن الإقرار بالدين على النحو المذكور ربما كان حيلة؛ لمصلحة ذلك الوارث على وجه التحديد. إن تمسكك -حضرة المحامي -في دفاعك بهاتين القرينتين: يثير الشك في الإقرار الصادر من قريبهم المتوفى؛ ويدعم طلب الورثة بإبطال التصرف الصادر من قريبهم.

ندريب - ١٢ - القرينة المدعومة قد تكون أقوى أثراً من أصل البراءة:

طلب المدعي من المدعى عليه سداد المبلغ؛ الذي افترضه وجاء موعد سداذه. لم يكن لدى المدعي دليل قاطع؛ لإثبات تخلف المدعى عليه عن السداد. طلب المدعي ليحلف على أنه قام بالسداد. امتنع المدعى عليه عن الحلف:

الأصل في كل فرد: هو براءة الذمة؛ ولذلك يقع عبء الإثبات على المدعي؛ الذي يدعي أن له دين في ذمة أحد الأفراد.

لكن أمامك أكثر من قرينة: القرينة الأولى: أن المدعى عليه لم ينكر وجود الدين أصلاً في ذمته. بمعنى أن الدين ثابت لا نزاع حوله؛ ولا حاجة للبحث في مسألة إثبات الدين بالكتابة في هذا الموضع. أما القرينة الثانية: فهي أن المدعى عليه رفض أداء اليمين؛ على قيامه بسداد الدين.

هل يمكنك -حضرة القاضي - أن تستند إلى القرينتين: فتحكم بإلزام المدعى عليه بالسداد؛ لأن وجود القرينتين معاً أقوى أثراً؛ من أصل البراءة أي براءة الذمة الذي يتمتع به كل فرد.

س ٥ : وضع متي وكيف يتفاعل المنطق مع الكذب في مجال القانون ؟

متي وكيف يتفاعل المنطق مع الكذب في مجال القانون

ينحاز المنطق القانوني للناس ومصالحهم، في الأحوال التي يصبح القانون فيها جامداً وعاجزاً عن التطور. يرفض المنطق اتساع الثغرة بين مصالح الناس، وبين القانون القائم. وترفض العدالة المنطق الشكلي، الذين يقدس القانون في ذاته؛ لأن الغاية من أي نظام قانوني هي حفظ مصالح الناس؛ والإقرار بتطلعهم للحياة الكريمة!.

هل الحيلة القانونية حل دائم.. أم هي وسيلة انتقالية؟

صدق أو لا تصدق! كان الناس مجبرين على الكذب؛ بهدف تغيير القانون. كان الناس يسعون - بالطبع - إلى تحقيق مصالحهم. وكانت طريقتهم هي أن يفترضوا وجود واقعة؛ لم تحدث في الحقيقة أو الواقع! بمرور الوقت أصبح يُطلق على الافتراض أو الكذبة القانونية اسم الحيلة. كان الغرض من افتراض الواقعة هو التحايل على قاعدة قانونية محددة. وكان يترتب على الافتراض: تطبيق القاعدة على واقعة لم تحدث أصلاً.. تخيل!.

إليك المثال التقليدي بخصوص توريث الجنين؛ عقب وفاة أبيه.

القاعدة القانونية: اشتراط حياة الوارث وقت وفاة المورث.

الحيلة / الكذبة: افتراض ولادة الجنين حياً.

النتيجة: تطبيق القاعدة القانونية على الافتراض / الكذبة.

يتم توريث الجنين على الرغم من أن القانون لا يورث سوى الأحياء.

كانت الحيلة أكثر الطرق المناسبة لتطوير القانون؛ في مجتمعات بعينها. وسنتحدث عن نوعين من المجتمعات؛ الأول: تلك المجتمعات التي كانت تتمسك بالإجراءات الشكلية؛ في التصرفات القانونية والدعاوى القضائية. والنوع الثاني: المجتمعات التي كان التشريع الديني هو المصدر الأساس للقانون فيها:

١- في النوع الأول من المجتمعات:

كانت الحيلة وسيلة للتغلب على القيود التي تتمثل في الإجراءات التي يتطلبها القانون. كان على المتعاقد مثلاً أن ينطق بألفاظ وعبارات معينة؛ أو يقوم بحركات محددة. وكان على المدعي أن يلتزم ببعض الإجراءات الشكلية الصارمة لقبول دعواه. بمعنى أن عدم التزام المتعاقد بتلك الألفاظ أو الحركات كان يترتب عليه بطلان تعاقد. وهو الجواب ذاته؛ إذا لم يفرغ المدعي دعواه في صيغة شكلية؛ من الصيغ المحددة في الدعاوى القضائية.

٢- في النوع الثاني من المجتمعات:

كانت الناس يلجأ للحيلة؛ بهدف الالتفاف على بعض الأحكام الشرعية. سواء تلك الأحكام التي تحرم بعض التصرفات القانونية؛ ويترتب عليها بطلان التصرف أو التعاقد. أو تلك التي تفرض عليهم بعض الفروض المالية؛ وفي مقدمتها زكاة المال. وهو الأمر الذي نلاحظه على المجتمع الإسلامي-في بعض العصور.

مثال ذلك: أن نصاب الزكاة في الذهب والفضة والنقود عند المسلمين هو ما يعادل (٨٥) جراماً ذهباً عيار

٢١. وقد يتحايل رب الأسرة؛ للتهرب من زكاته قبل نهاية العام الذي تُستحق فيه الزكاة. فيقوم بتقديم بعض الأموال على سبيل الهبة إلى بعض أولاده وزوجته. وهي هبة شكلية وافتراضية-غير حقيقية. والهدف من هذه الحيلة: أن يأتي وقت استحقاق الزكاة وهو نهاية العام الهجري مثلاً؛ ويجد رب الأسرة نفسه وهو لا يمتلك النصاب أو الحد الأدنى الذي تجب به الزكاة!.

لا تقدم الحيلة حلاً جذرياً للمشكلة أو النزاع؛ ولذلك تكمن وظيفتها في تقديم الحل العلمي الناقص لمشكلة ما. وبمعنى آخر: تقدم الحيلة حلاً انتقالياً ولفترة محددة؛ وتنتهي تلك الفترة في اللحظة التي يتدخل فيها التشريع أو العرف؛ لتعديل القاعدة القانونية التي لا تتفق مع مصالح الناس. وهكذا ينتهي دور الحيلة بعد تغيير القاعدة القانونية؛ فتنتضي الفترة الإنتقالية؛ وتزول حاجة أفراد المجتمع للحيلة.

يلاحظ ان ← الحيلة حل انتقالي ومتدرج في مجال تطوير القانون ويلاحظ النموذج التالي :

القاعدة القانونية القديمة: تغير مصلحة الناس وتعارضها مع القاعدة القديمة ← ظهور الحيلة بهدف

تغيير حكم القاعدة القديمة ← القاعدة القانونية الجديدة.

المنطق الانتقالي في الحيلة القانونية:

١- **الحيلة هي الإسعاف القانوني:** الذي يستدعيه الناس؛ للتغلب على جمود القانون؛ وتعارضه مع مصالحهم. ولذلك السبب ستبقى الحيلة دوماً؛ ما عاش الناس!

٢- **الحيلة هي المصدر المادي لبعض القواعد القانونية:** بمعنى أن هناك بعض القواعد التي لم تكن في أصلها سوى حيل قانونية؛ نشأت على يد أفراد المجتمع. وقد تدخل المجتمع فيما بعد؛ فأدمج هذه الحيلة أو تلك؛ في قاعدة عرفية أو تشريعية.

يلاحظ انه ← تختلف الحيلة القانونية؛ عن التشريع؛ فيما يتعلق بخاصية التدرج والانتقال من حكم لآخر خلال فترة زمنية محددة:

١- **يمكن للمشروع - بالطبع:** أن ينظم أحد الموضوعات بطريقة متدرجة وانتقالية. ويمكنك أن تصف التدرج هنا بأنه تدرج مصطنع أو مقصود أو مخطط.

٢- **أما خاصية التدرج في الحيلة:** فهي خاصية لصيقة بها ومن طبيعتها. ولذلك إذا كانت الحيلة ثمرة وعي الناس بمصالحهم: فإن التدرج في الحيلة أمر لازم ويتم بدون إرادة منهم.

هناك أحكام قانونية انتقالية؛ تُطبق لفترة محددة؛ وينتهي العمل بها وتفقد قيمتها القانونية فور انتهاء المدة المنصوص عليها. ومن ذلك نص المادة (٢٣٢) في دستور ٢٠٤ المعدل: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. وقد يكون الهدف من الحكم القانوني والانتقالي تكليف إحدى السلطات العامة بمهمة خلال مدة زمنية. ومن ذلك نص المادة (٢٤٠) من دستور ٢٠١٤ المعدل: تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

يقبل المنطق القانوني خاصية التدرج في الحيلة القانونية؛ وهي تمر من مرحلة إلى أخرى؛ حتى يكتمل نموها ويستوي عودها ويكتمل أثرها. ولا يوجد سبب واحد يمكننا به تفسير خاصية التدرج في الحيلة؛ لأنها تنشأ لأسباب مختلفة:

١- **قد يكون السبب هو قوة القاعدة القانونية:** التي يتم التحايل عليها؛ وتنبع تلك القوة عادة من القيمة المجتمعية؛ التي تتمتع بها القاعدة لدى أفراد المجتمع وفي نفوسهم بل وفي تاريخهم. وفي تلك الحالة تحتاج الحيلة إلى سنوات وسنوات؛ حتى يحصل القبول بها والرضا باستعمالها بين أغلب الأفراد.

٢- **قد يكون السبب هو نوع الحيلة:** لأن بعض الحيل معقدة ومركبة؛ ومن ذلك النوع الحيل الصورية؛ والتي يستعملها الأفراد عادة باعتبارها ستارة قانونية؛ بهدف إخفاء التصرف الحقيقي.

تدريب - ١٣ - المنطق القانوني يساعدك في البحث عن حقيقة العقد:

جاءك أحد الأفراد في مكتبك؛ لتوكيلك في قضية، ورفع دعوى قضائية على شقيقه وأبيه. كان الأب قد باع شقة يمتلكها إلى ذلك الأخ الشقيق؛ بينما لم يكن الأخ الشقيق يتمتع بدخل مالي؛ لأنه كان طالباً وقت إبرام عقد البيع. فما هو موضوع النزاع؛ وهل توجد حيلة؛

وما هو التكييف القانوني الذي تستخلصه منها:

- ماذا لاحظت على عقد البيع؛ هل هو سليم ويشتمل على أركان عقد البيع؛ ما هي تلك الأركان؟. وهل تحققت من أن الأخ الشقيق كان قد سدد ثمن البيع؛ وهل يختلف الأمر لو كان يسدده على أقساط؟
- وإذا لم يكن الأخ الشقيق قد سدد الثمن؛ فما هو مسمى العقد الحقيقي الذي حصل به على الشقة؟. وهل كان تصرف الأب على سبيل الحيلة؛ إذن ما هي القاعدة القانونية التي تم التحايل عليها؟
- وما هي القاعدة القانونية التي يستند إليه موكلك؛ لإبطال عقد البيع الذي تم لمصلحة الأخ الشقيق؟

الحيلة القانونية: هل هي تماماً.. كذبة خالصة وقياس كاذب؟

لاحظنا ← فيما مضى أن القرينة القانونية كانت تقوم على فكرة محددة؛ هي وجود علاقة أو رابطة محتملة بين واقعتين اثنتين. بمعنى أن وجود الواقعة المعلومة؛ يجعل من وجود الواقعة المجهولة أمراً محتملاً. من المنطقي أن تكون هناك نتيجة قانونية؛ تترتب على وجود تلك العلاقة. وتتمثل النتيجة القانونية في تطبيق القاعدة القانونية المرتبطة بوجود الواقعة المجهولة. وهكذا فإن تطبيق تلك القاعدة القانونية كانت نتيجة منطقية؛ بسبب وجود العلاقة أو الرابطة المحتملة بين الواقعة المعلومة والواقع المجهولة.

السؤال: هل تنطوي الحيلة القانونية على علاقة منطقية من ذلك النوع؛ الذي نجده في القرينة القانونية؟. بمعنى هل توجد علاقة محتملة بين واقعتين اثنتين؛ الواقعة المفترضة والتي هي مجرد كذبة لا وجود لها في الواقع وبين واقعة أخرى محتملة وجودها في الحقيقة؟ بالطبع لا يمكننا أن نقاوم إغراء المقارنة؛ في هذا الموضوع. وسنجد شيئاً من ذلك في التدريب التالي:

تدريب - ١٤ - المنطق القانوني طريقك لكشف العقود الموهوبة:

ماذا تفعل عندما يميز الأب بين أولاده؛ ويقوم ببيع شقة لأحد أولاده؛ بيعاً صورياً لأنه بلا ثمن. لديك - حضرة المحامي - فرصة لمساعدة الأولاد في استرداد حقهم؛ ورفع الإثم عن أبيهم بعد وفاته. ماذا تلاحظ في القضية التالية:

- **في القضية التي بين أيدينا:** ينطوي تصرف الأب على كذبة قانونية؛ ببساطة: ليس لدينا عقد بيع حقيقي؛ لأن ركن الثمن - وهو ركن أساسي - غير موجود.
- **يقول المحامي الموكل من الأب والابن:** إن القانون يسمح للمورث بعمل وصية شرعية لأحد ورثته؛ وذلك في نطاق ثلث التركة - لا أكثر. وأن الثمن المذكور في عقد البيع - والذي لم يسنده الابن فعلاً يعادل ثلث التركة التي تركها الأب لأولاده.
- **ما قاله المحامي هو قياس صحيح تماماً:** ذلك بسبب توافر العلة؛ ببساطة: لانة في الوصية: يحصل الموصي له على الشيء الموصي به مجاناً أي بدون مقابل - بعد وفاة الموصي بالطبع.
- **في القضية التي بين أيدينا:** لم يدفع الابن جنيهاً واحداً؛ مقابل الشقة التي تملكها من أبيه؛ ومع ذلك فإنه استلم الشقة وفرشها وسكن فيها!.
- **ترد على المحامي الموكل من الأب وابنه:** بأن وجود الكذبة يصيب القياس بالضعف الشديد؛ ويحول دون تطبيقه؛ وذلك لأكثر من سبب منطقي.

🌟 طبقاً للقاعدة القانونية تكون الوصية للوارث صحيحة في حدود ثلث التركة:

أوصى الأب لابنه بثلث تركته، وباع له شيئاً من التركة يعادل الثلث. القياس متوافر لوجود العلة، وهي أن الوصية في ناطق ثلث التركة. الحيلة متوافرة أيضاً لأن تصرف الأب أخذ شكل البيع خلافاً للحقيقة.

هدف الحيلة:

🌟 تطبيق القاعدة القانونية على واقعة لا يجوز أصلاً أن تطبق عليها.

🌟 **ما هو الهدف المباشر في الحيلة القانونية؟** تهدف الحيلة إلى تطبيق القانون؛ على واقعة لم يوضع لها القانون في الأصل. بمعنى أنه يترتب على التحايل تغيير حكماً لقانون؛ مع الحفاظ على بقاء القانون ذاته. لماذا لا نتأمل هذه العبارة من زواياها المختلفة؟

🌟 **الزاوية الأولى:** نلاحظ منها أن مصالح الناس أسرع ظهوراً وأقوى أثراً؛ ولذلك فهي أسبق في خطواتها من حركة القانون. وهو أمر منطقي؛ لأن تغيير القانون يحتاج إلى تدخل السلطة؛ التي يعترف المجتمع بدورها في صناعة القانون.

🌟 تقوم المجالس النيابية والبرلمانات بمهمة التشريع في أكثر دول العالم. وتخضع عملية التشريع للعديد من الإجراءات؛ قبل أن يصبح التشريع ملزماً لأفراد المجتمع. ومن هنا كانت الحيلة غالباً أسبق في ملاحظة مصالح الناس؛ مقارنة بالتشريعات الوضعية.

🌟 **الزاوية الثانية:** فإننا نلاحظ منها الغاية من الحيلة؛ بمعنى لماذا يتقبل الناس نتيجة الحيلة؛ ويستعملونها في معاملاتهم؟. نقول: إن المصلحة هي الغاية من الحيل التي يقبل عليها الناس. غير أنه يجب أن يوجد مبرر منطقي - خلف تلك المصلحة؛ حتى تستقر الحيلة وتنتشر بين الناس. قد ترد -عزيزي القارئ- بالقول: أي مبرر منطقي ونحن نفترض واقعة لا توجد في الواقع؟. أي مبرر منطقي ونحن نخترع كذبة؛ ونرتب عليها نتيجة قانونية:

🌟 **يلاحظ** ← إن الواقعة المفترضة أو الكاذبة؛ غير منفصلة تماماً عن حياة الناس. إن الواقعة المفترضة لا تحلق في الهواء تماماً؛ لأنها تحتفظ بقدر من العلاقة بالواقع. وإن هذه الخصيصة هي التي تساهم في انتشار الحيلة بين الناس وقبولهم لها ورضاهم بها.

١- **قد تكون الواقعة المفترضة غير مستحيلة:** أي تكون من الوقائع التي يتصور حصولها عقلاً؛ ولو بعد حين. **مثال ذلك:** الحيلة في توريث الجنين بافتراض ولادته؛ والحيلة في افتراض موت المفقود؛ الذي سقطت طائرته ولم يُعثَر على جثته. في هذه الحالة أو تلك: من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يولد الجنين حياً؛ بعد أقل من ستة أشهر؛ وهي أقل مدة الحمل. وكذلك من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يظهر المفقود بعد حين؛ وهو أمر يشهد به الواقع بشأن ضحايا الحروب والزلازل.

٢- **قد تكون الفكرة التي يقوم عليها الافتراض:** مقبولة لاعتمادها على منطق محدد. وهو ما نلاحظه في نوع من الحيل؛ التي تقوم على فكرة احترام العلاقة الأدبية أو المعنوية بين الأفراد. ومن ذلك: افتراض وجود قرابة بين فردين؛ بحيث يترتب عليها تحريم الزواج بينهما. تحرم الشريعة الإسلامية الزواج بين الفتاة وأحد الأفراد؛ بسبب الرضاعة من امرأة واحدة. وتطبيقاً لذلك: فإن خمس رضعات مشبعات كافية لحصول التحريم بينهما؛ سواء كانت الرضعات مجتمعات أو متفرقات.

🌟 تلك هي العلة في تحريم الزواج بين الأخوين في الرضاع؛ على الرغم من أنهما ليسا أخوين في الواقع. ويترتب على هذه الحيلة: تطبيق الحكم الشرعي والقانوني؛ الذي يحرم زواج الأخ بأخته. ألا تتفق معي أنه تنشأ علاقة روحية أو أدبية؛ بين الفتاة والفتى الذين جمعتهما الرضا من نفس المرأة. تنطوي الحيلة على احترام تلك العلاقة؛ وهو أمر له منطق؛ ولذلك يقبله العقل لدى الكثيرين.

❖ **مثل ذلك:** كان المنطق يختلط بالمصلحة؛ الأمر الذي كان يمهد لقبول حيلة أو كذبة القرابة.

ما تلاحظه في التطبيقين التاليين:

١- **التطبيق الأولي:- علاقة الأخوة في شركة التضامن:** تتميز تلك الشركة بوجود التضامن بين الشركاء في ديون الشركة. ولذلك فهي واحدة من الشركات التي نطلق عليها اسم "شركات الأشخاص"؛ تمييزاً لها عن شركات الأموال. ظهرت فكرة التضامن قديماً على أكتاف الحيلة. عندما افترضت بعض المجتمعات وجود علاقة الأخوة بين الشركاء في الشركة. الأمر الذي كان يترتب عليها التزام كل أخ/ شريك بديون الشركة؛ مع غيره من الأخوة / الشركاء.

٢- **التطبيق الثاني :- علاقة الأبوة في أحوال العتاقة:** اعترفت الكثير من المجتمعات القديمة بعلاقة الأبوة بين السيد؛ وبين العبد الذي حصل على حريته من سيده. وعلى سبيل المثال- وفي المجتمع العربي قبل الإسلام: كان العتيق يتحمل مجموعة من الواجبات تجاه سيده القديم؛ ومنها: واجبه في خدمة سيده والثار لمقتله. وكان العتيق يستحق شيئاً من ميراث سيده القديم؛ إذا لم يكن للسيد أقارب يستحقون ميراثه.

من أرشيف المنطق القانوني:

❖ كان الجانب المعنوي والأدبي واضحاً في بعض حيل القرابة؛ فقد اعترف القانون الإيرلندي القديم بالعلاقة الأدبية بين المعلم وتلميذه. ولذلك فقد تم التعامل معها باعتبارها قرابة حقيقية؛ مثل تلك التي تجمع بين الأب وابنه. ومن هنا كان المعلم يتمتع بالحق في الانتفاع ببعض الأموال التي يمتلكها تلميذه. وفي جاهلية العرب- أي قبل الإسلام: كانت الأخوة تنعقد بين فردين؛ إذا عاهد كل منهما الآخر، أنه يلتزم بالدفاع عنه والقصاص من قاتله. ويترتب على ذلك العهد ويسمى الموالاة ثبوت الحق لكل منهما في الإرث من الآخر. وتعتبر الموالاة هي الأصل التاريخي لنظام الإخاء؛ وهو النظام الذي عرفه المهاجرون والأنصار؛ عقب الهجرة الشريفة عن مكة أم القرى إلى المدينة المنورة.

❖ **يلاحظ ←** أن العلاقة الأدبية والمعنوية كانت أساساً للعديد من الحيل. وأن تلك الفكرة كانت سابقة على الأديان الكبرى؛ التي عرفتها المجتمعات البشرية. ولأحظت فيما مضى تطبيقاً للحيلة عند المسلمين؛ وأثر الديانة فيها. وأود أن أصرح حضرتك بأمر هام وخاصية جديدة - في الحيلة. وخلاصة ما أصرحك به: أن الحيلة لم تقطع علاقتها بالأفكار المتأصلة في نفوس الناس؛ حتى وهي تخضع للتأثير الديني.

❖ **بعض التطبيقات:** التي تتعلق بذلك النوع من الحيل؟ فكرة التطهر في المجتمعات القديمة. كان الماء والنار في مقدمة الوسائل التي يتطهر بها الإنسان القديم. ولذلك من المنطقي أن تلحظه بين الوسائل التي لجأت إليها تلك المجتمعات؛ في تنفيذ عقوبة الإعدام. كان الإعدام عن طريق التغريق- وكذلك الحرق- أكثر انتشاراً؛ وخاصة في الجرائم الخطيرة.

المنطق القانوني.. والوعي الشعبي:

❖ لدينا ظاهرة مصرية تستحق البحث المتعمق؛ وهي أن العديد من العبارات تسلت إلى الحكم الشعبية؛ على الرغم من افتقارها للسند الاجتماعي والتاريخي. ومن تلك العبارات التي لا سند لها: رش الماء عداوة. وهي العبارة التي تتعارض مع المعتقد الشعبي بخصوص الماء - عبر العصور. كان الماء هو الوسيلة التي يتم استعمالها- على سبيل الرمز في الطهارة المعنوية والجسدية. وقد انتقلت تلك الفكرة إلى أغلب الأديان؛ حيث يعتبر الغسل شعيرة رمزية؛ سواء عند اعتناق الديانة؛ أو قبل القيام ببعض العبادات وفي مقدمتها الصلاة.

❖ لقد أشرنا في أكثر من موضع كيف أن الكثير من الحيل كانت قد انتقلت من عصر إلى عصر؛ بفضل أثرها في حياة الناس ونظمهم الاجتماعية والقانونية. وفي هذا النطاق يمكنك أن تلاحظ بعض التطبيقات في الديانتين اليهودية والمسيحية. وإليك التطبيق التالي الذي يرتبط بفكرة الماء ورمزيتها في الديانة المسيحية.

التعميد هو أحد الشعائر الأساسية في الديانة المسيحية؛ حيث يبدأ به المرء حياته الإيمانية والمسيحية. تعود جذور التعميد المسيحي إلى الغسل؛ الذي خضع له السيد المسيح ليه السلام؛ على يد النبي يحيى أو يوحنا المعمدان في مياه نهر الأردن. وهناك علاقة بين التعميد؛ وبين الأفكار التي ترسخت في المجتمعات القديمة. من ناحية أولى: يتم التعميد بالماء باعتباره رمزاً أو أداة للطهارة سواء بغسل الوجه أو الرأس أو كل الجسم بالماء. ومن ناحية ثانية: يعبر التعميد بالماء عن فكرة التطهر؛ من أي خطيئة سبقت ميلاد المرء وكان قد ارتكبها الإنسان.

المنطق القانوني وقضايا المجتمع العربي

ما هو دور المنطق القانوني في تمكين المرأة (منطق الفقهاء المسلمين من وظيفة المرأة - نموذجاً)

س ٦: وضع كيف تستخدم المنطق للخروج من دائرة القياس الناقص؟

كيف تستخدم المنطق للخروج من دائرة القياس الناقص

هل يجوز للقانوني أن يتجاهل تطور التقنية؛ وهو يبحث في فقه المرأة عند المسلمين؟. أصبح بإمكان المرأة أن تقوم بالعديد من الأعمال في منزلها؛ وأن تنجز أكثر مهام البيت بالأجهزة التي تختصر الوقت والجهد لقد اختفى طشت الغسيل وطاولة العجين عن جهاز الزوجية. غير أن الحق في العلم سيظل حقاً خالداً!!

كيف تمسك الرافضون لوظيفة المرأة بعلّة الأنوثة؟

ما هو الاتجاه التقليدي في الفقه الإسلامي؛ بشأن الوظيفة العامة للمرأة؟ إليك خلاصته:

ذهب أكثر الفقهاء المسلمين إلى أن الوظيفة العامة هي واجب كفائي؛ يقوم به من كان أهلاً له ولمصلحة المجتمع. وذهبوا إلى أن الأولوية بالنسبة للمرأة هي القيام بواجباتها تجاه زوجها وأولادها؛ وهي الواجبات التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريقها وبواسطتها. وهكذا تقوم لك الواجبات على الاعتبار الشخصي؛ أي أنها ترتبط بشخص الزوجة؛ ولذلك فهي واجب عيني أو فرض عين في حقها. ويترتب على ما تقدم أن الزوجة مطالبة بالوفاء بواجباتها المنزلية بالفعل؛ فلا تسقط عنها إلا بالأداء الحقيقي.

وهناك بعض الاستثناءات؛ التي نستخلصها على سبيل المثال حالتين؛ يجوز فيهما أن تكون المرأة موظفة عمومية:

١- **الحالة الأولى:** إذا تعينت المرأة لإحدى الوظائف العامة؛ والوظائف العامة التي ترتبط بطبيعة المرأة. ومنها مثلاً: المدرسات بالمدارس الابتدائية - طبيبات النساء بمراكز الصحة.

٢- **الحالة الثانية:** عدم وجود من يصلح للولاية من الرجال؛ ويصح أن نضع هذه الحالة تحت مبدأ الضرورة. بمعنى قبول وظيفة المرأة؛ في الحالات التي يتعذر فيها توظيف الرجال؛ بسبب عدم تمتعهم بالشروط المطلوبة في الوظيفة العامة.

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

فرض الكفاية أو الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به بعض الأفراد: فإنه يسقط عن بقية أفراد المجتمع. وبمعنى آخر: هو الواجب الذي إذا قام به بعض الأمة سقط الطلب عن باقيها، وإذا توافقت فأهملت الفعل عوقب جميع أفرادها، وأثم الجميع بالترك. ومن أمثلة فروض الكفاية: تخصص بعض الأفراد في الطب أو الزراعة أو التدريس أو المحاماة.. وتتشابه فكرة فروض الكفاية مع فكرة الواجبات العامة؛ التي عرفتتها المجتمعات اليونانية والرومانية في مدنهم القديمة. وهي أيضاً نفس الفكرة التي عرفتتها القبيلة العربية قبل الإسلام. وخلاصة فكرة الواجب العام: تكليف أو تخصيص بعض الأفراد المجتمع؛ للقيام ببعض الواجبات العامة؛ التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع. غير أن هذه الفكرة تتميز عند المسلمين بأساسها الديني؛ وارتباطها بدعوة الإسلام وتبليغ رسالته.

تكتشف آثار الأنوثة في ثلاثة مظاهر

- ١- **المظهر الأول:** الانفعال والميل مع العاطفة.
- ٢- **المظهر الثاني:** عوارض الأنوثة التي ترتبط بطبيعة المرأة؛ والتي من شأنها أن تضعف من روحها المعنوية وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به.
- ٣- **المظهر الثالث-والأخير:** حاجتها للحماية ودفع الفتنة؛ لأنها بسبب طبيعة أنوثتها غير مأمونة وغير معصومة.

📌 **يلاحظ** ← ان هناك بعض المشايخ رفضت وظيفة المرأة للقضاء و أن منطقهم في هذه المسألة يتجاهل كلا من الواقع القانوني والحقائق العلمية؛ على النحو التالي:

- ١- **من جهة أولى:** يتجاهل الظاهرة التي استقرت في نظامنا القانوني؛ وهي ظاهرة تدوين القانون؛ حيث تنحصر مهمة القضاة في تطبيق القانون المكتوب أي التشريع.
- ٢- **من جهة ثانية:** يتجاهل حقيقة الدور الذي يقوم به القاضي؛ والغاية التي يسعى إليها. ببساطة: يقوم القاضي بالحكم بين المتنازعين في خصومتهم؛ بهدف إقامة عدالة القانون بينهم. والسؤال المنطقي- هنا: هل تعجز المرأة عن هذه المهمة؛ وهل تتعارض أنوثتها عن الوصول للغاية من عملية القضاء؟
- ٣- **من جهة ثالثة:** يتعارض مع حقيقة الواقع والعلم؛ لأنه لم يثبت مطلقاً أن المرأة تعجز عن أي عمل عقلي؛ يقوم به الرجل وهذا بعينه ما صرح به شيخنا محمد المدني؛ على الرغم من رفضه توظيف المرأة. يقول شيخنا بعبارة الواضحة: لا يلزمها من الأنوثة عدم الفطنة أو الذكاء أو المعرفة؛ بل إن الواقع يكذب ذلك.

ما هو المقصود بمقدمات القياس.. وشرط النماذج في عملينه؟

📌 **يلاحظ** ← انه يجب ان تشتمل عملية القياس كما قلنا في أكثر من موضع على واقعيتين. أولاهما: الواقعة النموذج؛ أي نموذج الواقعة الواردة في القاعدة القانونية؛ أو المتضمنة في الحكم الشرعي؛ ونطلق على تلك الواقعة اسم: الأصل. أما الواقعة الثانية: فهي الواقعة المستجدة؛ أو الواقعة موضوع النزاع. ونطلق على تلك الواقعة المستجدة اسماً مخصوصاً هو: الفرع. والهدف من عملية القياس كما نعلم: تطبيق حكم الأصل وهو حكم المقيس عليه على الفرع وهو المقيس.

🌟 **المقصود بعملية القياس:** العملية التي تجري بين واقعتين متماثلتين وهو الوصف الأدق

تمر عملية القياس بالخطوتين التاليتين:

- ١- **البحث عن علة أو سبب الحكم:** في الأصل المقيس عليه؛ أي في الواقعة النموذج.
 - ٢- **التحقق من وجود هذه العلة أو السبب:** في الفرع المقيس؛ أي في الواقعة المستجدة أو محل النزاع.
- 🌟 **لاحظ** ← في التالي كيف طبقنا القواعد الفنية لعملية القياس؛ بعد أن تحققنا من وجود علة الأنوثة في الواقعتين ومقتضى القياس فيه: عدم جواز تولية المرأة وظيفة القضاء. ولكن السؤال:
- 🌟 **هل يوجد تماثل فعلاً بين الواقعة النموذج؛ بين الفرع:-**
- الواقعة النموذج الأصل المقيس عليه:** سفر المرأة منفردة - ملازمة المرأة بيتها.
- حكم الأصل:** لا يجوز - واجب.
- علة/سبب الحكم:** الأنوثة.
- الواقعة محل النزاع الفرع المقيس:** تولية المرأة وظيفة القضاء.

إليك السؤال بصيغة أخرى: هل القياس- في التطبيق السابق- قياس كامل أم ناقص. إننا نصف القياس بالنقصان؛ في حالة عدم وجود التماثل بين كل من الأصل والفرع.

تدريب - ١٥ - بعض الضوابط التي تساعد في تدقيق عملية القياس:

🌟 **يفترض البدء في عملية القياس وجود مجموعة من الضوابط؛ تشكل ما يمكن تسميته بمقدمات القياس.** ومن أهم الضوابط:

- **أن يتعلق القياس بمسألة في المعاملات:** لأنه لا قياس في أغلب أحكام العبادات. وتفسير ذلك: أن أحكام المعاملات يمكن الوقوف على علتها أو السبب منها؛ خلافاً لأغلب الأحكام المتعلقة بالعبادات.
- **التأكد من أن حكم الأصل- المقيس عليه- ليس استثناء:** لأنه لا يجوز القياس على الأحكام الاستثنائية؛ الخاصة بفرد أو مجموعة من الأفراد.
- **التأكد من أن حكم الأصل- أي المقيس عليه- ليس حكماً خاصاً بالأصل مختصاً به:** لأن هذا النوع من الأحكام يختص بواقعة بعينها؛ ولا يجوز تطبيقه على غيرها.

❦ ثلاثة تطبيقات؛ لضوابط القياس التي لا يجوز تجاهلها وإلا كان القياس ناقصاً:

هل يجوز القياس على الأصل	علة / سبب الحكم	الأصل المقيس عليه
❦ القياس هنا غير جائز، لأن حرمان المرأة من السفر منفردة هو حكم استثنائي، والأصل أن المرأة تتمتع بالولاية على نفسها وفي أموالها.	الأنوثة.	١ - سفر المرأة منفردة
		حكم الأصل
		غير جائز.
القياس هنا غير جائز، لأن حكم لزوم المرأة في بيتها هو حكم خاص بأمهات المؤمنين -رضوان الله تعالى عليهن، والقاعدة أن الحكم الخاص لا يقاس عليه.	الأنوثة	٢ - قرار المرأة في بيتها
		حكم الأصل
		واجب
القياس هنا غير جائز، لأن الوظيفة العامة واحدة من مسائل المعاملات. ولذلك لا يصح قياسها على مسألة الإمامة في الصلاة؛ لأن مسألة الصلاة تدخل أساساً في باب العبادات.	الأنوثة	٣ - إمامة المرأة للمصلين بالمساجد
		- حكم الأصل
		غير جائز.

في الجدول السابقة: كان لدينا أكثر من قياس ناقص؛ لأنه كان يفتقد إلى شرط التماثل بين الأصل والفرع. ومن هذه الزاوية: فإنه لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الأقيسة الناقصة؛ لحرمان المرأة من الوظيفة العامة.

تدريب - ١٦ - ضوابط أخرى في تدقيق عملية القياس:

يشير التساؤل هل يوجد تماثل بين الأصل والفرع:

❦ توقف بعض أساتذتنا أمام حديث بنت كسرى: "لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وهي العبارة التي تُنسب للنبي عليه السلام. أما المناسبة التي قيلت فيها؛ فهي ورود الأخبار بوفاة كسرى ملك الفرس؛ وتنصيب ابنته ملكة من بعده على أهل فارس.

❖ **خلاصة رأي بعض أساتذتنا في هذا الشأن:** أن الحديث النبوي إنما هو دليل على عدم جواز تولية المرأة منصب الخلافة أو الإمامة العظمى غير أنه لا ينطبق على الوظائف الأخرى الأدنى مرتبة.

❖ **تفصيل رأيهم:** أنه لا يجوز حرمان المرأة من أي وظيفة عامة؛ قياساً على منعه من منصب الخلافة. لماذا: لأن هذا القياس يخلو من شرط التماثل. لأن الخلافة هي الولاية أو الوظيفة الأعلى في نظام الولايات الإسلامي. ومن المنطقي القول: إنه لا يصح أن نقيس وظيفة عامة أدنى مرتبة؛ على وظيفة أخرى أعلى مرتبة.

❖ **إليك الجدول التالي:** أرجو أن تختبر فيه كل قياس؛ وقوة المنطق فيه. قبل أن نعود مرة أخرى للبحث في حديث بنت كسرى المذكور بالتفصيل. ونناقش الآراء المختلفة حول الحديث؛ وله يجوز الاحتجاج به لحرمان المرأة من أي وظيفة عامة.

❖ **الأصل:** تولية المرأة منصب الخلافة أو الإمامة العظمى.

❖ **حكم الأصل عند جمهور الفقهاء:** غير جائز.

❖ **علة/سبب الحكم:** الأنوثة.

❖ **-هل يجوز القياس على الأصل لمنع المرأة من الوظيفة العامة:** القياس جائز؛ لأن منصب الخلافة هو أعلى المناصب أو الوظائف في نظام الولايات العامة عند المسلمين، ولذلك فهو ينطبق على أي وظيفة أدنى أو أقل درجة.

❖ ١-القياس غير جائز: لأن منصب الخلافة هو أعلى المناصب في نظام الولايات الإسلامي، فلا يجوز أن نقيس عليه أي وظيفة عامة أقل مرتبة.

❖ ٢-القياس غير جائز: لأن منصب الخلافة هو أعلى المناصب في نظام الولايات الإسلامي، فلا يجوز أن نقيس عليه أي وظيفة عامة أقل مرتبة

س٧: وضع كيف تستخدم المنطق في الاستنباط من النص الشرعي؟

كيف تستخدم المنطق في الاستنباط من النص الشرعي

❖ أثبتت المرأة جدارتها في العمل والحكم والقيادة؛ وهو أمر تشهد به المجتمعات في عصرنا شرقاً وغرباً. وتقدم المرأة في مجتمعاتنا العربية الدليل تلو الدليل؛ على قدراتها العقلية والجسمانية؛ وهي تعول مئات الآلاف من الأسر وتدرّب شئونها. لم يعد هناك محل لأكذوبة الرجل القديمة؛ عندما كان يُقضي المرأة بحجة ضعفها!!

ماذا نعرف عن القياس الجلي.. أو القياس من باب أولى..؟

❖ **عزيزي القارئ:** تشترط في عملية القياس وجود العلة أو سبب الحكم؛ في الأصل المقيس عليه؛ وفي الفرع المقيس. تفترض عملية القياس أن تكون علة الحكم بنفس القوة؛ في الأصل والفرع معاً. ماذا تفعل عندما تجد أن علة الحكم في الفرع أقوى درجة؛ مقارنة بقوة العلة في الأصل...، ويطلق على هذا النوع من القياس اسم: القياس الجلي أو القياس من باب أولى.

نُدرِب - ١٧ - درجة القوة في العلة نُؤثر في عملية القياس:

- تطبيق مستمد من حياتنا الاجتماعية تتعرف فيه على عملية القياس الجلي أو القياس من باب أولى:
- اتفق المريض مع أحد الجراحين على القيام بعملية جراحية في معدته.
- أجرى الطبيب عملية استكشافية بالمنظار؛ قبل القيام بالجراحة المتفق عليها. تطلبت عملية المنظار إدخال الخرطوم-الخاص به- من فم المريض إلى معدته؛ فتسبب في نزيف تم التحكم فيه بصعوبة.
- رفع المريض دعوى تعويض ضد الجراح؛ بحجة أن الاتفاق مع الجراح لم يكن يشمل جراحة المنظار. هل كان المريض محقاً في دعواه؟

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

وضع الفقهاء المسلمون شروطاً لصحة الحديث النبوي والعمل به؛ منها شروط تتعلق بنص الحديث النبوي؛ وشروط أخرى تتعلق برواية الحديث السند. وحديث الآحاد: هو الحديث الذي لم يبلغ حد التواتر؛ وأغلب تلك الأحاديث قام بروايته صحابي واحد أو اثنين عن النبي عليه السلام. والحديث المتواتر: الحديث الذي رواه عدد من الصحابة؛ لا يمكن طبقاً للعادة أن يتفقوا على الكذب على النبي عليه السلام؛ وأقله عند البعض عشرة من الرواة. ولم يختلف الفقهاء المسلمون بشأن حجية حديث الآحاد؛ ولكنهم اختلفوا في مرتبة العمل به؛ بمعنى تقديم أو تأخير تطبيقه في الواقع. ولماذا اختلف الفقهاء في مرتبة العمل به؛ بمعنى تقديم أو تأخير تطبيقه في الواقع. ولماذا اختلف الفقهاء في مرتبة العمل به؛ لأن حديث الآحاد ظني الثبوت؛ أي لا يمكن أن نجزم - قطعاً - بصدوره عن النبي عليه السلام؛ وبالتالي فإن الحكم المستخلص منه هو حكم ظني لا يفيد اليقين.

كيف نسنعين بالمنطق في ترتيب المعاني الهاردة بالنص الشرعي؟

يقول المنطق - عند أكثر مشايخنا - إذا سلمنا بحرمان المرأة من منصب الخلافة: فإنه يلزم التسليم بحرمانها من الوظائف الأدنى؛ ومنها وظيفة القضاء. لقد منعتها علة الأنوثة من الوظيفة الأعلى. ولذلك ومن باب أولى فإنه يتم حرمانها من أي وظيفة أخرى أدنى.

لماذا لا ننظر إلى حديث بنت كسرى من زاوية أخرى؟ لماذا لا نفتش عن الضوابط؛ التي تساعدنا في استخلاص المعنى المقصود منه:

- ١- **قد يكون لدينا نص تشريعي:** وتتعدد المعاني المستفادة منه؛ وقد تختلف تلك المعاني بين بعضها البعض؛ فما هو العمل عندئذ؟ المنطق يقول: إن المعنى الأقوى درجة هو المعنى الأولي بالتطبيق؛ وهو الذي يجب أن نبني عليه الحكم؛ بعد أن نستبعد غيره من المعاني.
 - ٢- **هكذا يحسم المنطق:** طريقة التعامل مع المعاني المستفادة من النص الشرعي؛ فلا يجوز أن نترك المعنى الأقوى درجة؛ وننتقل إلى المعنى الأقل درجة؛ دون دليل نطمئن إليه.
 - ٣- **السؤال المنطقي:** هل نترك المعنى الحرفي للنص؛ ونطبق بدلاً منه المعنى المستفاد من دلالة النص؟ لاشك أننا بحاجة للتعرف على معنى هذه المصطلحات؛ وكيف تتدرج في قوتها.
- أمامك حديث بنت كسرى "لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

ظاهر النص = المعنى الحرفي للنص: المقصود به: أول معنى يجيء في ذهنك عند قراءة النص. وبالتطبيق على حيث بنت كسرى: فإن النبي عليه السلام كان يتحدث عن أعلى منصب في دولة الفرس؛ وهو المنصب الذي يقابله منصب الخلافة - عند المسلمين.

دلالة النص = روح النص: المقصود به: المعنى الذي يرتبط بسبب صدور النص. وبالتطبيق على حديث بنت كسرى: كان النبي عليه السلام يتحدث عن ولاية المرأة بصفة عامة؛ وليس عن ولاية بعينها. ولذلك يشمل حديثه عليه السلام كل من: منصب الخلافة، وأي منصب عام آخر.

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

ينبغي وجود علاقة منطقية بين النص التشريعي من جهة؛ والمعنى الذي نستمد منه النص ونبنى عليه الحكم من جهة أخرى. كان عمل الفقهاء المسلمين يتم في هذا الإطار المنطقي. وذلك لأنهم كانوا يبحثون عنه بمقتضى النص. ولذلك فقد اعتمدوا على المنطق؛ في الترجيح بين المعاني المستفادة من النص التشريعي. وأعطوا لكل معنى درجة من القوة؛ طبقاً لقوة العلق المنطقية بين النص، وبين المعنى المستخلص منه إنه كما تلاحظ عمل عقلي ومنطقي؛ ولذلك يمكننا أن نعتمد على هذا المنهج في تناول النص الشرعي؛ وقد ننهي إلى نتيجة تخالف آراء الفقهاء السابقين.

🌟 **النص:** لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

🌟 **ظاهر النص أو عبارة النص وهو المعنى الحرفي للنص:** منع المرأة من وظيفة الخلافة - فقط.

🌟 **نتيجة التطبيق:** يجوز تولية المرأة أي وظيفة عامة أخرى، بما فيها وظيفة القضاء؛ لأنها أقل درجة من وظيفة الخلافة.

🌟 **دلالة النص وهو روح النص:** منع المرأة من أي وظيفة عامة. لأن النبي عليه السلام كان يتحدث عن النساء بوجه عام وعن إسناد الشئون العامة للمرأة.

🌟 **نتيجة التطبيق:** لا يجوز تولية المرأة أي وظيفة عامة؛ إلا من باب الضرورة، أو تلك الوظائف التي ترتبط بطبيعة النساء.

وسنجد في عصرنا يستدلون بهذا الحديث في منع المرأة من منصب رئاسة الدولة:

١- **لقد حصر أساتذتنا حكم الحديث:** في منع المرأة من ولاية عامة محددة؛ وهي ولايتها منصب الخلافة أو الإمامة العظمى. ولذلك فإنه يجوز للمرأة عندهم أن تتولى الوظائف العامة الأدنى مرتبة والأقل سلطة؛ ومنها وظيفة القضاء على سبيل المثال.

٢- **أضاف بعض أساتذتنا:** دليلاً آخر؛ لدعم رأيهم الذي يفرق بين منصب الخلافة؛ وغيره من المناصب العامة. وخلاصة دليلهم: هو أن منصب الخلافة أو الإمامة يشتمل على اختصاصات دينية؛ ومنها الإمامة في الصلوات؛ وهي الإمامة التي لا تجوز للمرأة.

٣- **قد انتهى أساتذتنا إلى نتيجة تتفق مع منطقهم:** وهي نتيجة تتعلق بعصرنا؛ عندما ذهبوا إلى منع المرأة من منصب رئاسة الدولة؛ إذا كانت الدولة تخضع لنظام الحكم الرئاسي. ومن المعلوم أن نظام الحكم الرئاسي يتشابه مع نظام الخلافة الإسلامية. أما وجه التشابه بين النظامين: فهو تركيز المهام التنفيذية بيد مسئول واحد وهو رئيس الدولة في النظام الرئاسي؛ والخليف في نظام الخلافة الإسلامية.

🌟 **من ذلك:** أنه يجوز لها أن تتولى منصب رئيس الدولة في نظم الحكم البرلمانية؛ وكذلك منصب الوزير أو المحافظ أو القاضي-بغض النظر عن نوع نظام الحكم.